

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

**شرح وتعليق على الدراسة النصية
للفرقة الثالثة / كلية الشريعة والقانون**

جمع وإعداد

أ د / فتحي عثمان عمر الفقي
أ د / محمود علي عبدالجواد
أ د / علي محمد علي

وكيل كلية الشريعة والقانون الأسبق
أستاذ الفقه المساعد بكلية
أستاذ الفقه المساعد بكلية

والأستاذ المتفرغ بقسم الفقه بالكلية
والقانون بالقاهرة
الشريعة والقانون بالقاهرة

وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف

وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الموضوعات المقررة في الدراسة النصية
١ - باب الحوالة.
٢ - كتاب الضمان وأحكامه.
٣ - باب الإجارة.

تمهيد،،

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين
الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد،،،،

فنظرا لأهمية المعاملات في حياة كل إنسان؛ لأنها تعتبر الوسيلة
الوحيدة المشروعة لتبادل الأموال والمنافع بين الناس، ولأن معرفة حلالها
وحرامها واجب وضروري على كل مسلم ؛ فلأجل هذا استخرت الله تبارك
وتعالى - وطبقا للمنهج المقرر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الشريعة
والقانون ، الفقه المالكي - اخترت كتابي " الحوالة " و " الضمان " من السفر
الزاهر ألا وهو (الشرح الكبير للعلامة: أحمد الدردير، على مختصر العلامة
: خليل بن إسحاق الجندي) فقامت بالنظر والتأمل في النص، ثم قمت
بصياغته بأسلوب سهل ميسر بما فتح الله به علي؛ لكي يتسنى لأبنائنا
الطلاب الإلمام بأحكام هذين البابين في سهولة ويسر، محاولا قدر جهدي أن
أبحث عن دليل لكل ما أذكر من أحكام قدر الإمكان ، واضعا نصب عيني أن لا
أتعرض لغير مذهب المالكية؛ حيث إن الدراسة مذهبية

وبعد، فهذه محاولة عاجز لا حول له ولا قوة إلا بالله، لم أقصد بها إلا
وجه الله سبحانه وتعالى، فإن كان في هذه المحاولة من توفيق فهو من الله
العلي القدير ، والله وحده الفضل والمنة ، وإن كانت الأخرى ، فمن نفسي ومن
الشيطان ، ومن الله وحده العفو والغفران ، وأهمس - في أذن كل من اطلع
على ما كتبت فوقعت عينه على خطأ - بما قال الإمام الشافعي رحمه الله : -

تعمدني بنصحك في انفرادي ❖ وجنبني النصيح في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع ﴿٥﴾ من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت قلبي ﴿٥﴾ فلا تجزع إذا لم تعط طاعة
فجزى الله خيرا كل من اطلع على خطأ ، فقام بواجب النصح فأصلح
وستر

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ﴿٥﴾ وعين السخط تبدي المساويا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الدراسة النصية

باب الحوالة

باب الحوالة

يقول المصنف : [دَرْسٌ] (بَابُ) فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ وَأَحْكَامِهَا، وَهِيَ : نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ إِلَى أُخْرَى تَبَرُّاً بِهَا الْأُولَى ^(١) "

(١) الشرح والتعليق: تعريف الحوالة ، الحوالة لغة : اسم مأخوذ من التحول، وهو التنقل من موضع إلى موضع، أو حول الشيء من مكانه: نقله منه إلى مكان آخر، وحول وجهه : لفته.

والحوالة شرعا: " نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " وتعقب هذا التعريف بالآتي : كلمة " نقل " النقل حقيقة في الأجسام، وعرفها العلامة الدردير في النص بقوله : " نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ إِلَى أُخْرَى تَبَرُّاً بِهَا الْأُولَى " وتعقب هذا أيضا: بأن جملة : " تبرأ بها الأولى " : حشو ؛ لعدم افادته مدخلا ، أو مخرجا . وعرفت أيضا بأنها : تحول الدين من ذمة تبرأ بها الأولى ، وتعقب هذا أيضا ، بأنه عرف الشيء بنفسه (تحول وحوالة) .

* شرح تعريف الدردير: قوله " بمثله " جار ومجرور متعلق بنقل ، وكذلك قوله " إلى أخرى " أي نقل الدين من ذمة لأخرى بسبب وجود مثله في الأخرى ، قوله : " تبرأ بها الأولى " أي تبرأ به ، أي بالنقل ، وأنت الضمير " بها " نظرا لمعنى النقل لأن معنى النقل (هو الحوالة) وهي مؤنثة ، ولفظ النقل مذكر .

حكم الحوالة:

قال القاضي عياض : هي مندوبة، عند أكثر شيوخ المالكية، وقيل : مباحة ؛ لما أشبهت بيع الدين بالدين ، فهي رخصة مستتناة من بيع الدين بالدين ، جوز للحاجة على خلاف القياس ولهذا لم يشترط التقابض في المجلس إذا كان الدينان ربويين كجنيهات بجنيهات أو جنيهات بريالات ، فهي بيع ؛ لأنها إبدال مال بمال ، فكأن المحيل باع للمحال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحال في ذمته ، وجاز تأخير القبض نظرا لمعنى الرخصة لأنها موضوعة على الرفق ، فيدخلها خيار المجلس عند من يقول به - حيث لا يعتبره الحنفية والمالكية - * والصحيح ما قاله ابن قدامة في المعنى : " من أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعا لما جازت لكونها بيع دين بدين، ولما

جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال ربوي بجنسه لا يجوز تأخير القبض فيه ، بل لابد من أن يكون يدا بيد.

دليل مشروعية الحوالة:

ثبتت مشروعية الحوالة بالسنة والإجماع :

أولاً : السنة : ما رواه البخاري بسنده - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ»

وفي رواية للبخاري ومسلم : " من أحيل على ملئ فليحتل " * معاني مفردات الحديث : " المطل " : منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه ، قوله : " فليتبّع " الصواب : تسكين التاء في " أتبع " ، وفي " فليتبّع " يقال : " تبعت فلانا بحقي وأنا أتبعه بتسكين التاء " وذهب البعض إلى تشديدها وهو ضعيف ، فلا يقال : أتبعه بفتحها وتشديدها إلا في المشي خلفه.

وجه الاستدلال من الحديث : أن لفظ " أتبع " بالتخفيف معناه : إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبّع ، أي فليحتل ، أي فليقبل الحوالة ، يقال : أتبعته غريمي على فلان فتبعه ، أي أحلته فاحتال .

حكم قبول الحوالة:

وليس قبول الحوالة بواجب على المحال بل هو على سبيل الإباحة ، أو الندب ، إن اختار قبول الحوالة قبل وإن شاء لم يقبل ، لم يقبل ، وهذا خلافا لما ذهب إليه أهل الظاهر ، وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير ، فإنهم حملوا لفظ الحديث على الوجوب ، أما الجمهور فحملوه على الاستحباب.

ثانياً : الإجماع : حكاه ابن مفلح من الحنابلة في المبدع له ، فقال وهي ثابتة بالإجماع ، ولا عبرة بمخالفة الأصم (الأصم هو : عبد الرحمن بن كيسان الأصم - ٢٠١ - ٢٧٩ هجرية فقيه مفسر ومتكلم معتزلي كان جليل المقدر يكاثبه السلطان وكان صبوراً على الفقر) ، فقد أجمع جمهور العلماء على جوازها في الجملة ، وإن اختلفوا في بعض المسائل.

شروط صحة الحوالة

يقول المصنف : (شَرَطُ) صِحَّةِ (الْحَوَالَةِ رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمَحَالِ فَقَطُ) لَا الْمَحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُرَجَّحَيْنِ.

وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ (وَتُبُوتُ دَيْنٍ لَازِمٍ) لِلْمُحِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمَحَالِ عَلَيْهِ وَكَذَا لِلْمَحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَإِلَّا كَانَتْ وَكَالَةً لَا حَوَالَةً ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى كَانَتْ حَمَالَةً إِنْ رَضِيَ الْمَحَالُ عَلَيْهِ لَا حَوَالَةً وَإِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ^(١)

(١) * الشرح والتعليق: يشير المصنف في هذا النص إلى بعض شروط صحة الحوالة وهي

: ١ - رضا المحيل والمحال ٢ - حضور المحال عليه وإقراره - طبقا للراجح من أحد القولين المرجحين - ٣ - ثبوت دين المحيل والمحال، وإليك بيانها وتوضيحها:

الشرط الأول: رضا المحيل والمحال ، اختلف فقهاء المذهب في هذا الشرط على رأيين : الرأي الأول : وهو مشهور المذهب (ومعنى المشهور هو : ما كثر قائله) : أنه يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط فلا يشترط رضا المحال عليه.

وحجتهم لهذا : قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحيل على ملئ فليحتل " متفق عليه ، ووجه الاستدلال منه : أنه صلى الله عليه وسلم : لم يشترط رضا المحال عليه ، ولأن الحق للمالك فله أن يملكه من شاء ، كسائر الحقوق ، ولأن المحيل أقام المحال في القبض مقام نفسه ، فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق ، قياسا على ما لو وكل المحيل المحال في قبض دينه من المحال عليه.

إضافة : وأضاف المالكية : أن الحوالة صحيحة رضي المحال عليه ، أو لم يرض ، إلا إذا كان بين المحال عليه والمحال عداوة دنيوية سابقة على وقت الحوالة ، فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور ، وهذا قول الإمام مالك ، فإن حدثت العداوة بعد الحوالة أو كانت عداوة دينية منع المحال من اقتضاء الدين من المحال عليه ، ووكل من يقتضيه منه ؛ لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته.

الرأي الثاني : وهو مقابل المشهور في المذهب (حكاه ابن شعبان) : من انه لا بد من رضا المحال عليه.

وحجة من قال بهذا: أن المحال عليه يلزمه الدين بالحوالة ، ولا لزوم إلا بالتزامه ولو كان مديونا للمحيل ؛ لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء ما بين سهل ميسر ، وصعب معسر ، ثم إن المحال عليه أحد من تتم بهم الحوالة ، فأشبهه المحيل ، فلا بد من رضاه.

الشرط الثاني : حضور المحال عليه وإقراره.

التساؤل : هل يشترط لصحة الحوالة حضور المحال عليه وإقراره أم لا ؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين :

القول الأول : يشترط من يقول به : حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين ، وإن كان رضاه بالحوالة لا يشترط وهذا قول ابن القاسم ، واقتصر عليه الوقار وصاحب الإرشاء وصاحب الكافي.

وحجة هذا القول : يشترط حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين ؛ لاحتمال أن يكون له مطعنا في البينة ، ولن يتمكن من ذلك إلا إذا حضر ، أو يثبت براءته من الدين ببينة على السداد والدفع ، أو على إقراره بالدفع ، أو إبرائه منه ، أو نحو ذلك.

والأثر المترتب على هذا القول : أنه لا تجوز الحوالة على الغائب ، وإن وقعت الحوالة على هذه الصورة فسخت حتى يحضر المحال عليه ، وهذا هو المعتمد في المذهب والمعتمد معناه : القوي سواء كانت قوته لرجحانه ، أو لشهرته.

القول الثاني : لا يشترط حضور المحال عليه في مجلس الحوالة ، وهذا هو قول عبد الملك وغيره من الموثقين والأندلسيين ، ولم أعر لهذا القول على حجة مستقلة لقولهم هذا إلا ما سوف يستنبط من سبب الخلاف بين القولين

سبب الخلاف بين القولين : هل الحوالة من قبيل بيع الدين بالدين ؟ أم هي أصل مستقل بنفسه ؟ فالقول الأول الذي اشترط حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين ، يرى أنها من قبيل بيع الدين بالدين ؛ ولذا فيشترط فيها شروطه ، (ومن أهمها حضور المدين وإقراره بما عليه من الدين) غاية ما في الأمر أنه رخص في جواز بيعه بدين آخر ، أما القول الثاني الذي لا يشترط حضور المحال عليه في مجلس الحوالة ، فبنى وجهته هذه على أساس أن الحوالة أصل مستقل بنفسه ، فلا يسلك بها مسلك بيع الدين بالدين من : اشتراط حضور المحال عليه وإقراره بما عليه من الدين .

الشرط الثالث : ثبوت دين المحيل والمحال ، وهذا الشرط يستلزم : أ - ثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه ب - ثبوت دين المحال في ذمة المحيل.

أ - ثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه.

لزوم الدين

يقول المصنف : **وَاخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ (لَازِمٌ) عَنْ دَيْنٍ صَبِيٍّ وَسَفِيهِ وَرَقِيقٍ بِغَيْرِ**
إِذْنٍ وَلِيِّ وَسَيِّدٍ فَلَا تَصِحُّ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِمْ بِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ثَمَنُ سِلْعَةٍ مَبِيعَةٍ
بِالْخِيَارِ قَبْلَ لُزُومِهِ (فَإِنْ أَعْلَمَهُ) أَيْ أَعْلَمَ الْمُحِيلُ الْمُحَالَ (بِعَدَمِهِ) أَيْ الدَّيْنِ بِأَنْ
قَالَ لِلْمُحَالَ : لَا دَيْنَ لِي عِنْدَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إِنْ عَلِمَ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي
الْمُدَوَّنَةِ.

(وَشَرَطَ) الْمُحِيلُ (الْبَرَاءَةَ) مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَرَضِيَ الْمُحَالَ (صَحَّ)
التَّحَوُّلُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّهُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّحَوُّلِ (وَهَلْ)
مَحَلُّ عَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيلِ (إِلَّا أَنْ يَفْلَسُ أَوْ يَمُوتَ) الْمُحَالَ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ
الْمُحَالَ عَلَى الْمُحِيلِ ، أَوْ لَا يَرْجِعُ مُطْلَقًا مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ ، وَإِلَّا رَجَعَ (تَأْوِيلَانِ)
وَالْمَذْهَبُ الْإِطْلَاقُ^(١)

(١) أولاً : توضيح ما غمض من مفردات النص : معنى : " لزوم الدين " الدين اللازم هو :
 الدين الناشئ عن التزام صادر عن شخص يتمتع بأهلية الأداء الكاملة التي تستلزم : البلوغ ، العقل ، والرشد ، أي أن يكون مأذوناً له في التصرف ، أي له ولاية إصداره ، سواء كانت هذه الولاية أصلية ، أو نيابية .

الخيار : هو : طلب خير الأمرين من الإمضاء ، أو الفسخ
 الفلس : أفلس الرجل ، أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، ويستعمل مكان :
 افتقر ، وهو نوعان :

١ - فلس عام وهو : إحاطة الدين بأموال المدين ٢ - فلس خاص وهو : قيام الغرماء أي الدائنين بالطلب ، وقضاء القاضي بخلع ماله لغرمائه.

* قوله : " تأويلان " هذا من مصطلحات المالكية ، ويراد به : اختلاف شارحي المدونة في هذه المسألة - وإن لم يتصدوا لشرح سائرهما - في فهم المراد من ذلك الموضع ، المؤدي فهم كل له إلى خلاف فهم الآخر ، ويختلف المعنى به ، ويصير قولاً غير الآخر ، ويجوز الإفتاء بكل وإن لم يرجح بعضها على بعض.

المذهب : هذا من مصطلحات المالكية ، يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوفا عليه من الإمام مالك رحمه الله تعالى أو يكون هو مشهور المذهب .

ثانيا : الشرح والتعليق

يشترط المالكية لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال به ، أو عليه لازما ، وهم بذلك يحترزون عن الحوالة على الدين الغير لازم ، كدين على صبي ، أو سفيه ، أو رقيق (والرق لا وجود له الآن) إذا استدان هؤلاء بغير إذن من ولاهم الشارع عليهم من ولي ونحوه ، فلا تصح الحوالة عليهم به ؛ لعدم لزوم الدين لهم لأن لولي الصغير ونحوه طرح الدين عنهم وإسقاطه ، وكذلك ثمن المبيع في زمن الخيار ؛ لأن البيع في زمن الخيار صحيح غير لازم وكذلك دين الكتابة (والمكاتب الذي لا وجود له الآن ؛ ولكن توضيح الحكم يستلزم ذكره) فدين الكتابة غير لازم للمكاتب لأن المكاتب إن عجز عن سداد دين الكتابة لا يتبع به ، فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا دائنا له على المكاتب

* وتصح الحوالة ولا يرجع المحال على المحيل إذا توفر ثلاثة شروط:

الأول منها : أن يعلم المحيل المحال بعدم الدين على المحال عليه بأن يقول المحيل للمحال : " لا دين لي عند المحال عليه " أو علم المحال بذلك من غيره .

الثاني منها : اشتراط المحيل على المحال البراءة من الدين الذي عليه.

والثالث : ورضي المحتال بذلك ، وإن لم يرض المحال عليه لكن إن رضي المحال عليه لزمه ، وإلا فلا يلزمه أن يطالبه المحال ، لا أصل الدين ، كما هو منصوص عليه في المدونة قال ابن القاسم فيها : " إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضي بأن يحتال عليه ، وأبرأه من ذلك ، أنه لا يرجع عليه ، ويؤخذ هذا بما أقر به ، وإن كان لم يعلم فله أن يرجع . (المدونة الكبرى ج ٤ / ١٤٩ ، كتاب : الحوالة ، باب : في الرجل يحيل الرجل على الرجل ليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين) وبناء على وجود هذه الشروط الثلاثة يصح التحول ولا رجوع للمحال على المحيل ؛ لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول على هذه الكيفية

* **تساؤل :** إذا أعلم - بالبناء للمجهول - المحال بعدم الدين على المحال عليه ، واشترط المحيل على المحال البراءة من الدين الذي عليه وأنه لا رجوع له بعد ذلك عليه ، ورضي المحتال بذلك وصح التحول ، فهل لا رجوع له مطلقا ؟ أي سواء فلس المحال عليه ، أو مات ، أو لا ؟

* **والجواب :** تأويلان في هذا:

الأول منهما : أنه لا يرجع المحال على المحيل إذا توافر الشرطان السابقان ما لم يفلس المحال عليه ، أو يموت ، أي أنه إذا أفلس المحال عليه ، أو مات رجع المحال على المحيل ، وهذا تأويل ابن المواز .

الثاني من التأويلين : أنه لا رجوع للمحال مطلقا إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة، أي سواء فلس المحال عليه ، أو مات وهذا هو ظاهر قول ابن القاسم ، ما دام أنه قد اشترط عليه البراءة من الدين ، وهذا هو المذهب .

*** تساؤل آخر :** إذا لم يكن هناك دين في ذمة المحال عليه للمحيل ورضي المحال عليه (مجازا) بالحوالة ودفع فعلا للمحال ، فهل له الرجوع على المحيل بما دفع ، أم لا ؟
*** والجواب :** لقد اختلف فقهاء المذهب في هذا على النحو التالي :

القول الأول : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي (١٠١٠ - ١١٠١ هـ) لو رضي المحال عليه بالحوالة مع عدم ثبوت دين في ذمته للمحيل ، ومع هذا دفع رجوع له على المحيل بهذا الذي دفعه ؛ لأنه متبرع ؛ حيث لا دين عليه .

القول الثاني : قال به : عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري (١٠٢٠ - ١٠٩٩ هـ) وهو أنه ينبغي أن يكون له الرجوع ؛ لأن اشتراط البراءة إنما هو بالنسبة للمحال (أي براءة المحيل من دين المحال ، أما المحال عليه فله الرجوع وسمي محال عليه تجوزا) ، ولأن رضا المحال عليه بالدفع صيره بمنزلة الحميل ، والحميل أي الضامن يرجع بما غرم وهو كالقرض من المحال عليه . [راجع فيما سبق : الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٣ / ٣٢٦ ، الشرح الصغير ٢ / ١٥٣ ، شرح الخرشي بحاشية العدوي ٤ / ٢٣٣ ، مواهب الجليل للحطاب ٥ / ٩٢ ، شرح الزرقاني بحاشية البناني ٦ / ١٨] .

القول الثالث : وقال به العلامة العدوي وهو : أن الذي ينبغي هنا أنه إن قامت قرينة على تبرع المحال عليه بما دفع فلا رجوع له بما دفعه ، وإلا كان له الرجوع ، كأن يكون هذا المحال عليه ذا غنى ويسار ، ومعروف عنه أنه يفرج كرب المكروبين

صيغة الحوالة

يقول المصنف : " (وَصِيغَتُهَا) أَي لَفْظُهَا الْخَاصُّ ، كَأَحْلَتُكَ عَلَى فُلَانٍ وَحَوَّلْتُ حَقَّكَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ مُحَالٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهِيَ مَا دَلَّ عَلَى تَرْكِ الْمُحَالِ دَيْنَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِمِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ انْتَهَى ، وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ خُذْ حَقَّكَ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا تَتَحَصَّرُ صِيغَتُهَا فِي لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنَ الْحَوَالَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنَّفِ ^(١)

(١) الشرح والتعليق : علق ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير بقوله : وهذا محل نظر : لأن ظاهر كلام المصنف لا يقتضي انحصار صيغتها في اللفظ المشتق من الحوالة ، إلا أن يقال : إن هذا ظاهر بمعونة ما ذكره في الهبة حيث قال فيها : " الصيغة أو مفهمها " فأراد بالصيغة ما كان مشتقا من لفظ الهبة بقريضة قوله " أو مفهمها " فلما اقتصر هنا على قوله : " وصيغتها " ولم يقل : " أو مفهمها " دل على أن مراده بصيغتها : ما كان مشتقا من لفظ الحوالة [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٥٣١] .

قوله : " وصيغتها " عطف على قوله : " ورضا المحيل " ورضا المحيل ركن ، وهو هنا يذكر شروط صحة الحوالة ، ففي كلام المصنف مسامحة ؛ لأن الصيغة ركن لا شرط ، لكن الفقهاء يتسامحون فيطلقون الشرط على الركن ، ووجه هذا التسامح : أن النتيجة المترتبة على تخلف أي منهما الركن أو الشرط واحدة وهي عدم صحة الحوالة.

* هل يشترط في صيغة الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة ؟

* والجواب : في هذا اتجاهان :

الأول منهما : ظاهر كلام العلامة " خليل " وبعض الفقهاء أنه يشترط أن تكون الصيغة بلفظ الحوالة ؛ لأن الألفاظ التي ذكرها العلامة الدردير كأمثلة شارحا بها كلام العلامة " خليل " وهي : أحلتك على فلان أو حولت حقك على فلان ، أو أنت محال ، كل هذه العبارات تقتضي انحصار الصيغة فيما ذكر ، أي أن تكون مشتقة من لفظ : " التحول " ، ولأنه لم يقل كما قال في باب الهبة " أو مفهمها " أو ما دل ، وبناء على هذا قال ابن القاسم : في الرجل يطلب الرجل في حقه ، فيذهب به إلى غريم له فيقول له : خذ حقك من هذا ،

وبأمره بالدفع إليه ، فيتقاضاه إياه ، فيقضيه بعض حقه أو لا يقضيه ، فيريد أن يرجع على الأول ببقية حقه ، أو بحقه فله ذلك ، فليس هذا بوجه الحوالة اللازمة ؛ لأن له أن يقول : لم أحتل عليه بشيء ، إنما أردت أن اكفيك التقاضي ، وأما وجه التحول اللازم أن يقول : أحيلك على هذا بحقك علي وتبرئ ذمتي مما تطلبني به ، وأن لا ترجع علي ، وأيد هذا ابن رشد ؛ لأن الحوالة بيع من البيوع ينتقل بها الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين ، وهو التصريح بلفظ الحوالة.

الاتجاه الثاني : وهو لابن عرفة وهو المذكور في النص بقوله " مَا دَلَّ عَلَى تَرْكِ الْمُحَالِ دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِمِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ خُذْ حَقَّكَ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَنْحَصِرُ صِيَغَتُهَا فِي لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنَ الْحَوَالَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (والمعتمد سبق تعريفه في ص ٩)

حلول الدين المحال به

يقول المصنف : " (وَحُلُولُ) الدَّيْنِ (المُحَالِ بِهِ) وَهُوَ الَّذِي عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَالًا أَدَّى إِلَى تَغْيِيرِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ فَيُؤَدَّى إِلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، أَوْ الْوَرَقِ بِالْوَرَقِ ، أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ لَا يَدَا بَيِّدَ إِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ عَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ حَالًا وَيَقْبِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِثْلَ الصَّرْفِ فَيَجُوزُ ، وَبَالَغَ عَلَى شَرْطِ حُلُولِ الْمُحَالِ بِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ كِتَابَةً) حَلَّتْ ، أَوْ عَجَلَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ ، وَأَحَالَ بِهَا الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَى غَرِيمٍ (لَا) حُلُولَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ (عَلَيْهِ) فَلَا يُشْتَرَطُ " (١)

(١) أولاً : الصرف هو : دفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة في مقابلة الآخر، ويعبر عنه في وقتنا الحاضر : بمبادلة نقود وطنية بأخرى غير وطنية ، كمبادلة الجنيهاات الوطنية بالدولارات الأمريكية.

ثانيا : قوله في النص : " وَإِنْ كِتَابَةً " الرقيق رغم أنه لا وجود له الآن إلا أنه من باب العلم بالشيء فهي : عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.

الشرح والتعليق : يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال به حالا ، وهو الذي في ذمة المحيل للمحال ، وعلة هذا الشرط أن الأصل في الحوالة المنع ، لكن رخص فيها الشارع بقيود منها حلول الدين المحال به ، وإلا خرجت عن حدود الرخصة والرخصة لا تتعدى موردها ، وأخذ البعض هذا الشرط من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم " ووجه الاستدلال منه : أن المطل لا يكون إلا بالدين الحال ، ولا يشترط حلول ما على المحال عليه ؛ لأنه إذا احتال على من لم يحل عليه دينه كان ذلك زيادة معروف ، واستثنى من هذا (أي من اشتراط حلول الدين المحال به كشرط لصحة الحوالة) بمعنى أنه إذا كان الدين المحال به غير حال فلا تجوز الحوالة إلا أن يكون دين المحال عليه حالا ، وإلا فلا ، قال الرماصي (العلامة مصطفى الرماصي المالكي ، عالم جزائري ، من مدينة رماصة توفي في ١١٣٦ هـ / ١٧٢٤ م) : " إن خرجت الحوالة عن محل الرخصة لعدم حلول الدين المحال به ففي هذه الحالة تطبق عليها القواعد العامة ، فإن أدت إلى تعميم ذمة المحيل والمحال عليه بالمطالبة فتكون من بيع الدين بالدين ، ويمنع هذا للنهي عن ذلك ؛

لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " وهو النسيئة بالنسيئة ، أي التأخير ، ومعناه لو كان الدينان عينا من ذهب أو فضة فليست يدا بيد عند اتحاد جنس الدينين وكذلك عند اختلافهما

تعليق إضافي : عند قول المصنف : " لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَالًا أَدَّى إِلَى تَعْمِيرِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ فَيُؤَدَّى إِلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالْذَّيْنِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لَا يَدَا بِيَدٍ إِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ عَيْنًا " قال العلامة العدوي : الصواب في تعليل المنع في هذه المسألة ما ذكره ابن عرفة من أنه يؤدي إلى " ضع وتعجل " و " حط الضمان وأزيدك " حيث إن المحيل ضامن لدين المحال ، فإذا ما أحاله بدينه الذي لم يكن حالا - وبمقتضى الحوالة سوف يبرأ منه - فكأن المحال وضع وأسقط الضمان عن المحيل وزاده في تعجيل دينه ؛ لأن من عجل ما أجل عد مسلفا في مقابل حط الضمان عنه ، أما ما ذكره العلامة الدردير في النص : " تَعْمِيرِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ " فهو لازم في جميع صور الحوالة ، كما ذكره القاضي عياض عن شيوخه ، كذا قرره بعض شيوخ أهل المغرب ، ثم بعد ذلك رأيت في " محشي التتائي " قال : مراد الأئمة بهذا : أنها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل المحال به كان ذلك محل الرخصة [حاشية العدوي / على شرح الخرشي ٦ / ٢٩٥ ، حاشية الدسوقي / الشرح الكبير ٤ / ٥٣١].

والإجماع منعقد على منع ذلك ، حكاه الإمام أحمد رحمه الله ، وإن أدت إلى بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو أحدهما بالآخر لا يدا بيد إن كان الدينان عينا ، وهذا منهي عنه شرعا ، ودليل ذلك : ١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي لَفْظٍ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدَا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى ، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.

وَفِي لَفْظٍ : « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ،

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

ففي كل ما سبق تمنع الحوالة ؛ لأنها سوف تؤدي إلى ممنوع إلا إذا كان الدين المحال عليه حالا ويقبضه المحال قبل أن يتفرقا مثل الصرف ففي هذه الحالة يجوز .

تساوي الدينين

يقول المصنف : " (و) شَرَطُهَا (تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ) الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ (قَدْرًا وَصِفَةً) مُرَادُهُ بِالتَّسَاوِي قَدْرًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَأْخُذُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَلَا أَقَلَّ فَلَا يُحِيلُ بِخَمْسَةٍ عَلَى عَشْرَةٍ وَعَكْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَبًّا فِي الْأَكْثَرِ وَمَنْفَعَةً فِي التَّحَوُّلِ إِلَى الْأَقَلِّ ، فَيَخْرُجُ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ حَتَّى يَمْتَنِعَ أَنْ يُحِيلَ بِخَمْسَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ عَلَى مَدِينَةٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ عَلَيْهِ كَمَا تُؤْهِمُ ، وَكَذَا لَا يُحِيلُ بِخَمْسَةٍ مُحَمَدِيَّةٍ عَلَى مِثْلِهَا يَزِيدِيَّةٍ وَلَا عَكْسُهُ وَيَلْزَمُ مِنَ التَّسَاوِي فِي الصَّفَةِ التَّسَاوِي فِي الْجِنْسِ فَلَا حَاجَةَ لَزِيَادَتِهِ " (١)

(١) * الشرح والتعليق : يشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الدين الذي يحيل عليه في القدر والصفة ؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة ، فخرج بذلك من باب الرخصة إلى باب البيع ، وإذا خرج إلى باب البيع دخله بيع الدين بالدين ، بناء على ذلك لا تصح حوالة بعشرة على أكثر منها ، أي على أن يأخذ المحال من المحال عليه خمسة عشر ؛ لأن هذا ربا.....

* اعتراض على هذا التعليق المطلق : قال ابن عرفة الدسوقي : ذكر هذا التعليق على إطلاقه لا يتم إذا كان الدين المحال به ثمن بيع ، إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا ، فالأولى أن يعطل : بأنه بيع دين بدين في غير مورد الرخصة ، وصورة الاعتراض : أن يكون " لمحمد " عند " علي " مبلغ ٥٠٠ ج خمسمائة جنيه ثمن ثلاجة لم يدفعها " علي " عند عقد البيع فيحيل " علي محمدا " على " أحمد " بمبلغ ٥٢٠ ج جنيه ، لمحمد عند أحمد ، فهذا جائز ؛ لأن محمدا ما أخر ثمن الثلاجة ليأخذ ٥٢٠ جنيه ، ولم يخطر في باله ذلك ولم يشترط على " علي " ذلك ولكنه فعل ما مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم : " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى " رواه البخاري.

* وبناء على ما سبق: لا تصح الحوالة بعشرة للمحال عند المحيل على خمسة يأخذها المحال من المحال عليه هي كل ما للمحيل عند المحال عليه حيث قد انتفع المحيل بباقي

الحوالة بالأعلى على الأدنى

يقول المصنف : " (وَفِي) جَوَازِ (تَحْوِيلِهِ) بِالْأَعْلَى (عَلَى الْأَدْنَى) صِفَةً أَوْ قَدْرًا وَمَنْعِهِ (تَرَدُّدٌ) عِلَلُ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ ، وَالْمَنْعَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُلِ

ما كان للمحال عليه ، وهي بذلك تخرج عن المعروف الذي هو أصلها ؛ إذ أن من فعل معروفا لا يراعي منفعة دنيوية من ورائه.

فالحوالة إنما تجوز إذا كانت على وجه المعروف ، فإذا دخلها وجه من وجوه المكايسة والمغالبة رجعت إلى الأصل فلم تجز [حاشية الرهوني / على شرح الزرقاني ٥ / ٣٩٢] ، ثم إن الفقهاء قد صرحوا بأن الغرر في الحوالة مغتفر لتصريحهم بأنه لا يشترط فيها الكشف عن ذمة المحال عليه ، مع أن جهل ذلك يؤدي إلى الغرر قطعا ، فقد نقل اللخمي عن المازري ما نصه : " أنه لا يلزم عند الإمام مالك الكشف عن ذمة المحال عليه ، هل هو غني أم فقير ؟ بخلاف مشتري الدين ، فإنه لا يجوز إلا أن يكون من عليه الدين حاضرا ومقرا ، يعرف غناه من عدمه ، وفرق المازري بينهما : بأن الدين المشتري يختلف مقدار عوضه باختلاف حال المدين من فقر أو غنى ، والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا ، فإذا لم يعلم حال المدين صار مشتريا لمجهول والحوالة ليست بيعا على أحد الطرفين عندنا ، بل طريقها المعروف [حاشية الرهوني / على شرح الزرقاني ٥ / ٣٩٢]

* **ونلاحظ:** أنه ليس المراد من التساوي أن يتساوى ما للمحيل عند المحال عليه لما للمحال عند المحيل ، حتى لا يمتنع أن يحيل بخمسة عليه للمحال على خمسة من عشرة له عند المحال عليه أو يكون له عند المحال عليه خمسة وللمحال عشرة على المحيل فيحيله بخمسة منها على المحال عليه.

* **والتساوي في الصفة :** فلا يحيل بخمسة دنانير محمية له على المحال عليه بخمسة يزيدية للمحال على المحيل ؛ لأنه ربا ؛ إذ أنه سلف بزيادة حيث يختلف وزن كل منهما عن الآخر ، وكذلك التساوي في الجنس : فلا يحيل بعشرة دنانير عليه للمحال بمائة درهم للمحيل عند المحال عليه ؛ لأنه ربا ، وهو ما يسمى بالصرف المؤخر المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ فَمُرَادُهُ بِالْأَدْنَى مَا يَشْمَلُ الْأَقْلَّ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ فَكَانَ الْأَوَّلَى
الِإِقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ " وَتَسَاوِي إلخ " (١)

(١) معنى بعض المفردات : قول العلامة خليل : " تردد " هذا من مصطلحات المذهب
استعمله بمعنى الاختلاف والتحير وجاء على عدة أوجه : الوجه الأول: تردد المتأخرين
(من أول ابن أبي زيد القيرواني ت ٣٨٦ هـ) في النقل عن المتقدمين، ولذلك ثلاث صور:
الأولى : أن ينقل أحد المتأخرين أو بعضهم حكما لواقعة معينة في باب ، وينقل آخرون
حكما آخر لنفس الواقعة في باب آخر .

الثانية : أن ينقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم نازلة معينة وينقل آخرون اختلافهم في
حكم هذه النازلة ؛ ويعود ذلك لأمرين:

١ - إما أن يكون للإمام في المسألة قولان ٢ - أو اختلافهم في فهم كلام الإمام ، فينسب
إليه ما فهمه من كلامه

الثالثة: أن ينقل بعضهم حكما وينقل الآخر خلافاً.

والوجه الأول: هو الغالب ، الوجه الثاني : تردد المتأخرين في استنباط الحكم نفسه ، وذلك
لعدم نص المتقدمين على هذا الحكم.

الوجه الثالث : يستعمل لفظ التردد بشأن الشخص نفسه كأن يستتبط حكما ؛ ويكون متحيرا
فيه ؛ وذلك مثل ما جاء في مصارف الزكاة قوله : «وفي غارم يستغني تردد» يقول الشيخ
عليش: « للخي وحده ونصه : " وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه
إشكال ، ولو قيل تنزع منه لكان وجهاً فالأولى واختار نزاعها من غارم استغنى "

الوجه الرابع : استعمله إذا كثر الخلاف بين المتقدمين وتشعبت الطرق، ومثال ذلك قوله:
«ففي الاكتفاء بالتذكية الأولى تردد» قال الشيخ عليش: «(تردد) للمتأخرين في النقل عن
المتقدمين بطرق كثيرة » ، وقد يأتي بلفظ غير التردد في موضع التردد كالنظر

الشرح والتعليق : أولا : المراد بالأدنى هنا ما يشمل : الأدنى في الأوصاف، والقلة، أي
العدد ؛ حيث إن الشأن عند ما يستعمل كلمة الأدنى فيراد بها : في الأوصاف فبين مراده
هنا من أنها تشمل الأدنى في الذات كذلك ، أي الأقل عددا.

ثانيا : التحول بالأدنى على الأعلى ، أو الأكثر يمنع قولاً واحداً لأنه ربا [شرح الخرشي
على مختصر خليل ٤ / ٢٣٥] .

* ولكن هل يجوز التحول بالأعلى على الأدنى ؟

للإجابة على هذا التساؤل تردد فقهاء المذهب على رأيين:

الرأي الأول : ذهب إليه ابن رشد ، وعياض إلى المنع من ذلك، وعلا هذا بأن الحوالة بيع ، والحوالة بالأعلى على الأدنى سوف تؤدي إلى التفاضل بين العينين ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه إن كان الدينان ذهبا فيشترط فيهما التماثل ، وأن يكونا يدا بيد ، وهذا غير موجود هنا ، وإن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلن يكون يدا بيد وهذا ممنوع شرعا ؛ لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بَيْدٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

الرأي الثاني : ذهب إليه اللخمي والمازري والمتيطي ، فقالوا بجواز ذلك ، أي الحوالة بالأعلى على الأدنى ، وعللوا هذا : بأن الحوالة معروف ؛ لأنها عقد إرفاق يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.

وسبب الخلاف هو : هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين ؟ أم هي عقد مستقل بنفسه قصد به الإرفاق والتيسير على الناس ؟

* **والمختار من الرأيين هو :** الأول حيث إنه المذهب ، ولهذا كان الأولى بالمصنف خليل أن يكتفي بقوله سابقا " وتساوي الدينين " [الشرح الكبير ، بحاشية الدسوقي ٣ / ٣٢٧ ، مواهب الجليل للحطاب ٥ / ١٩] .

ألا يكون المحال به وعليه طعاما من بيع أو أحدهما:

يقول المصنف : " (وَأَنْ لَا يَكُونَ) أَيِ الدَّيْنَانِ الْمُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ (طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ) أَيِ سَلَمٍ ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ أَوْ اخْتَلَفَتْ ، وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضٍ ، فَتَجُوزُ إِذَا حَلَّ الْمُحَالُ بِهِ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ إِلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ فَاشْتَرَطَ حُلُولَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَيْضًا ابْنُ عَرَفَةَ الصَّقَلِيُّ : وَقَوْلُهُمْ أَصَوَّبُ ؛ فَلِذَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنَّفُ هُنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ ، وَأَنَّ الْمَذْهَبَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنَّفُ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ قَالَ : وَجَارَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلَّا فِي مُطْلَقِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ " (١)

(١) أولا : لماذا لم يقل : " طعامين " ؟ لأن طعاما مصدر مؤكد والمصدر اسم معنى يدل على حدث مجرد ، غير مقيد بزمان ولا بمكان ، ولا هيئة حدوثه أو مرات حدوثه ، ولا يدل على من أحدثه أو اتصف به ، ولا على من وقع الحدث عليه فهو يدل على معنى ذهني مطلق من كل القيود والعلاقات والمصدر المؤكّد لفعله هو (المطلق) حقاً ، فلا وجه لتثنيته أو جمعه.

الشرح والتعليق : يشير المصنف بهذا إلى الشرط الأخير من شروط صحة الحوالة ، وهو يحتوي على صورتين الصورة الأولى وهي : ألا يكون الدينان طعاما من بيع لأنه لا يصح أن يقبضه إلا صاحبه ؛ لما يلزم عليه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وهو منهي عنه ، وتوضيح ذلك أنه يجب أن لا يكون كل من المحال به والدين المحال عليه طعاما من بيع ، أي سلم ؛ لأنه لو كان كذلك فسوف تدخله العلة المحرمة وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، وهو لا يجوز، كأن يكون للمحال (المسلم) عند المحيل (المسلم إليه) عشرة أرادب من القمح على سبيل السلم ، فيحيله على المحال عليه الذي هو مدين للمحيل بعشرة أرادب من قمح كذلك.

ودليل النهي عن ذلك : ١ - ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ».

٢ - وما رواه مسلم أيضا بسنده عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ».

٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرَّبَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : « أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى » ، قَالَ : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا» ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ، [والصكاك : جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك للإنسان قبل أن يقبضه].

ففي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منفولا أو نقدا أو غيره وقال عثمان النبتي : يجوز في كل مبيع ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء إلا العقار ، وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون ، وقال آخرون : لا يجوز في المكمل والمؤزور ويجوز فيما سواهما ، أما مذهب عثمان النبتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الاكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه ، قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم.

* وما هي علة المنع من هذا ؟ قيل: منع هذا تعبدا ، أي لا يعطل المنع ، وقيل: معطل بأن غرض الشرع سهولة الوصول إلى الطعام ومنع احتكار أقوات الناس من فئة قليلة ، وفي هذا من الضرر ما فيه فمنع هذا ؛ ليتوصل إليه القوي والضعيف ، ولو جاز بيعه قبل قبضه فلربما أخفي بإمكان شرائه من مالكة وبيعه خفية ، فلم يتوصل إليه الفقير ، ولأجل نفع الحمال والكيال .

* الصورة الثانية : أن يكون أحد الدينين طعاما من بيع والاخر طعاما من قرض ، وهذه الصورة اختلف فيها فقهاء المذهب على النحو التالي :

الرأي الأول : وقال به جميع الأصحاب عدا ابن القاسم : أن الحوالة جائزة في هذه الصورة إذا حل المحال به فقط - وهي العشرة أرادب من بيع أي سلم - لأنه طعام لم يبيع قبل قبضه

واعترض ابن عاشر على هذا (وابن عاشر : هو أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر ٩٩٠ - ١٠٤٠ هـ يعد من أبرز علماء المذهب المالكي) بقوله : علة المنع السابقة وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه موجودة في هذه الصورة فما وجه الجواز ؟
وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن قضاء القرض بطعام البيع - السلم - جائز ، وصورتها : أن المحيل مدين للمحال بعشرة أرداد من قمح على سبيل القرض أي السلف والمحال عليه مدين للمحيل بعشرة أرداد من قمح على سبيل السلم أي أن المحيل عجل للمحال عليه ثمن عشرة أرداد من قمح يأخذها منه عند الحصاد قمحا ، فتصح الحوالة بالعشرة قرضا إذا حل أجله على العشرة من سلم الذي لم يحل بعد.

* **تعليق** : هذه الإجابة ظاهرة وواضحة فيما إذا كان المحال به طعام القرض والمحال عليه طعام السلم - البيع - ولكن توقف ابن عاشر في الصور العكسية ، وهي أن يكون المحال به طعام البيع - السلم والمحال عليه طعام القرض ، فإن علية المنع وهي بيع طعام المعاوضة قبل قبضه موجودة هنا تحقيقا [تعليق العلامة عليش / حاشية الدسوقي ٣ / ٣٢٦ ، شرح الخرشي ٤ / ٢٣٥ ، شرح الزرقاني ٦ / ١٩].

الرأي الثاني : وقال ابن القاسم لا بد من حلول المحال عليه أيضا ، وصوب البعض الرأي الأول ، أي يكفي حلول المحال به فقط ، وقال الدردير : كلا القولين ضعيف ، والمذهب قول ابن رشد : بالمنع مطلقا سواء كان المحال به ، والمحال عليه كلا منهما من بيع ، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض ، وذلك لأنه ذكر سابقا في باب البيع قوله : " وجاز لمشتري وموهوب شيئا البيع قبل القبض من البائع والواهب إلا مطلق طعام المعاوضة أي الذي في مقابلة شيء ، وأراد بمطلقه ربويا كقمح ، أو لا كتفاح فلا يجوز بيعه قبل قبضه ، ولو كان طعام المعاوضة كرزق قاض وإمام مسجد ، ومؤذن ، وجندي ، وكاتب ، مما جعل لهم في بيت المال ، كعالم جعل له في نظير التعليم ، ومحل المنع ؛ حيث أخذ أي اشتري بكيل ، أو وزن ، أو عدد لا جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه ؛ لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد ، فهو مقبوض حكما ، فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض.

أحكام الحوالة

الفرق بين الغرر في الحوالة والغرر في البيع

يقول المصنف : " لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الشُّرُوطِ السَّتَّةِ أَخْرَجَ مِنْهَا قَوْلَهُ (لَا كَشْفُهُ) أَيَّ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ يَكْشِفَ الْمُحَالُ (عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَغْنَى هُوَ أَمْ فَقِيرٌ ، بَلْ تَصِحُّ مَعَ عَدَمِ الْكَشْفِ عَلَى الْمَذْهَبِ " (١)

(١) الشرح والتعليق : عقد الحوالة من باب المعروف والعقود المبنية على المعروف يتسامح فيها ويغتفر ما لا يتسامح ولا يغتفر في غيرها، ولهذا جاز فيها الغرر (والغرر هو : ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا ؟) بخلاف بيع الدين فإنه يشترط فيه العلم بحال ذمة المدين ، وإلا كان غررا ، فقد قال المازري : " شرط صحة بيع الدين : علم حال ذمة المدين ، وإلا كان غررا ، بخلاف الحوالة فإغتر في بيعها الغرر ، ولهذا اشترط حضور المدين في بيع الدين بالدين ليعلم حاله ، من فقر أو غنى ؛ إذ لا بد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين باختلاف حال ذمة المدين من فقر ، أو غنى ، والبيع لا يصح ان يكون مجهولا وبيع الدين بالدين هو ما يعبر عنه بـ (بيع الكالئ بالكالئ) من الكلاءة بكسر الكاف ، أي الحفظ .

واعترض على هذا : بأن الدين مكلوء لا كالئ ، والكالئ إنما هو صاحبه لأنه الذي يحفظ الدين.

وأجيب عن هذا : بأن هذا مجاز في إسناد معنى الفعل لملايسه ، فحق الكلاءة أن تسند للشخص بأن يقال : كالئ صاحبه ، فأُسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه ، أو أن كالئ بمعنى مكلوء ، فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة اللزوم ؛ لأنه يلزم من الكالئ المكلوء وعكسه.

وصورة بيع الدين بالدين : أن يشتري زيد من الناس شيئا بثمن مؤجل فإذا حل أجل السداد لم يجد زيد ما يسدد به الثمن فيقول لعمره اشتريه مني إلى أجل بزيادة شيء من غير قبض ، أو هو : بيع ما على مدينك (المحال هنا يبيع ما له عند المحيل) بدين في ذمة رجل ثالث فبيعه بمعين حال ، أو بمعين يتأخر قبضه ، أو بمنافع معين فلا يمنع، ولكن بشروط وهي : ١ - أن يكون المدين حيا ٢ - أن يقر المدين بالدين ، فإذا لم يقر بالدين فلا يصح بيع الدين ، ولو كان الدين ثابتا بالبينة ؛ لأنه من بيع ما فيه خصومة ٣ - تعجيل

الثلث حقيقة ، أو حكما ، كبيعه بمنافع معين يتأخر قبضها ؛ لأن قبض الأوائل قبض للأواخر ، كأن يسكنه دارا شهرا ٤ - أن يكون الثمن من غير جنس الدين ، أو من جنسه في غير العين واتحدا قدرا وصفة ، لا إن كان أقل لما فيه من دفع قليل في كثير ، وهو سلف بمنفعة ٥ - أن لا يكون الدين ذهبا بيع بفضة أو العكس ؛ لما في ذلك من الصرف المؤخر المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " ٦ - ألا يكون الدين طعام معاوضة ، وإلا لزم منه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ، وقد ورد النهي عنه من الشارع سابقا ٧ - أن يكون المدين حاضرا ٨ - أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام ٩ - ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة.

تنبيه

يقول المصنف : " تنبيه : من اشترى دينا ، أو وهب له وكان برهن ، أو حميل فإن الرهن والضمان لا ينتقل كلا منهما مع الدين المباع ، أو الموهوب إلا بشرط انتقالهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة .. وإن كره الحميل التحمل لمن ملكه ، وهذا بخلاف من ورث دينا برهن ، أو حميل ، فإنه يكون له ما به ، وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث^(١)

(١) الشرح والتعليق : النص واضح ، والفرق بينهما : من وجهين :

الأول : أن الهبة ، أو الشراء للدين لهما تعلق بالإرادة ، ومبناهما على الرضا ، وسند ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" أما الميراث فلا دخل للإنسان فيه.

الثاني : أن الوارث خليفة المورث فيما يثبت للمورث من حقوق ، والرهن والضمان حق من الحقوق وصورة الميراث الموثق برهن ، أو ضمان : أن يكون لوالد زيد من الناس دين على عمرو من الناس أخذ هذا الوالد من المدين رهنا ، أو ضامنا ، ثم مات هذا الوالد قبل سداد الدين ، فورث ابن هذا الدائن هذا الدين فيرثه بما فيه من وثيقة الرهن ، أو الضامن.

انتقال الدين المحال به بمجرد الحوالة

يقول المصنف : " (وَيَتَحَوَّلُ) بِمَجَرَّدِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ (حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَدَّ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَقُّ بَعْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ ، وَأَمَّا جَعْدُهُ قَبْلَهَا وَلَا بَيِّنَةٌ ، فَلَا تَصِحُّ ؛ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ، بِخِلَافِ الْفَلَسِ حِينَ الْحَوَالَةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا بَلْ يَتَحَوَّلُ الْحَقُّ مَعَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بِإِفْلَاسِهِ) أَيْ إِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (فَقَطُّ) أَيْ دُونَ الْمُحَالِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الظَّنَّ الْقَوِيَّ كَالْعِلْمِ ، وَمِثْلُ عِلْمِهِ بِإِفْلَاسِهِ عِلْمُهُ بِلَدِّهِ أَوْ عَدَمِهِ (وَحَلَفَ) الْمُحِيلُ (عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ نَفْيِ الْعِلْمِ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُحَالُ الْعِلْمَ (إِنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ) أَيْ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَخْلِفْ وَإِنْ اتَّهَمَهُ الْمُحَالُ فَقَوْلُهُ : " ظَنْ " بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ^(١)

(١) الشرح والتعليق : لغويات النص : التفليس : من أفلس الرجل ، إذا لم يبق له مال ، يراد به ، أنه صار إلى حال ، يقال فيها : ليس معه فلس (والفلس عملة يتعامل بها مسكوكة من غير الذهب والفضة ، وتقدر بسدس درهم ، وهي تساوي اليوم جزءا من ألف من الدينار في العراق وغيره) فيقال أفلس الرجل : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ، وقد فلسه الحاكم تفليسا : نادى عليه أنه أفلس ، والفلس شرعا ، له معنيان ، عام ، وخاص والفلس بمعناه العام : قيام الغرماء على ذي دين حل ليس له ما يفي به ، فلهم سجنه ، ومنعه من البيع والشراء والأخذ والعطاء والفلس بمعناه الخاص هو : حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخُلْعِ مَا بِيَدِهِ لِغُرْمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ وَقَاءِ مَا عَلَيْهِ ، وَيَتَحَوَّلُ بِمَجَرَّدِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَدَّ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَقُّ بَعْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ ، ما دام لم يشترط المحال يسار المحال عليه، وبناء على هذا لا يجوز للمحال الرجوع على المحيل أبدا ، أي سواء أمكنه الاستبفاء ، أو تعذر له لمطل ، أو فلس ، أو غير ذلك ، وهذا ما قاله الليث بن سعد ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة ، ووافق هؤلاء كلهم

الإمام أحمد إلا فبي مسألة الفلس فقد نقل عنه : انه إذا أفلس المحال عليه ، ولم يعلم المحال بذلك ، فله الرجوع على المحيل إلا إذا علم ورضي فلا يجوز له الرجوع ولكن ما الحكم : لو اشترط المحال بسار المحال عليه فظهر بخلاف ذلك؟ في هذا رأيان :

الأول منهما : ومضمونه : انه إن شرط المحال على المحيل أنه إن أفلس المحال عليه أي وجده مفلسا رجع على المحيل فله شرطه ، قال بهذا سحنون نقلا عن المغيرة ، ونقله الباجي كأنه المذهب ، وقال ابن رشد : هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا
ودليل هذا الرأي : أ - من السنة ، قوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " رواه الترمذي وصححه وأبو داود بلفظ " المؤمنون .. " فهذا شرط يجب الوفاء به ب - ومن المعقول : أن هذا شرط فيه مصلحة العقد ، وهو في عقد معاوضة ، فكان كشرط صفة في المبيع ، فإن بأن معسرا فله الرجوع على المحيل لفوات شرطه وتخلفه.
الرأي الثاني : أن هذا الشرط لا يعمل به ، بل ويفسد العقد عند المالكية (وقيل : الشرط فقط) وأصل المذهب في الشرط المناقض لمقتضى العقد أنه يفسده ، وبناء على ذلك - أي على فساد الشرط - ، فليس له الرجوع ؛ لأنه مقصر بتركه الفحص والاحتياط لماله وما الحكم إذا جحد المحال عليه الحق ، والحال ألا بينة للمحيل بحقه على المحال عليه الجاحد ؟

والجواب : أن جحد المحال عليه الحق والحال ألا بينة للمحيل بحقه على المحال عليه الجاحد ، وكان ذلك قبْلَ الحوالة وَلَا بَيِّنَةٌ للمحيل بحقه على المحال عليه الجاحد فَلَا تَصِحُّ الحوالة لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ؛ لأن المحال عليه لم يصدق على دينه.

فلس المحال عليه

أما فلس المحال عليه حين الحوالة فلا يمنع منها بل يتحول الحق مع إفلاس المحال عليه بشرط أن يكون المحال عالماً بإفلاس المحال عليه * أما إذا علم المحيل وحده فقط بإفلاس المحال عليه أي دون المحال فله الرجوع على المحيل ؛ ويثبت علم المحيل بإفلاس المحال عليه إما ببينة ، أو بإقراره بذلك ؛ لأنه عرّه ، والظاهر أن الظن القوي كالعلم ، ومثل علمه بإفلاسه علمه بلده أو عدمه ، أو أنه سيئ القضاء وهناك قيد آخر : ألا يكتب الموثق في عقد الحوالة : بعد معرفة المحال ملاء المحال عليه وموضعه ، فإذا كتب الموثق هذا فلا رجوع للمحال بأي وجه على المحيل (حاشية العدوي / على شرح الخرشي ج ٤ / ٢٣٦) وحلف المحيل على نفي العلم بإفلاس المحال عليه إذا ادعى عليه المحال العلم إن ظن بالمحيل العلم أي إن كان مثله يظن به ذلك وإلا لم يخلف وإن اتهمه المحال فقله ظن بالبناء للمجهول .

* ولكن ما الحكم إذا علم المحيل بإفلاس المحال عليه وشك المحال في إفلاس المحال عليه ؟ فإن شك المحال في إفلاس المحال عليه مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح والشامل ، وهو المعتمد : أن للمحال الرجوع على المحيل تقديماً لما أثبتته العلم على الشك ؛ لأن اليقين لا يزال بالشك ، وهذا هو الذي ذهب إليه اللخمي وابن عرفة * قال الخرشي : لا رجوع للمحال على المحيل في هذه الحالة ، وإن جهلا معا ؟ قيل : لا رجوع على المحيل ؛ لأن المحيل ليس منه شيء والمحال هو المقصربعدم الشرط ، أو بعدم الفحص عن ذمة المحال عليه .

* سؤال : ما الحكم إذا ادعى المحال على المحيل أنه كان يعلم بإفلاس المحال عليه ؟ إذا ادعى المحال على المحيل أنه كان يعلم بإفلاس المحال

عليه حلف المحيل على نفي العلم بإفلاس المحال عليه وبرئ من المطالبة بشرط : أن يكون مثله يظن به أنه يتهم بالعلم بإفلاس المحال عليه ، كأن يكون المحال عليه قريبا ، أو مخالطا للمحيل ولا يخفى عليه شأنه وحاله ، فإذا لم يظن به ذلك لم يحلف وإن اتهمه المحال.

* سؤال : ما نوع هذه اليمين ؟ هذه اليمين التي يحلفها المحيل (المدعى عليه بالعلم بإفلاس المحال عليه) يمين اتهام يبرأ بها الحالف بمجرد الحلف ، فإذا نكل أي امتنع منها غرم الحق المدعى به ، ولا ترد اليمين على المدعي ، بمعنى أنه إذا امتنع المحيل - المدعى عليه هنا - من اليمين رجع المحال بحقه عليه مباشرة بخلاف يمين التحقيق - التي فيها : إذا امتنع المدعى عليه وهو هنا المحيل من الحلف فترد اليمين على المدعو هو هنا المحال - خالف في ذلك الخرشي : حيث يرى حلف المحال بعد امتناع المحيل من اليمين ، حيث قال : " وإن نكل حلف المحتال ويرجع بدينه على المحيل " واعترض عليه العدوي (حاشية العدوي / على شرح الخرشي ج ٤ / ٢٣٦) بما ذكرنا من أنها يمين اتهام لا تحقيق ، ودليل هذا ، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع " ووجه الاستدلال منه : أنه لو أحيل على مفلس وكان حقه نائيا - أي بعيدا - عن المحيل بأن كان المحيل معدما ، فهل كان يزداد بذلك إلا خيرا إن أيسر المفلس أي المحال عليه ، وإلا فحقه حيث كان عند المحيل المعدم.

فروع فقهية على ما سبق

يقول المصنف : " ثُمَّ فَرَعَ عَلَى قَوْلِهِ : وَيَتَحَوَّلُ ...إِلْخَ قَوْلُهُ (فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ لِسِلْعَةٍ شَخْصًا بِدَيْنٍ لَهُ كَانَ عَلَى الْبَائِعِ (عَلَى) (مُشْتَرٍ) لِتِلْكَ السِّلْعَةِ (بِالثَّمَنِ) أَيْ بِثَمَنِهَا (ثُمَّ رَدَّ) الْمَبِيعِ الْمَفْهُومَ مِنْ بَائِعٍ عَلَى بَائِعِهِ الْمُحِيلِ (بِعَيْبٍ) أَوْ فُسَادٍ (أَوْ اسْتَحَقَّ) الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ (لَمْ تَنْفَسِخْ) الْحَوَالَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ ، فَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي دَفْعُهُ لِلْمَحَالِ وَيَرْجَعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْمُحِيلِ (وَاخْتِيرَ خِلَافُهُ) أَيْ اخْتَارَ ابْنُ الْمَوَازِ وَغَيْرُهُ خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ بَفَسْخِ الْحَوَالَةِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ " (١)

(١) الشرح والتعليق : * أولا شرح معاني مفردات النص : قوله (أو استحق) الاستحقاق هو : رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله ، أو حرية . قوله : (واختير خلافه) مراد المالكية بهذا اللفظ : ما اختاره بعض الأئمة لدليل روجه به ، وقد يكون ذلك المختار هو المشهور ، أو خلافه ، قوله : (وعليه الأكثر) أي أنه مشهور .

الأحكام التي في النص : يوضح المصنف هنا حكم ما إذا أحال بائع لسلعة ما - لم يقبض هذا البائع ثمن السلعة بعد من المشتري - شخصا ما ، هذا الشخص دائن للبائع بمبلغ من المال فأحاله البائع على مشتري تلك السلعة بثمن هذه السلعة ، ثم رد المبيع لعيب فيه ، أو فساده ، أو أن هذه السلعة استحققت من يد مشتريها ، فقد اختلف فقهاء المالكية في حكم الحوالة هنا على رأيين وهما :

الرأي الأول : قال به ابن القاسم وهو : عدم انفساخ الحوالة ، بناء على ذلك ، يلزم المشتري دفع ثمن ما اشتراه للمحال ، ثم يرجع بما دفعه على المحيل - البائع - ودليل هذا : أن الحوالة معروفة ، والثمن لازم للمشتري حين الحوالة ، وكأنه أي الرد بالعيب ابتداء بيع ، ولتعلق الحق في الحوالة بشخص ثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن المحال فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين ، قياسا على ما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيب ، فإن تصرف البائع في الثمن لا يبطل ، ثم إن العبرة بحال ووقت عقد الحوالة فالعقد

صحيح لا يبطل [الشرح الكبير للدريير ج ٢ / ٣٢١ ، وقد نص على هذا في المدونة ،
المدونة الكبرى ج ٤ / ١٥٠ كتاب الحوالة ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد ج ١١ /
٣٥٧ ، كتاب الحوالة والكفالة]

الرأي الثاني : وهو ما اختاره ابن المواز ، وهو قول أشهب ، وعليه أكثر الفقهاء: أن الحوالة
تتفسخ ، وهذا هو المعتمد [الشرح الكبير للدريير ج ٢ / ٣٢١ ، شرح الخرشي ج ٤ /
٢٣٦ ، ومواهب الجليل ، للحطاب ج ٦ / ٩٠] ودليل هذا القول ، أنه لما رد المبيع بالعيب
، أو الفساد انفسخ البيع فصار كأن لم يكن ، فلا شيء في هذه الحالة على المشتري ،
فعلى ماذا يحيل البائع ؟ والحوالة فرع عن البيع ، فإذا بطل الأصل بطل الفرع المترتب
عليه.

مسألة : إذا أحال مشتر بالثمن الذي عليه البائع على مدين للمشتري ، ثم حصل الرد
بالعيب ، أو بالفساد ، أو حصل استحقاق للمبيع قبل قبض المحال - أي البائع - الثمن
، فإن الحوالة في هذه الحالة تبطل قطعاً ، وذلك لبطلان حق المحال - البائع - بالاستحقاق
، أو أحد سابقه * وذكر الخرشي الجزم بعدم البطلان وأن الحوالة صحيحة ، ولكن هذا
غير ظاهر ، بل ينبغي الجزم ببطلان الحوالة ؛ لبطلان حق المحال - البائع -
بالاستحقاق .

*** مسألة أخرى :** إذا وهب بائع لسلعة شخصاً ثمن هذه السلعة أو تصدق به عليه ، ثم
أحاله على المشتري - أي ثم أحال الواهب ، أو المتصدق الموهوب له ، أو المتصدق
عليه على المشتري - ثم ردت السلعة بعيب ، أو استحققت ، أو ردت لفساد فما حكم هذه
الهبة ، أو الصدقة المحال بها ؟ * في هذا رأيان

الأول منهما : فرق بين قبض الموهوب له والمتصدق عليه وبين عدم قبضه ، فقال :
تبطل الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له ، وإن كان قبضها لم يتبع الموهوب له بها ولا الواهب ،
ويضيع ذلك على المشتري وهذا قول ابن القاسم ، نقله عنه اللخمي في التوضيح ، [
وحاشية الدسوقي / الشرح الكبير ج ٣ / ٣٢٩] .

ولعل حجة هذا الرأي : أن الموهوب له لا يتبع بها ؛ لأن الهبة تتم بالقبض عندنا ، ولا يتبع الواهب ؛ لأنه لحظة الهبة أحال بها والعقد صحيح

الرأي الثاني : تبطل الحوالة هنا إذا رد المبيع ، أو استحق ؛ لأن الغيب كشف ، واطهر أنه وهب ، أو تصدق بما لم يملك ، وهذا لا يجوز * **وبناء على هذا:** إن كان الموهوب له قبض الثمن الموهوب له أخذه منه المشتري، أي استرده منه وهذا قول اشهب.

الاختلاف في الحوالة

اختلاف المحيل والمحال

١ - في نفي دين المحال عليه

يقول المصنف : " (وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ) بِبَيِّنٍ أَنَّهُ أَحَالَ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ (إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ) الْمُحَالُ (نَفْيَ الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ) إِذَا مَاتَ أَوْ غَابَ غَيْبَةً انْقِطَاعٍ فَلَوْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ حَاضِرًا فَهُوَ مَا قَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحَالِ إلخ " (١)

(١) الشرح والتعليق : قوله : " نفي الدين للمحال عليه " اللام في " للمحال عليه " بمعنى على متعلقة بالدين، أو بمعنى " عن " متعلقة بـ " نفي " والمعنى على الأول : - أي أن اللام بمعنى على - إن ادعى المحال نفي الدين على المحال عليه ، والمعنى على الثاني : - أي أن اللام بمعنى في - إن ادعى عليه نفي الدين عن المحال عليه .

ومعنى النص : هنا حالتان :

الحالة الأولى : أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه ، أو غيبته غيبة انقطاع (والغيبة نوعان : ١ - غيبة انقطاع ، وهي : على معنى الاضطراب والغلبة كالأسير . ٢ - وغيبة ارتجاع ، وهي : التي على معنى الترفه والاختيار ، وفيها قد تعلم حياته ، أو تجهل وهي كمن خرج للتجارة ، أو لطلب حاجة) فقال المحال للمحيل : أحللتني على غير ذي دين ، فأنا أرجع عليك بديني . وقال المحيل : بل أحللتك على ذي دين في ذمته ، وقد برئت ذمتي ، فلا رجوع لك علي . فلن يكون القول ؟ القول قول المحيل بيمين ، ولا يصدق المحال في دعواه (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣ / ٣٢١ ، وهذا قول الإمام مالك في المدونة ، المدونة الكبرى ج ٤ / ١٤٨ ، كتاب الحوالة) فإن كان المحال عليه حاضرا وذكر ما يوافق قول أحدهما ، فهل يعتبر كالشاهد ، أم لا ؟ وهل يجري في الملى والمعسر ؟ فإن قيل : قد تقدم : أنه لا بد من حضور المحال عليه وإقراره ، وإذا حضر وأقر فلا يتأتى تنازعهما في أن الحوالة وقعت على أصل الدين أم لا ؟

* والجواب : أن هذا الكلام مبني على عدم اشتراط الحضور (شرح الخرشي ج ٤ /

٢٣٧ شرح الزرقاني ج ٦ / ٢١)

* الحالة الثانية : أن يكون المحال عليه حاضرا ، أو غائبا ولكنها ليست غيبة انقطاع ، ففي هذه الحالة يتحول حق المحال بمجرد عقد الحوالة ويطبق عليه ما ذكره المصنف عند قوله : " ويتحول بمجرد عقد الحوالة حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَقَّ بَعْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ ... "

٢ - اختلاف المحيل والمحال في الصيغة

يقول المصنف : " (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِي دَعْوَاهُ وَكَالَةً) لِلْمَحَالِ عَلَى قَبْضِ مَالٍ مِنْ مَدِينِهِ (أَوْ سَلَفًا) مِنَ الْمُحِيلِ لِلْمَحَالِ وَيَرُدُّ لَهُ بَدَلُهُ مَعَ صُدُورِ لَفْظِ الْحَوَالَةِ بَيْنَهُمَا ، بَلْ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ مِنْ دِينِهِ أَحَالَهُ بِهِ تَغْلِيْبًا لِلْفَظِ الْحَوَالَةِ وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِأَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ يُشَبِّهُ أَنْ يُدَايِنَ الْمُحِيلَ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ وَكَالَةً ، وَخَرَجَ اللَّخْمِيُّ مَسْأَلَةَ السَّلَفِ عَلَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْقَوْلَ فِي دَعْوَى السَّلَفِ لِلْمُحِيلِ وَخَرَجَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْوَكَالَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ الْجَرِيُّ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَى أَعْلَمُ ^(١)

(١) الشرح والتعليق : معاني مفردات النص : قوله : " .. وكالة .. "
 الوكالة لغة : الحفظ ، والكفالة ، والضمان والتفويض ، يقال : وكلت أمري لفلان ، أي فوضته إليه
 والوكالة شرعا : نيابة في حق غير مشروطة بموته ، ولا إمارة أو : إقامة شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم مملوك قوله : " .. أو سلفا .. "
 السلف ، أو القرض هو في اللغة : القطع ، سمي المال المدفوع للمقترض قرضا ؛ لأنه قطعة من مال المقرض .
 وشرعا : دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة .

* شرح النص : أولا : صورة المسألة : أن يدعي المحيل أنه وكل المحال في أن يقبض له دينه من المحال عليه ، ويحضره له ، أو يقبضه من المحال عليه ، ويأخذه المحال سلفا على أن يرد مثله فقال المحال : بل أحلتني بدين لي عليك ، فلمن يكون القول ؟ لا يقبل قول المحيل في دعواه الوكالة في هذه المسألة فيما إذا تم العقد بصيغة الحوالة ولفظها ، بأن قال المحيل : إنما أحلتك لتقبضه لي على سبيل الوكالة ، أو على سبيل أنه سلف ، وقرض مني لك ترد لي بدله ، وقال المحال : إنما قبضته من الدين الذي لي عليك ، فالقول في ذلك قول المحال بيمينه ؛ تغليباً لجانب الحوالة ، إن أشبه أن مثل هذا المحال يداين المحيل

، وإلا يشبهه كان القول قول المحيل في دعواه الوكالة بيمينه ، وهذا قول عبد الملك بن الماجشون ، ولكن القيد الذي ذكره ، وهو : " إن أشبه أن مثل هذا المحال يداين المحيل " محله دعوى الوكالة ، دون مسألة السلف ، ولكن اللخمي هو الذي خرج مسألة السلف على الوكالة . قال ابن الحاجب : " وَإِذَا جَرَى لَفْظُ الْحَوَالَةِ وَتَنَازَعَا فَقَالَ الْمُحِيلُ : وَكَالَةً ، أَوْ سَلَفٌ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَصَحِّ " .

يعني : إذا صدر لفظ الحوالة بين رجلين ، فقال له مثلاً : أحلتك على فلان ، فقبضه المحال ، فقال المحيل : إنما أردت بذلك التوكيل أو التسلف ، وقال المحال : بل قبضته من دين لي عليك ، فالأصح أنه لا يقبل قول المحيل تغليباً للفظ الحوالة ، وقيل : القول قوله ؛ لأنه لا تدرى إرادة نفسه ولا يعلم ذلك إلا من قوله ، وأراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة ، قال فيمن تحول بدين له على رجل ، فقال المحيل : ادفعه لي لأنني إنما وكلتك في قبضه وتسليمه إليّ ، وقال المحال : بل كنت استحققه عليك ديناً قبل الحوالة ، فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل سبب حلف وسقط عنه قول المحيل ، وإن لم يشبهه فإنما هو وكيل ، ويحلف ما أدخله إلا وكيلاً .

اللخمي : وأرى أنه حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة مثل أن يكون هذا ممن يتصرف لصاحب الدين أو تكون عادته التوكيل على التقاضي ، وهذا ممن يتوكل في مثل هذا وغير الأصح هو قول ابن القاسم في العتبية في السلف في من أحال رجلاً بدين له على رجل : فقال المحيل : إنما أحلتك على دين لي ليكون ذلك سلفاً عندك ، وقال القابض : أخذته عن دين كان لي عليك ، وإحالتني إقرار منك بحقي أن القول قول المحيل وهو سلف .

اللخمي : بعد قول ابن الماجشون وابن القاسم والمسألتان سواء .

وخلاصة القول : أن مسألة الوكالة منصوص عليها عند ابن الماجشون ، مخرج عليها مسألة السلف عند اللخمي ، ومسألة السلف منصوص عليها عند ابن القاسم في العتبية مخرج عليها مسألة الوكالة .

فتحصل من هذا : أن كل مسألة فيها قول منصوص ، وخرج عليه آخر في الأخرى وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ (خليل) الْجَزْيُ عَلَيْهِ أَيُّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السَّلَفِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ جَارِيًا عَلَى الْمُنْصُوصِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ * وَأَقُول : إن المصنف التزم منهجه الذي وضعه للسفر عليه في هذا السفر العظيم من انه يتبع الراجح والأصح من الأقوال ، وفي مسألتنا هذه نجد أن قول ابن القاسم المنصوص عليه في السلف هو مقابل الأصح ؛ لهذا لم يتبعه المصنف خليل جرياً على منهجه .

السفتجة

وتطبيقا لمعايير الجودة المعمول بها في الجامعات المصرية وغيرها ؛ حيث إنه من بين توصيف المقررات بها : تنزيل ما يدرسه الطالب من كتب التراث على النوازل العصرية حتى ينمي في طلاب العلم الشرعي التقدير والاعتزاز بتراث الأمة الفقهي بناء على ذلك استعرض مسألة السفتجة.

والسفتجة هي : التطبيق المعاصر للحوالة : السفتجة بضم السين وفتحها ، وفتح التاء فارسيّ معرّب . قال في القاموس : السفتجة كَقَرْطَقَةٍ ، أن يعطي شخص مالا لآخر ، ولآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك ، فيستفيد أمن الطريق.

والسفتجة اصطلاحاً كما قال ابن عابدين : إقراض لسقوط خطر الطريق ، وفي الدسوقي : هي الكتاب الذي يرسله المقرض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده وهي المسماة بالبالوصة.

* هل السفتجة قرض أو حوالة : ؟ السفتجة تشبه الحوالة باعتبار أن المقرض يحيل المقرض إلى شخص ثالث ، فكأنه نقل دين المقرض من ذمته إلى ذمة المحال عليه ، والحوالة لا تخرج عن كونها نقل الدين من ذمة إلى ذمة.

لكن جمهور الفقهاء - المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية - اعتبروها من باب القرض ؛ لأنّ الكلام في القرض الذي يجزّ منفعة هل هو جائز أو غير جائز ، أمّا الحوالة فهي في دين ثبت في الذمة فعلا.

وقد ذكرها بعض فقهاء الحنفية كالحصكفي والمرغيناني في آخر باب الحوالة مع ذكرها في باب القرض أيضاً، وقال ابن الهمام والبايرتي : أورد القدوري هذه المسألة هنا لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة ، وقال الكرمانى : هي في معنى الحوالة ؛ لأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض وهذا ما قاله الحصكفي : قال : السفتجة : إقراض لسقوط خطر الطريق فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة - قال ابن عابدين وفي نظم الكنز لابن الفصيح : وكرّهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق ، قال شارحه المقدسي : لأنه يحيل صديقه عليه، أو من يكتب إليه .الحكم الإجمالي :القرض من القرب المندوب إليها وهو من باب المعروف ، شرع للتعاون بين الناس وتفريج كرب المحتاجين بما يبذله المقرض للمستقرض المحتاج ، وهو لا يطلب من وراء ذلك سوى الثواب من الله سبحانه وتعالى ، فإذا طلب المقرض من وراء إقراضه نفعاً خاصاً له من المستقرض فقد خرج بذلك عن موضوع القرض ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة ، ولذلك يحرم إذا كان يجلب نفعاً للمقرض وخاصةً إذا شرط ذلك في عقد القرض ، كأن يشترط المقرض زيادةً عما أقرض ، أو أجود منه ؛ لأن ذلك من باب الربا.

ومن القواعد المعروفة : أن كلّ قرض جرّ منفعةً فهو حرام . روى ذلك عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الصحابة والسلف . قال : حدثنا خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كلّ قرض جرّ منفعةً ، ومن الصور التي قد تجلب نفعاً للمقرض ما يسمّى بالسفتجة، وصورتها : أن يقرض شخص غيره - تاجراً أو غير تاجر(كبنك مثلاً) - في بلد ويطلب من

المستقرض أن يكتب له كتاباً يستوفى بموجبه بدل القرض في بلد آخر من شريك المقرض أو وكيله .

والنفع المتوقع هنا هو أن يستفيد المقرض دفع خطر الطريق ، إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع الطرق فيلجأ إلى هذه الحيلة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقع في الطريق والحكم في ذلك يختلف ، لأنه إما أن يكون الكتاب الذي يكتبه المستقرض لوكيله " وهو السفتجة " مشروطاً في عقد القرض أو غير مشروط . فإن كان ذلك مشروطاً في عقد القرض فهو حرام والعقد فاسد ؛ لأنه قرض جرّ نفعاً فيشبه الربا ؛ لأنّ المنفعة فضل لا يقابله عوض ، وهذا عند جمهور الفقهاء " الحنفية والشافعية وبعض فقهاء المالكية ورواية عن أحمد " وذكر ابن عبد البر أنّ مالكا كره العمل بالسفاتج بالدنانير والدراهم ولم يحرمها ، وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم ، وقد روي عن مالك أيضاً أنّه قال : لا بأس بذلك والأشهر عنه كراهيته لما استعمله الناس من أمر السفاتج . وفي رواية عن أحمد جوازها لكونها مصلحةً لهما جميعاً ، وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - فلم ير به بأساً ، وممن لم ير به بأساً : ابن سيرين والنخعي ، رواه كُله سعيد بن منصور .

وذكر القاضي من الحنابلة أنّ للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق ، والصحيح جوازه ؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما . والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرّة فيها بل

بمشروعيتها ، ولأنّ هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة.

غير أنّ المالكيّة استثنوا ما إذا عمّ الخوف جميع طرق المحلّ التي يذهب المقرض منها إليه، فإذا كان الخوف على النفس أو المال غالباً لخطر الطريق فلا حرمة في العمل بالسّفْتجة بل يندب ذلك تقديمًا لمصلحة حفظ النفس والمال على مضرة سلف جرّ نفعاً ، كما أنّه يجوز ذلك عندهم إذا كان فيه نفع للمقترض ، أو كان المتسلّف هو الذي طلب ذلك .

وإن كان المقترض هو الذي كتب السّفْتجة من غير شرط من المقرض بذلك جاز ذلك باتّفاق ؛ لأنّه من حسن القضاء ، وقد " استسلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم من رجل بكرةً فقدمت عليه إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضى الرّجل بكرة ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلّا خياراً رباعياً فقال : أعطه إيّاه ، إنّ خيار النّاس أحسنهم قضاء. صحيح الترمذي والحديث صحيح وصحيح مسلم برقم (١٦٠٠) * * وخيارا : أي مختارا

* * ورباعيا : وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة " ورخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن والنّخعي والشّعبيّ والزّهريّ ومكحول وقتادة وإسحاق

* والله أعلى وأعلم *

كتاب الضمان وأحكامه

كتاب الضمان وأحكامه

يقول المصنف : " (الضَّمانُ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ) قَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَّةٍ جِنْسٌ ، وَقَوْلُهُ أُخْرَى فَصْلٌ أَخْرَجَ بِهِ الْبَيْعَ وَالْحَوَالَةَ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِمَا شَغْلٌ بَلْ بَرَاءَةٌ ذِمَّةٌ ، وَقَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَّةٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ ، أَيُّ أَنْ يَشْغَلَ رَبُّ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ الْأُولَى ، وَأَرَادَ بِالذِمَّةِ الْجِنْسَ فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ ، وَأَرَادَ الشَّغْلَ بِالْحَقِّ بَلَا تَوَقُّفٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ بَعْدَ التَّوَقُّفِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ كَعَدَمِ إِيْتِيَانِ الْمَضْمُونِ فِي الْوَجْهِ أَوْ تَهْرِيْبِهِ أَوْ تَفْرِيطِ الضَّامِنِ فِي الطَّلَبِ فَقَدْ اشْتَمَلَ تَعْرِيفُهُ عَلَى أَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَلَّ فِي الْحَقِّ لِلْعَهْدِ أَيُّ الْحَقِّ الْأَوَّلُ فَخَرَجَ مَا لَوْ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ بَدَيْنٍ ثُمَّ بَاعَ أُخْرَى لِغَيْرِهِ بَدَيْنٍ ^(١)

(١) الضمان لغة : الحفظ ، ويسمى حمالة ، وكفالة ، وزعامة قال تعالى " قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " يوسف (٧٢) أي ضامن وكفيل ، والضمان في اللغة له سبعة أسماء : ١ - زعيم ٢ - كفيل ٣ - قبيل ٤ - أدين ٥ - حميل ٦ - صبير ٧ - ضامن (المقدمات الممهדות لابن رشد الجد ج ٢ / ١٣٥٣) وكلها موجودة في القرآن الكريم والسنة والآثار ، وفيما يحتج به من الأشعار فمثلا من القرآن : قال تعالى : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ " النحل (٩١) وقال تعالى : " أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا " الإسراء : ٩٢

وقال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ " الأعراف : ١٦٧ وقال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ " إبراهيم : ٧ ، فالزعيم من الزعامة ، وهي : السيادة ، فكأنه لما تكفل به صار عليه سيادة ، وحكم عليه ، والكفالة : من الكفيل ، وهو الكساء الذي يطوى حول سنام البعير ليحفظ به الراكب ، والكفيل حافظ لما التزمه ، والقبيل : من القبالة ، وهي القوة ، ومنه قوله : مالي بهذا الأمر قبل ، ولا طاقة ، والقبيل قوة في استيفاء الحق والأدين : من الأذانة ، بمعنى

الإيجاب ، وتوضحه الإيتان المذكورتان ، أي أوجب على نفسه المزيد للشاكر ، والعذاب للكافر *والحميل : وهو مشتق من الحمل ؛ لأن الضامن حمل والمضمون نقل ما كان عليه * والصبر : من الصبر ، وهو الثبات والحبس ، ومنه المصبورة ، وهي المحبوسة للرمي لأنه حبس نفسه لأداء الحق * أما الضمين : فهو من الضمن وهو الحرز ، وكل شيء أحرزته في شيء فقد ضمنته إياه (الذخيرة ، للقرافي ج ٧ / ٣٥٦ ، ٣٥٧)

والضمان شرعا : " التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه " **تعريف آخر ، الضمان :** " شغل ذمة أخرى بالحق " **شرح التعريف :** قوله " شغل ذمة ... " جنس في التعريف والجنس هو : لفظ كلي يطلق على أنواع مشتركين في صفات عامة مثل " الحيوان " فهو يطلق على كل الأحياء عدا النبات ، فشغل ذمة جنس شامل للمعرف - بفتح الراء المشددة - وهو الضمان والبيع والحوالة ؛ لأن في البيع شغل ذمة المشتري بالثمن ، وفي الحوالة شغل ذمة المحال عليه بحق المحال ، وقوله " أخرى " فصل ، والفصل هو : لفظ كلي ذاتي يميز أفراد النوع بصفات أساسية لا توجد في الأنواع الأخرى أي تفصلهم عن غيرهم من أنواع ، وبها يقوم الشيء ، مثلاً : فصل كلمة " الإنسان " أنه ناطق ، وبذلك يفصل عن باقي الحيوان فكلمة " أخرى " هنا فصل أخرج به البيع والحوالة ؛ لأن المراد بقوله " شغل ذمة أخرى " أي كما أن الأولى مشغولة أيضاً ، والحوالة ليست الذمة الأولى فيها مشغولة ؛ لأنها بمقتضى الحوالة برئت ، فالحوالة ليس فيها شغل ذمة ، بل براءة ذمة ، وقوله " شغل ذمة ... " من إضافة المصدر لمفعوله أي أن يشغل رب الدين ، أو الحق ذمة الضامن مع ذمة المدين والمراد من الذمة : الجنس ليشمل الواحد والمتعدد .

والذمة لغة : العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذم ، وتطلق على الأمان ، والكفالة ، والحق والحرمة ، وفي الحديث : " المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم " (نيل الأوطار للشوكاني ، ج ٧ / ٨ ، ٩) .

والذمة عند الفقهاء : معنى يصير به الإنسان أهلاً لوجوب الحق له ، أو عليه وجمعها ذمم ، وهذا تعريف لها بالوصف ، أما تعريفها بالذات فهي : نفس لها عهد ، فالإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء (التعريفات للجرجاني ص ٩٥)
* **والمراد من قوله " شغل " الشغل المطلق ، أي سواء توقف هذا الشغل على شيء آخر كعدم الإيتان بالمضمون في ضمان الوجه ، أو تهريبه ، أو تفريط الضامن في ضمان**

الطلب ، أو بلا توقف على شيء ، كضمان المال ، فإننا سوف نعرف أن لرب الحق : أن يطالب أيهما شاء ، وبهذا يشمل التعريف أنواع الضمان الثلاثة ، وهي : المال ، والطلب ، والوجه .

اعتراض : اعترض على هذا التعريف : بأن لفظ " الحق " يدخل فيه الحق البدني (الحدود) والحق المالي .

وأجيب عن هذا : بأن الحقوق البدنية خارجة من التعريف بقوله " شغل ذمة أخرى " والذمة لا تشغل بالحقوق البدنية

نوع " ال " في كلمة " الحق " ال في كلمة " الحق " للعهد ، أي الحق الأول - الحق الذي في الذمة الأولى - فال تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : العهد الثاني : الجنس ، الثالث : الاستغراق .

والتي للعهد تنقسم إلى قسمين : الأول : العهد الذكري ، مثل : اشتريت كتابا ، ثم بعت الكتاب ، فال في الكتاب للعهد الذكري ، أي الكتاب المذكور أولا وكما في قوله تعالى : " اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " النور (٣٥)

الثاني : العهد الذهني : مثل : حضر الطالب ، والحال أنك تخاطب إنسانا بينك وبينه عهد في طالب بعينه

أما " ال " التي لتعريف الجنس ، فمثالها : الرجل افضل من المرأة ، بشرط أن لا تريد رجلا بعينه ، ولا امرأة بعينها ، بل المقصود : أن جنس الرجل افضل من جنس المرأة .

أما " ال " التي لاستغراق الجنس ، فهي على قسمين : الأول : استغراق حقيقة الأفراد ، مثل قول الله تبارك وتعالى : " يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِخْلَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفاً " النساء (٢٨) أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف . **الثاني :** استغراق صفات الأفراد ، مثل : أنت الرجل ، أي الجامع الشامل لصفات الرجل وضابط كل منهما : أن الأولى : أي التي لاستغراق حقيقة الأفراد يصح وضع " كل " محلها على جهة الحقيقة ، أما الثانية : أي التي لاستغراق صفات الأفراد فتوضع " كل " محلها على سبيل المجاز لا الحقيقة

أنواع الضمان

الضمان ثلاثة أنواع : ضمان مال ، ضمان طلب ، وضمان وجه.

وضمان الطلب هو : ما تقوم به المصارف الآن تحت ما يسمى " بخطاب الضمان " الذي يصدره المصرف لعميله ، فإذا كان بدون أجره فهو جائز شرعا ، وإن كان بأجرة فهو محرم ، إلا إذا أخذ المصرف أجره مقابل تكاليف إصدار خطاب الضمان ، فإن ذلك جائز ، إذا كان بقدر تكلفة خطاب الضمان الفعلية ، أو أنقص منها.

ويستثنى من ذلك: إذا كان خطاب الضمان مغطى من قبل الشخص المدين ، و**خطاب الضمان المغطى هو :** أن يكون المدين قد أودع المال الذي ضمنه المصرف فيه في هذا المصرف ، فتكون حقيقة هذا الضمان : أنه ضمان من المودع عنده - بفتح الدال - بما يشبه الرهن ، وليس الضمان من المصرف ، فالمودع ضمن بإيداع هذا المال الذي يساوي المال المضمون في المصرف ، والمصرف وكيل عن هذا الشخص ، أو الشركة في إصدار هذا الضمان

* ويجوز للمصرف في هذه الحالة أخذ الأجرة عليه؛ لأن المصرف مجرد وكيل عن هذا المودع - بكسر الدال - في الضمان ، ويدخل في ضمان المال أيضا : **"الاعتماد المستندي"** وهو عبارة عن : تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب عميله المدين - المستورد - يلتزم بمقتضاه البنك بالوفاء للمصدر - الدائن - وغالبا يكون المصدر الدائن في بلد آخر بتسديد قيمة السلع المتفق عليها بين المستورد والمصدر عند شحن المصدر السلع إلى المستورد ، ثم يقوم المستورد بالتسديد للبنك جميع ما دفعه البنك للمصدر فحكمه هو نفس حكم خطاب الضمان على ما سبق تفصيله ، فإذا كان البنك يأخذ فوائد مقابل سداد قيمة هذه السلع فهو ربا محرم (شرح عمدة الفقه ، تعليق : الجبرين ج ٢ / ٩٠٠ - ٩٠٢ ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس ص ٦٤١)

* **وفي ضمان الوجه** - كأن يقول : أنا زعيم لك بوجه فلان - خلاف بين الإمامين مالك والشافعي ، فقال الإمام مالك : يلزمه لأن المقصود بالزعامة ، تنزيل الزعيم مقام الأصل (المدين) والمقصود من حضور الأصل (المدين) أداء المال ، فكذلك الزعيم وقال الإمام الشافعي : لا يلزمه ؛ لأنه غرر ؛ إذ لا يدري : هل يجده ، أم لا .

حكم ضمان المال

ضمان المال حكمه الاستحباب ؛ لأنه فعل معروف ، وتعاون بين المسلمين ؛ ولذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل في عشرة

دنانير (سنن أبي داود) وهذا هو الأصل في الضمان ، ولكن قد يعرض له الوجوب ، أو الحرمة ، فيكون الضمان واجبا ، كضمان الابن لوالده ، إذا تعامل الوالد بالدين في أمر مشروع ، واحتاج لضامن فيجب على الابن في هذه الحالة ضمان والده إذا كان والده غير ملد ، ولا مماطل في السداد ، ويكون الضمان محرما ، كضمان شخص يتداين بفائدة من البنك لا تعوه إلى الدين ضرورة ولا حاجة؛ لأن هذا ربا محرم ، ولأن في ضمان هذا الشخص إعانة على الإثم.

وهذا منهي عنه شرعا بنص القرآن الكريم قال تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " سورة المائدة (٢) وكضمان بجعل ، فإنه حرام ؛ حيث إن الضمان لا يكون إلا لله ، فقد قيل " ثلاثة لا تكون إلا لله القرض والضمان والجاه " ، ونظمها بعضهم بقوله:

القرض والضمان رفق الجاه ﴿٥﴾ تمنع أن ترى لغير الله (البهجة / شرح التحفة ، للتسولي ، ج ١ / ٩٦) ثم إنه ربما يسدد الضامن للدائن ، ثم يرجع الضامن على المدين بما سدده بالإضافة إلى هذه الأجرة ، فيكون من قبيل الربا المحرم.

(موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، للسالوس ، ص ٦٤٦ - ٦٥٦ ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي في هذا الموضوع)

دليل مشروعية الضمان

ثبتت مشروعية الضمان بالكتاب ، والسنة ، والإجماع والقياس
أما الكتاب ١ - فقوله تبارك وتعالى : " قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " سورة يوسف (٧٢)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة : أن مذهب المالكية : أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ ولا ناسخ هنا ، وهي كفالة بالمال

٢ - وقول بعقوب عليه السلام لأبنائه : " قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ " سورة يوسف (٦٦)

* **ووجه الاستدلال من الآية الكريمة** : أن هذه كفالة بالوجه (الذخيرة ، للقرافي ، ج ٧ / ٣٥٨).

* **أما السنة**: فأحاديث كثيرة نذكر منها : ١ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ بِمَيْتٍ فَسَأَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا :

نَعَمْ، دِينَارَانِ قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلِيَ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوَرَّثَهُ « رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ. »

٢ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، ولا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " ف قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال " ذاك أفضل أموالنا " ثم قال : " والعارية مؤداه ، والمنحة مردودة والدين مقضي ، والزعيم غارم " (ينظر : فتح الرحيم للشنقيطي ج ٢ / ١٥٢) ، وروى أحمد والنسائي وأبو داود

* فإن قيل : لماذا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على الميت الذي عليه دين لم

يؤده ؟

الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت الذي عليه دين ولم يترك وفاء له : في هذا تحريض للناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة من شغل ذممهم بحقوق

العباد

* أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعية الضمان من حيث الجملة ، وإن اختلف

الفقهاء في بعض الفروع

* أما القياس : فلأن الضمان باب معروف فيجوز قياسا على العارية ، والقرض ، وغيرهما

من أبواب المعروف ، ولأنه توثق بالحق ، فيجوز كالرهن (الذخيرة ، للقرافي ج ٧ / ٣٥٨) .

أركان الضمان

الركن الأول

الضامن

يقول المصنف : (وَصَحَّ) الضَّمانُ وَلَزِمَ (مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ) وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الَّذِي لَا حَجَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِيمَا ضَمِنَ فِيهِ فَدَخَلَ ضَمَانُ الزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ بِالثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي ، وَمَفْهُومٌ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ فِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَتَارَةٌ لَا يَصِحُّ كَالْوَقْعِ مِنْ سَفِيهِ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ ، وَتَارَةٌ يَصِحُّ وَلَا يُلْزَمُ كَالْوَقْعِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ مَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ وَمِنْ الْعَبْدِ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَمَثَلٌ لِأَهْلِ التَّبَرُّعِ بِقَوْلِهِ (كَمَكَاتِبِ وَمَأْدُونِ) لَهُ فِي التَّجَارَةِ (أَذْنِ سَيِّدُهُمَا) لَهُمَا فِي الضَّمانِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا فِيهِ لَمْ يُلْزَمَهُمَا وَإِنْ صَحَّ بِدَلِيلٍ قَوْلُهُ الْآتِي : " وَاتَّبَعَ ذُو الرِّقِّ بِهِ إِنْ عَتَقَ " وَدَخَلَ بِكَافِ التَّمَثِيلِ قِنْ وَذُو شَائِبَةٍ مِنْ مُدَبِّرٍ وَأُمٍّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُمِ جَوَازِ ضَمَانِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ) مَرَضًا مَخُوفًا (بِثُلُثٍ) أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ بِسِيرِ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُفْصَدَ بِهِ الضَّرَرُ كَالدِّينَارِ لَا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُلْزَمُ وَإِنْ صَحَّ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَارَةِ الزَّوْجِ أَوْ الْوَارِثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَمِنَا قَدْرَ الثُّلُثِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ^(١)

(١) تعريف الركن : رُكْنُ الشَّيْءِ فِي الإِصْطِلَاحِ : مَا لَا وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ " الْجُزْءُ الدَّائِي الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ تَقَوُّمُهَا عَلَيْهِ .
أما الشرط فهو : " مَا يُلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يُلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ " كالطهارة بالنسبة للصلاة وبناءً عَلَى هَذَا فَكُلُّ مِنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الْمُسَمَّى شَرْعًا ، غَيْرَ أَنَّ الرُّكْنَ يَكُونُ دَاخِلًا فِي حَقِيقَةِ الْمُسَمَّى ، فَهُوَ جُزْؤُهُ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا عَنِ الْمُسَمَّى .

* **الشرح والتعليق :** يشير المصنف بهذا إلى الركن الأول من أركان الضمان ، وهو الضامن الذي يشترط فيه : أن يكون من أهل التبرع ، أي مكافا (بالغا ، عاقلا ، رشيدا) غير محجور عليه ولو فيما ضمن فيه ، فيشمل ضمان الزوجة والمريض بالثلث ، ولقد مثل المصنف لأهل التبرع بعدة أمثلة :

* وألفت النظر إلى أن جل ما سيذكره المصنف من أمثلة عدا الزوجة والمريض لا وجود له في الواقع المعاصر ، والفضل الأول يرجع إلى الشريعة الغراء ؛ حيث قضت على الرق بأن أغلقت كل الأبواب التي يدخل منها الرقيق ، وفتحت كل الأبواب التي يخرج منها كل من ضرب عليه الرق ، إلا أننا نضطر إلى ذكرها كأمتلة لما نتحدث عنه، ولتركب بعض الأحكام عليه ، فلم نقصد إليه لذاته بل لأمر آخر ؛ حتى لا نوصف بما نحن برآء منه براءة الذنب من دم ابن يعقوب ، ألا هل بلغت اللهم فاشهد .أ ، هـ

١ - **المكاتب :** وهو المعتق على مال مؤجل موقوف على أدائه ٢ - **المأذون له في التجارة** ، فهذان يصح منهما الضمان بشرط أن يأذن لهما سيدهما في الضمان ، فإذا ضمنا بدون إذن السيد لهما لم يلزمهما الضمان ، وإن صح.

* **تساؤل :** ألا يعتبر توقف تصرف كل من المكاتب ، والمأذون له في التجارة على إذن السيد معارضا لجعلهما من أهل التبرع ؟

* **والجواب :** أن الكاف في قوله : " (كَمْكَاتِبٍ وَمَأْذُونٍ) تحتل وجهها من اثنين : الأول منها : أنها للتشبيه وليست للتمثيل ووضح البناني في حاشيته على شرح الزرقاني الفرق بينهما بعض الشيء، فقال إن الكاف في الأوليين - المكاتب والمأذون له في التجارة - للتشبيه ؛ لأن كاف التشبيه : تفيد التشبيه في الصفات ، فالمكاتب والمأذون له اشتركا في صفة واحدة وهي الإذن لهما في التجارة ، والكاف للتمثيل في الآخرين وهما الزوجة والمريض ، وكاف التمثيل تفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض ذات ونفس الزوجة كالمريض. أما المكاتب والمأذون له في التجارة فصفا المكاتب من حيث الإذن تشبهه المأذون له من حيث التجارة ، فالكاف من المشترك المستعمل في أحد معنييه وهما التشبيه والتمثيل.

* **الثاني من الوجهين اللذين تحتلهما الكاف :** أن المكاتب والمأذون له في التجارة صارا بعد الإذن لهما من أهل التبرع ، فقوله : (أَذْنٌ سَيِّدُهُمَا) شرط في اتصافهما بكونهما من أهل التبرع ويدخل بكاف التشبيه في قوله : " (كَمْكَاتِبٍ وَمَأْذُونٍ) : ٣ - **الغن وهو :** العبد الخالص الذي ليست فيه شائبة حرية ويدخل كذلك من فيه شائبة حرية مثل : ٤ - **المدير والتدبير عبارة عن :** تعليق مكلف رشيد ، وإن زوجة في زائد الثلث عتق رقبة على

موته لزوما ٥ - أم الولد ، وهي : الأمة التي ولدت من سيدها ، أو هي : الحر حملها من وطء مالكة ، وتعتق من رأس ماله بعد مماته بدون توقف على حكم حاكم
٦ - ومعتق لأجل ، والعتق هو : خلوص الرقبة من الرق بصيغة وهو من أعظم القربات عند الله عز وجل.

لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمْرًا مُسْلِمًا ، اسْتَقْدَّ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ » قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ : « فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ ».

* والفرق بين المعتق لأجل والمدير : أن المعتق لأجل لا يتوقف عتقه على موت سيده ، بل على انقضاء الأجل ، أما المدير فيتوقف عتقه على موت سيده.
* تساؤل : لماذا خص المكاتب والمأذون له في التجارة بالذكر ؟ نبه المصنف عليهما بالذكر لدفع ما قد يتوهم من جواز ضمانهما بغير إذن . ٧ - الزوجة : لها أن تضمن في حدود ثلث مالها - ضمان مال ، لا ضمان طلب ولا ضمان وجه - أو ما زاد على الثلث بيسير ، وشأن هذا اليسير أن لا تقصد به الضرر كالدينار مثلا (٢٥ ، ٤ أربعة جرامات وربعا) لا ما زاد على ذلك ، فلا يلزم وإن صح ، أي فيتوقف على إجازة الزوج ، فإن شاء رد الجميع ، وإن شاء أمضى لجميع .

ولماذا للزوج رد الجميع ، لا ما زاد على الثلث فقط ؟ لأن الزوج قد يتضرر من خروج زوجته للبحث عن المدين ، أو الولوج في قاعات المحاكم ، والجلوس أمام المحققين ونحوهم.

وفي ضمان الزوجة تفصيل يوضح غموضه أرى أنه من الواجب استعراضه ليتضح الأمر
ويزال الوهم ، فعن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه الخمسة إلا الترمذي [نيل الأوطار للشوكاني ج ٦ / ١٨ ، كتاب : النكاح باب : ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها] والحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وقد أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرک ، وفي إسناده عمرو بن شعيب ، هم

رجال الصحيح عند أبي داود ، وفي الباب عن خيرة امرأة كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

* وقد استدلت بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة .

وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء على النحو التالي :

* **قال الليث بن سعد :** لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ولا فيما دونه ، إلا في الشيء التافه

* **وقال طاووس ومالك :** يجوز لها أن تعطي من مالها بغير إذن في حدود الثلث لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه

* **وذهب الجمهور** إلى أنه يجوز لها أن تعطي من مالها مطلقا أذن الزوج ، أو لم يأذن ، بشرط ألا تكون سفية فإن كانت سفية لم يجز ، قال ابن حجر في فتح الباري : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة ، وقد استدلت البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب : هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة ، ومن جملة أدلة الجمهور : حديث جابر وفيه قال : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن ، وذكرهن ، وقال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة - خيرة - النساء سفعاء الخدين - فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة ، وتكفرن العشير " قالت : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب " بلال " من أقراطهن " متفق عليه .

* **أولا : التعليق على الحديث :** (فقالت امرأة من سطة النساء) هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة ، وفي بعض النسخ (واسطة النساء) قال القاضي : معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال : وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم ، وأن صوابه (من سفلة النساء) وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده ، والنسائي في سننه ، وفي رواية لابن أبي شيبة " : امرأة ليست من علية النساء " وهذا ضد التفسير الأول ، وبعضه قوله : بعده سفعاء الخدين ، هذا كلام القاضي ، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة ، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسر هو بل المراد : امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة : يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم ، قوله : (سفعاء الخدين)

بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد . قوله صلى الله عليه وسلم (تكثرن الشكاة) هو بفتح الشين أي الشكوى ، قوله صلى الله عليه وسلم : (وتكفرن العشير) قال أهل اللغة : يقال : هو العشير المعاصر والمخالط ، وحمله الأكثرون هنا على الزوج وقال آخرون : هو كل مخالط . قال الخليل : يقال : هو العشير ومعنى الحديث : أنهم يجحدن الإحسان لضعف عقلمن وقلة معرفتهم ، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان . قوله (من أقرطتهن) هو جمع قرط . قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي .

* **ثانيا : ما يؤخذ من الحديث من أحكام :** حمل الجمهور الحديث المذكور هنا (حديث عبد الله بن عمرو) على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة.

* **وحمل الإمام مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير** وجعل حده الثلث فما دونه ، ومن جملة أدلة الجمهور : الأحاديث المتقدمة في أول الباب ، حديث أم المؤمنين عائشة ، وأبي هريرة وأسماء ، وسعد رضي الله عنهم جميعا القاضية بأنه يجوز لها التصديق من مال زوجها بغير إذنه ، وإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه ، فمن باب أولى يجوز لها ذلك في مالها .

* **والأولى :** أن يقال يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو ، وما ورد من الحوادث المخالفة له تكون مقصورة على مواردّها ، أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم ، أما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجة .

٨ - **المريض :** ويقصد به المريض مرضا مخوفا ، وهو الذي يغلب منه الهلاك ، ويتصل بالموت ، ومرض الموت أيضا هو : الذي تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة ، وكان الغالب فيه الهلاك ، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول على اعتباره مرض موت هو : " عجز المريض بسببه عن الخروج لمصلحة نفسه " ومثل الفقهاء لذلك : بالمقعد ، والمشلول ما دام يزداد به لأنه ما دام يزداد في علته فالغالب أن آخره الموت ، ويمكن الاسترشاد الآن برأي أهل الذكر في ذلك من الأطباء المهرة الثققات العدول في الأمراض الميؤس الشفاء منها ، وما قيل في الزوجة يقال هنا في المريض إلا إذا ضمن بأزيد من الثلث بكثير الشأن فيه الضرر بالورثة ، فللورثة إن شاءوا أن يردوا ما زاد على الثلث ، وإن شاءوا أجازوا

الجميع ، فما زاد على الثلث في ضمان كل من الزوجة والمريض صحيح غير لازم ، أي موقوف على إجازة الزوج أو الورثة

* **اعتراض :** في موضع آخر ذكر أن الزوجة أو المريض إذا تبرع أي منهما بأكثر من الثلث ، ولو بيسير كان للزوج أو الوارث الرد ، وهنا قالوا بجواز الضمان بأزيد من الثلث بيسير ! فكيف هذا ؟

* **والجواب :** ما تقدم من منع تبرع كل من الزوجة والمريض بأزيد من الثلث ولو بيسير هذا محله في التبرع المحض المجرد الذي لا رجوع بعوضه ، أما ما هنا ففي الضمان الذي فيه الرجوع على المضمون بما غرم للمضمون له.

* **وما محل ، أو متى يتوقف نفاذ ولزوم ما ضمنته الزوجة بأزيد من الثلث على إجازة الزوج ؟**

يتوقف نفاذ ولزوم ما ضمنته الزوجة بأزيد من الثلث على إجازة الزوج إذا ضمننت غير زوجها ، أما إذا كان الضمان منها لزوجها ، فلا يتوقف على إجازته ، قال الباكي : " لها الكفالة لزوجها بجميع مالها ، أي وليس له الرد " وفي المدونة : إذا ادعت أنه أكرهها في كفالتها له فعليها البينة.

مسألة غير موجودة في الوقت الحاضر

يقول المصنف : " (وَاتَّبَعَ ذُو الرِّقِّ بِهِ) أَيُّ بِالضَّمَانِ بِمَعْنَى الْمَالِ الَّذِي ضَمِنَهُ (إِنْ عَتَقَ) ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ لَهُ إِسْقَاطُهُ عَنْهُ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَلَهُ إِسْقَاطُهُ قَبْلَ عِتْقِهِ فَلَا يَتَّبَعُ بِهِ بَعْدَهُ وَلَا يُبَاعُ فِيهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ (وَلَيْسَ لِلْسَيِّدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ) أَيُّ عَلَى الضَّمَانِ فَإِنْ جَبَرَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْعَبْدَ شَيْءٌ إِنْ عَتَقَ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ أَوْ لَهُ مَالٌ وَجَبَرَهُ عَلَى أَكْثَرِ مِمَّا بِيَدِهِ وَأَمَّا لَوْ جَبَرَهُ عَلَى ضَمَانٍ قَدَرٍ مَا بِيَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ انْتِزَاعِ مَا بِيَدِهِ " (١)

(١) الشرح والتعليق : ونظرا لعدم وجود الرق الآن فلن أفيض في شرح هذه الجزئية ، مكتفيا بشرح الفقهاء القدامى لها على النحو التالي : يَعْنِي أَنَّ ذَا الرِّقِّ كَالْمُكَاتِبِ وَالْمُدَبِّرِ وَالْمَادُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ إِذَا حَصَلَ مِنْهُمْ ضَمَانٌ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَاسْتَمَرَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ حَصَلَ لَهُمُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُمْ يُنْبَعُونَ بِمَا حَصَلَ مِنْهُمْ مِنَ الضَّمَانِ وَلَيْسَ لِلْسَيِّدِ قَبْلَ الْعِتْقِ إِسْقَاطُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِإِذْنِهِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ مِنْ دَكَرِ الضَّمَانِ بغيرِ إِذْنِ السَّيِّدِ، فَإِنَّ لَهُ إِسْقَاطَهُ فَإِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ حَتَّى حَصَلَ مَا ذَكَرَ مِنَ الْعِتْقِ فَإِنَّهُمْ يُنْبَعُونَ أَيْضًا، الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السَّيِّدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ عَلَى الضَّمَانِ أَمَّا غَيْرُ مَنْ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ فَلَأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقُ وَالضَّمَانُ بَاقٍ عَلَيْهِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الضَّرَرُ فَإِنْ جَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْعَبْدَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقِيلَ لَهُ جَبْرُهُ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى النِّكَاحِ وَفُرِّقَ بَيْنَ السَّيِّدِ مَنْفَعَةٍ فِي النِّكَاحِ.

الضمان عن الميت المفلس

يقول المصنف : " (و) صَحَّ الضَّمَانُ (عَنْ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ) بِسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ أَيْ الْمُعْسِرِ بِمَعْنَى الْحَمْلِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنَ الضَّامِنِ ، وَخَصَّ الْمُفْلِسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَيْمَةِ ؛ إِذْ مَنْعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَمَّا الْحَيُّ أَوْ الْمَيِّتُ الْمُؤَسِّرُ فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الضَّمَانِ عَنْهُ وَكَذَا ضَمَانُ الْمُفْلِسِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ " (١)

(١) أولاً : معنى بعض الكلمات التي في النص : التفليس : من أفلس الرجل، إذا لم يبق له مال ، يراد به ، أنه صار إلى حال يقال فيها : ليس معه فلس (والفلس عملة يتعامل بها مسكوكة من غير الذهب والفضة، وتقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي اليوم جزءا من ألف من الدينار في العراق وغيره) فيقال أفلس الرجل: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ، وقد فلسه الحاكم تفليسا : نادى عليه أنه أفلس ،

والفلس شرعا ، له معنيان ، عام وخاص.

والفلس بمعناه العام : قيام الغرماء على ذي دين حل ليس له ما يفي به ، فلهم سجنه ، ومنعه من البيع والشراء والأخذ والعطاء ، ويسمى صاحبه : المفلس (بسكون الفاء وكسر اللام).

والفلس بمعناه الخاص هُوَ : حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخُلْعِ مَا بِيَدِهِ لُغْرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ وَقَاءِ مَا عَلَيْهِ ، ويسمى صاحبه المفلس (بفتح الفاء وكسر اللام المشددة) ، ولا يكون ذلك إلا بثلاثة شروط : ١ - أن يطلب الدائنون ، أو بعضهم تفليسه ٢ - أن يحل أجل الدين أو الديون ٣ - أن يزيد الدين الحال الذي على المدين على ما بيده من مال ، بناء على ذلك يرفعون الأمر للقضاء مطالبين بـ : أ - سجنه إن كان موجودا ، وإلا ب - فيحولون بينه وبين ماله ويمنعونه من التصرفات المالية من بيع وشراء ، وأخذ وإعطاء ولو بغير محاباة ، ويطالبون بمنعه من التزوج ، ولهم المطالبة بقسم ماله بالمحاصة - التي سنوضحها قريبا - أي يأخذوا بنسبة ما لكل منهم.

ثانيا : الشرح والتعليق : لم يَخْتَلَفْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْحَمَالَةِ عَنْ الْحَيِّ مُوسِرًا كَانَ ، أَوْ مُعْسِرًا ، وَلَا فِي الْحَمَالَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي الْحَمَالَةِ عَنْ

الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ الْحَمَالَةِ وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ فَمَنَعَا ذَلِكَ أَهـ
، في هذا النص مسألتان :

المسألة الأولى وهي في المفلس بمعناه العام ، ولهذه المسألة صورتان الصورة الأولى :
يصح الضمان عن الميت المفلس ويلزم ، إذا تحمل إنسان عن الميت المعسر عالما بعسره
وأدى عنه ، وفي

هذه الحالة لا يرجع بما أداه في مال يطرأ لهذا الميت المفلس بعد ذلك لأن تحمله وأدائه
عنه تبرع محض ، الصورة الثانية : أن يتحمل إنسان عن الميت المعسر عالما بأن لهذا
الميت مالا ، أو ظن أن له مالا ، أو شك ، وأدى عنه ، ثم ظهر المال الذي لهذا الميت
ففي هذه الحالة يرجع بما أداه في المال الذي طرأ لهذا الميت المفلس بعد ذلك

المسألة الثانية : وهي في المفلس بمعناه الخاص إذا تحمل إنسان عنه ، وأدى فإنه لا
يرجع بعد ذلك في مال يطرأ له سواء علم بأن له مالا ، أو ظن ، أو شك وبمعنى أوضح :
أنه إذا قام الغرماء ، أي الدائنون على المفلس ورفعوا أمرهم إلى القضاء ، وحكم القاضي
بخلع ماله لدائنيه فضمنه إنسان فإن المال الذي حكم القاضي به لدائنيه يتحاصون فيه ،
أي يقتسمونه قسمة محاصة ، أي يأخذ كل منهم من ماله بنسبة دينه.

وبالمثال يتضح المقال : فلو أن شخصا مدين لثلاثة على النحو التالي : س من الناس دائن
له بـ ١٠٠٠ من الجنيهات ، ص من الناس دائن له بـ ٢٠٠٠ من الجنيهات ، د من الناس
دائن له بـ ٣٠٠٠ من الجنيهات ، كل ما يملكه هذا المدين ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف من
الجنيهات ، وهي لا تسد دينهم جميعا ، فيتحاصون في الثلاثة آلاف بنسبة دين كل منهم ،
أي بنسبة ١ : ٢ : ٣ فيكون مجموع الأجزاء = ١ + ٢ + ٣ = ٦ فيكون نصيب كل جزء
٥٠٠ = ٦ ÷ ٣٠٠٠ من الجنيهات فصاحب الألف يأخذ ٥٠٠ = ٥٠٠ ،
وصاحب الألفين يأخذ : ٥٠٠ × ٢ = ١٠٠٠ من الجنيهات ، وصاحب الثلاثة آلاف يأخذ :
٥٠٠ × ٣ = ١٥٠٠ من الجنيهات ، فيدخل عليهم النقص جميعا بنسبة ما لهم ، وما بقي
لهم بعد ذلك يدفعه ذلك الضامن عنه ، ولا يرجع عليه بما أداه عنه مطلقا أي سواء علم بأن
له مالا ، أو ظن ، أو شك ، أو علم أن لا مال له ، وطرأ له مال ، وهذا بخلاف ما ذكرنا
في المسألة الأولى ، ولعل وجه هذا : أن الضامن لم يظلمه أحد ولم يغرر به أحد ، وهو
داخل في الضمان وهو على علم بذلك ؛ لأنه يوجد حكم من القاضي ، فكأنه متبرع بما زاد

على ما في تركة الميت المفلس ، هذا هو الذي قاله الشيخ / عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل ونقله العدوي ، وقال البناني : وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم له مالا ولا فرق بين المفلس بالتشديد أو بالتخفيف ، وفي كتاب المديان من المدونة ج ٤ / ١٢٤ كتاب : المديان ، باب : في الرجل يموت وعليه دين

" وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَتَبَرَّعَ رَجُلٌ فَضَمَّنَ دَيْنَهُ فَذَلِكَ لَزِمَ لَهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ رَجَعَ فِيهِ بِمَا أَدَّى إِنْ قَالَ : إِنَّمَا أَدَيْتُ لِارْجَعِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَالضَّامِنُ عَالِمٌ فَإِنَّهُ لَا يَرْجَعُ فِي مَالٍ إِنْ ثَابَ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْحِسْبَةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ النَّبْرُ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَالنَّظَرُ مَا كَانَ عَنْ سُؤَالٍ " قول المدونة : (وَالضَّامِنُ عَالِمٌ) جَعَلَ لَهُ الرُّجُوعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، وَقَالَ ثَابٌ أَيُّ ظَهَرَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَمَنْ ضَمَّنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى إِذَا ضَمَّنَ الْقَضَاءُ عَنْ مَيِّتٍ وَكَانَ ظَاهِرُهُ الْيُسْرُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا تَحَمَّلْتُ لِارْجَعِ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَمْ أَضْمَنْ أَهْ

* والمقصود بضمان الميت هنا هو الحمل عنه لا حقيقة الضمان الذي هو : شغل ذمة اخرى بالحق ؛ لأن ذمة الميت قد خربت بالموت ، والدليل على جواز الضمان عن الميت الآتي : عَنْ جَابِرٍ قَالَ « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ دَيْنَارَانِ . قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

تسلسل الضمان

يقول المصنف: " (و) صَحَّ ضَمَانُ (الضَّامِنِ) وَلَوْ تَسَلَّسَلَ وَيُلْزَمُهُ مَا يُلْزَمُ الضَّامِنِ الْأَصْلِيَّ وَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ مَعًا بِالْمَالِ أَوْ بِالْوَجْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْمَالِ وَالثَّانِي بِالْوَجْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ " (١)

(١) الشرح والتعليق : هل يصح ضمان الضامن ؟ يصح ضمان الضامن ولو تسلسل ، ولا مانع من ذلك ؛ لأن التسلسل في المستقبل ، وإنما يكون محالاً إذا كان في الماضي .
* وظاهر المذهب (مصطلح ظاهر المذهب : يطلق على ما ليس فيه نص ، ويراد به : الظاهر من الدليل ، أو الظاهر من المذهب فالمسألة التي لم ينص على حكمها ينظر في الدليل ، أو فيما تدل عليه قواعد المذهب وأصوله ، فالذي يدل عليه ظاهر الدليل ، أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص ، ومثال الظاهر من المذهب قول ابن رشد : " إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها ") **فظاهر المذهب** يشمل ما إذا كانا معا بالمال أو بالوجه ، أو أحدهما بالمال والثاني بالوجه فهو صحيح ، وإنما الاختلاف من حيث الرجوع عندما يغرم ضامن الضامن ، وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر من إحدى الصور الآتية :

* **الصورة الأولى** : أن يكونا معا بالمال : ففي هذه الصورة يبدأ بمطالبة المدين إن كان حاضراً مليئاً ، وإلا يكن كذلك فينتقل للضامن الأول إن كان حاضراً مليئاً ، وإلا يكن كذلك فينتقل للضامن الثاني ، وهكذا

* **الصورة الثانية** : أن يكونا معا بالوجه : (و ضمان الوجه هو التزام الإتيان بالمدين عند الأجل، ويبرأ بتسليمه للدائن ، ولو كان عديماً، أو بسجن، أو بغير البلد إن كان به حاكم، وإلا لو أسلمه الضامن في صحراء، أو في بلد لا سلطان فيه، أو كان المدين يقدر على الامتناع من الأداء بسلطانه أو غيره لم تسقط الحماله) ففي هذه الصورة يبدأ بالمدين إن كان حاضراً ، فإن غاب كلف الأول بإحضاره ، فإن غاب الأول كلف الثاني بإحضار أحدهما ، فيبرأ بذلك ، فإن غاب

* **الصورة الثالثة** : أن يكون الأول بالوجه والثاني بالمال : وخلاصة هذه الصورة : أنه إن ترتب على الأول المال لعدم إحضاره المدين غرمه الثاني عنه ، ويبرأ الثاني أيضاً بإحضار المضمون الأول ؛ لأنه يبرأ بما يبرأ به الضامن الأول .

ضمان الدين المؤجل على الحلول

يقول المصنف : " (و) صَحَّ ضَمَانُ الدَّيْنِ (المُؤَجَّلِ حَالًا) أَيَّ عَلَى الضَّامِنِ بِأَنْ رَضِيَ الْمَدِينُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنَ الْأَجَلِ (إِنْ كَانَ) الدَّيْنُ (مِمَّا يُعَجَّلُ) أَيَّ يَجُوزُ تَعَجِيلُهُ وَهُوَ الْعَيْنُ مُطْلَقًا وَالْعَرَضُ وَالطَّعَامُ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ حَظِّ الضَّامِنِ وَأَزِيدُكَ تَوْثُقًا بِالضَّامِنِ إِذْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْبَيْعِ فَقَطْ " (١)

(١) الشرح والتعليق : أولا صورة المسألة : مثلا " محمد " دائن لأحمد ب ١٠٠٠ ألف من الجنيهات إلى شهر ، فأسقط أحمد حقه من الأجل ، وضمنه " علي " ليؤدي أحمد حالا ، وذلك خوف المماطلة مثلا ؛ لأنه وإن كان حالا ، لكن من الجائز أن يماطل المدين وهو أحمد في السداد ، فالضمان - الذي كان بعد أن لم يكن - زيادة توثق ، ولأنه قد يكون للدائن " محمد " مصلحة في الأجل ، كانتظار ارتفاع الأسواق ، أو أن الدين سيكلفه حفظا وحراسة ، ولأن من عجل ما أجل عد مسلفا وذلك نظير إسقاط الضمان بإقباضه أو قد يظهر أن ما يسلمه المدين مغشوشا ، أو معيبا ؛ أو قد يظهر لهذا المبلغ أو الدين الذي يسدد عاجلا مالك آخر غير المدين ، ويستحق في هذه الحالة كالمغصوب ؛ حيث إن بعض البائعين يطلب كفيلا يضمن له سلامة الثمن ، فالضمان في هذه الحالة صحيح ولازم بشرط : أن يكون الدين مما يعجل ، ويكون ذلك في الحالات الآتية :

١ - أن يكون الدين عينا (أي ذهباً أو فضة أو ما حل محلها من أوراق البنكنوت) مطلقا ، أي سواء أكان الدين عينا من قرض - بأن يكون قد سلفه أو أقرضه ذهباً أو فضة أو ما حل محلها من أوراق البنكنوت - ، أو من بيع بأن يكون ثمن بيع مؤجل ، ففي هذه الحالة يجوز ضمانه على الحلول ، وذلك لأن الأجل من حق المدين ، فإذا أسقطه وعجل الأداء جاز هنا.

٢ - أن يكون الدين عرضا (والعرض هو : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا) أو طعاما من قرض ، مثال الدين الذي من عرض أن يكون لمحمد عند علي مرجع من كتب المالكية أخذها عي على سبيل السلف من محمد لمدة شهر مثلا ، ومثال الطعام الذي من قرض : أن يقرض محمد عليا عشرة أرادب من قمح لمدة شهرين مثلا ، وفي المثالين المذكورين يجوز ضمانهما على الحلول ؛ وذلك للعلة السابقة ، ألا وهي

: أن الأجل فيهما من حق المقرض إن شاء عجل، وإن شاء أبقى للأجل ، ولا يقال عند التعجيل أنه طلب من المقرض حط الضمان عن نفسه ؛ لأن القرض من باب المعروف ، فلا شيء في هذا، بخلاف البيع (المسلم) فإن الحق في الأجل إن كان طعاما أو عرضا للطرفين ؛ لأن للمشتري (المسلم) الحق في تأجيل قبض المثلث ؛ لأنه يرصد به الأسواق ، وللبائع (المسلم إليه) الحق في التأجيل حتى يحصد زرعه ويسلمه في الأجل ، فإذا عجل المسلم إليه شيئا قيل : إنه طلب حط الضمان عن نفسه ؛ لأنه طالما في ذمة المسلم إليه أي البائع فهو من ضمانه فإذا عجله فكأنما رفع الضمان عن نفسه ، فمن عجل ما أجل عد مسلفا في مقابل حط الضمان عن نفسه ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه قرض جر نفعاً ، وهذا منهي عنه بالنص.

٣ - أن يكون الدين عرضاً ، أو طعاماً من بيع وهو ما ذكرناه سابقاً ما يسمى بالسلم، وهو بيع عجل فيه الثمن وآخر فيه المثلث ، وهذه الصورة لا يجوز فيها ضمان الدين المؤجل على الحلول ، وذلك لن الحق في الأجل إذا كان طعاماً أو عرضاً منهما ، أي من البائع وهو المسلم إليه ومن المشتري وهو المسلم ، والسلعة، هنا يرصد بها الأسواق غالباً ، فللمشتري وهو المسلم غرض صحيح في تأخير القبض وتسلم السلعة في الأجل لينتفع بالربح فيه ، بخلاف القرض فإنه لا يجوز أن يقصد المقرض النفع الدنيوي بما أقرض ، وإلا كان قرضاً جر نفعاً ، وهو منهي عنه شرعاً .

* **وَأَعْلَمَ أَنَّ مِثْلَ ضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحُلُولِ فِي الْجَوَازِ بِقِيْدِهِ (أن يكون الدين مما يعجل) ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ لِدُونِ الْأَجْلِ فَإِنْ ضَمِنَهُ لِأَجَلٍ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلِأَبْعَدَ مُمْتَنِعٌ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنَفَعَةً فَالْصُّورُ أَرْبَعٌ وَهِيَ:**

* **الصورة الأولى :** ضمان الدين المؤجل على الحلول جائز ، إذا كان الدين مما يعجل ، وهو العين مطلقاً ، والعرض والطعام من قرض لا من بيع

* **الصورة الثانية :** ضمان الدين المؤجل على أن يكون لدون الأجل ، وحكمها كحكم الصورة الأولى

* **الصورة الثالثة :** ضمان الدين المؤجل للأجل نفسه ، وهذه جائزة بلا شرط

* **الصورة الرابعة :** ضمان الدين المؤجل لأبعد من الأجل ، وهذه الصورة غير جائزة ؛ لأنه سلف جر نفعاً

* **فالجواز بشرط في صورتين :** الأولى والثانية ، ويجوز في واحدة وهي الثالثة بلا شرط ، ويمتنع في واحدة وهي الرابعة .

ضمان الدين الحال إلى أجل آخر

يقول المصنف: " (وَعَكْسُهُ) وَهُوَ ضَمَانُ الْحَالِ مُوَجَّلاً كَأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِرَبِّ دَيْنٍ حَالٌ: أَجَلُ مَدِينِكَ شَهْرًا وَأَنَا أَضْمَنُهُ لَكَ ، فَيَصِحُّ بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لِأَوَّلِهِمَا بِقَوْلِهِ : (إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ) أَي مَدِينُهُ بِالَّذِينَ الْحَالُ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ ؛ لِلسَّلَامَةِ مِنْ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا ، فَكَأَنَّهُ بِالتَّأخيرِ ابْتَدَأَ سَلَفًا بِضَامِنٍ وَيُسْرِهِ لَمْ يَحْصُلْ بِالضَّامِنِ نَفْعٌ فَيَكُونُ التَّأخيرُ مُحْضَ سَلَفٍ ، وَأَشَارَ لِلثَّانِي بِقَوْلِهِ (أَوْ لَمْ يُوسِرْ) الْغَرِيمُ (فِي الْأَجَلِ) الَّذِي ضَمِنَ الضَّامِنُ إِلَيْهِ بَلْ أَعْسَرَ وَاسْتَمَرَّ عُسْرُهُ إِلَى انْقِضَائِهِ فَيَجُوزُ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ حَصَلَ نَفْعٌ بِالضَّمَانِ لَمْ يَحْصُلْ سَلَفٌ بِتَأخيرِهِ لَوْجُوبِ انْتِظَارِ الْمُعْسِرِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْسِرْ فِي جَمِيعِهِ بَلْ أَيْسَرَ فِي أَثْنَائِهِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ الْغَلَاتِ وَالْوُظَائِفِ ، كَأَنْ يَضْمَنَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَادَتُهُ الْيَسَارُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ الْمُتَأخَّرَ عَنْ ابْتِدَاءِ يَسَارِهِ يُعَدُّ فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ مُسَلِّفًا لِقُدْرَةِ رَبِّ الْحَقِّ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ عِنْدَ الْيَسَارِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ الْمُتَرَقِّبَ كَالْمُحَقَّقِ وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ عُسْرِهِ (و) صَحَّ الضَّمَانُ (بِالْمُوسِرِ) بِهِ فَقَطْ (أَوْ بِالْمُعْسِرِ) بِهِ فَقَطْ وَكَلَامُهُ فِي ضَمَانِ الْحَالِ مُوَجَّلاً يَغْنِي إِذَا كَانَ الدَّيْنُ كُلُّهُ حَالًا وَالْغَرِيمُ مُوسِرٌ بِبَعْضِهِ وَمُعْسِرٌ بِالْبَعْضِ الْآخِرِ صَحَّ ضَمَانُهُ مُوَجَّلاً بِهِذَا أَوْ هَذَا (لَا بِالْجَمِيعِ) ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً إِذْ هُوَ سَلَفٌ لِلْمُوسِرِ بِهِ لِتَأخيرِهِ إِيَّاهُ بِحِمِيلٍ بِهِ وَانْتَفَعَ بِالضَّامِنِ فِي الْمُعْسِرِ بِهِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ كَضَمَانِ الْمُعْسِرِ بِهِ فَقَطْ وَمِثْلُ ضَمَانِ الْجَمِيعِ ضَمَانُ الْبَعْضِ مِنْ كُلِّ " (١)

(١) الشرح والتعليق : وصورة المسألة التي يدور عليها النص ؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره : دائن لآخر بمبلغ من المال إلى أجل ما ، ثم حل أجل أداء الدين ، فجاء

شخص ثالث وقال للدائن : أجل مدينتك هذا شهرا وأنا ضامن له ، فهذا الضمان جائز بشرطين على البدل ، أي إذا وجد أحدهما كفى في الجواز ، وهما :

* **الشرط الأول :** أن يكون المدين موسرا بالدين الذي حل أجله ، ولو في أول الأجل ، ولو أعسر بعد ذلك (ولكن لماذا التأجيل لأجل آخر ، والمدين موسر وقادر على السداد ؟ لأنه ربما يكون المدين في حاجة لهذا المبلغ لأمر آخر ضروري من نحو طعام ، أو سلعة ضرورية) ولا يقال : إن هذا سلف جر نفعاً إذا أعسر بعد أول الأجل ، وذلك لأن العبرة بحالة المدين الراهنة ، أي عند حلول الجل قبل الضمان ، وهو عنده كان موسرا ، ويسره في أول الأجل والضمان هكذا ، فكأن الدائن ابتداء سلفاً يضمن ، وببسر المدين عند حلول الأجل لم يحصل بالضمان نفع ؛ لأن رب الدين يستطيع أن يستوفي حقه ، وتأخير المدين في هذه الحالة محض سلف.

* **الشرط الثاني :** إذا لم يوسر المدين في أول الأجل بل أعسر ، فيشترط : استمرار حالة الإعسار إلى الأجل الذي سوف يضمنه الضامن إليه ، بمعنى ألا يتقرب يساره أثناء الأجل بغلة ونحوها ، ففي هذه الحالة يجوز ضمانه ، وذلك لأنه وإن حصل نفع للدائن بالضمان نظرا لعسر المدين ، فلم يحصل سلف بتأخيره ؛ لأنه يجب على الدائن انتظار يسر المدين ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " البقرة (٢٨٠)

ويفهم من قوله : " واستمر إعساره إلى الأجل الذي سوف يضمن الضامن إليه " أن المدين إذا لم يكن شأنه وحاله الإعسار في جميع الأجل الذي ضمن الضامن إليه بل أيسر في أثناءه ، بأن كانت عادته حصول اليسار له في أثناء الجل كبعض أصحاب الغلات ، والوظائف ، كأن يضمنه إلى أربعة أشهر ، وعادة المدين اليسار بعد شهرين فلا يصح هذا الضمان

←————→ ←————→

أول الأجل ١ / ٤ أثناء الأجل ١ / ٦ آخر الأجل ١ / ٨

هو معسر فيه أيسر أثناء الأجل هنا لا يجوز الضمان

ولماذا لا يجوز الضمان هنا في هذه الصورة ؟ لأن الزمن المتأخر من ابتداء اليسار (١ / ٦) في المثال يعد شرعا أن صاحب الحق مسلف فيه ، وذلك لقدرته على أخذ حقه من المدين عندما كان موسرا ، وقد انتفع الدائن بالضامن الذي توثق به في فترة الإعسار (من

١ / ٦ - ١ / ٨) فيكون سلفا جر نفعا ، وهذا لا يجوز عند ابن القاسم ، واستدل على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (وليس من نافلة القول أن نفيض في تخريج هذا الحديث ؛ لأهميته في موضوعنا : الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده لكنه ساقط الإسناد ؛ لأنه من رواية : سوار بن مصعب وهو متروك ، وقال عمرو بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء ، ولكن له شواهد تؤيده منها : عن فضالة بن عبيد موقوفا قال : " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " مسالك الدلالة ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن عباس موقوفا عليهم ، ووهم إمام الحرمين والغزالي ، حيث قالوا : إنه صح ؛ حيث لا خبرة لهما بهذا الفن " نيل الأوطار للشوكاني ج ٥ / ٢٣٢ ، ٢٣٣

** والله أعلى وأعلم **

باب الإجارة

باب الإجارة^(١)

قال المصنف:

(باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك) وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي والكراء شيء واحد في المعنى: وهي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض، غير أنهم سمو العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما^(٢).

(١) كتبه أد/علي محمد علي أحمد، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

(٢) الشرح: شرع المصنف - رحمه الله - في باب الإجارة وكما جرت العادة في التأليف بدأ بتعريف الإجارة وهي:

تعريف الإجارة في اللغة:

الإجارة مثلثة الهمزة، وتقرأ بالفتح والضم والكسر، وهي بالكسر أفصح، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وهي بالكسر أفصح وهي مصدر أجر بالقصر، ويقال أجر إيجارًا، كأكرم إكرامًا، ويستعمل الممدود أيضًا من باب المفاعلة، ويكون مصدره المؤجرة. ومجمل معنا في اللغة الأجرة على عمل أو منفعة ذات.

تعريف الإجارة في الشرع: هي: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.

شرح التعريف:

قوله "تمليك" جنس في التعريف يشمل سائر عقود التمليك ما يرد منها على الذات كالبيع، وما يرد على المنافع كالإجارة.

قوله "منافع" قيد في التعريف خرج به العقد على الذات كالبيع والهبة، والصدقة؛ فإنها تمليك ذوات.

قوله "مباحة" قيد في التعريف خرج به استئجار منافع الغير منفعة غير مباحة كاستئجار امرأة للرقص أو استئجار رجل لقتل غيره بغير حق، فالإجارة على مثل هذه الأمور غير جائزة؛ لأن المنفعة المراد استيفؤها منفعة غير مباحة.

قوله "مدة معلومة" أفاد ذلك القيد أن الإجارة لا بد أن تكون مؤقتة إذ التأقيت من أبرز خصائصها؛ لأنه يفرق بين الإجارة والبيع.

قوله "بعوض" أي تمليك المنفعة في نظير ومقابلة عوض فخرج بذلك النكاح والجعالة؛ لأن المنفعة في الإجارة تكون في نظير العوض حتى ولو حصل مانع من إتمامه رجع للمحاسبة، بخلاف النكاح والجعالة؛ لأن المنفعة في النكاح هو التمكين من البضع، وفي الجعالة هو التمكين من المجاعل عليه في نظير عوض فيهما، فكل من البضع والمجاعل عليه في المنفعة تحققت أم لا، استمرت أم لا فيثبت العوض بتمامه على كل حال.

حكم الإجارة:

الإجارة من العقود الجائزة دل على جوازها الكتاب، والسنة، والإجماع.

أولاً الكتاب:

- قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) سورة الطلاق من الآية ٦.
- قوله تعالى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ) سورة القصص آية ٢٦، ٢٧.

- قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) سورة الطلاق من الآية ٦.

ثانياً السنة:

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل ابتاع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره). صحيح البخاري كتب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير.
- وعن عائشة بن عمر - رضي الله عنها - قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر رجلاً من بني الدئل هادياً خريتماً، وهو على دين كفار قريش، فدفعاً إليه راحلتهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث). وفعل النبي دليل على جواز الإجارة. (صحيح البخاري كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة).

- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره). نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية. التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ح ٣، ص ١٣٢ كتاب الإجارة.

ثالثا الإجماع:

أجمع السلف على جواز الإجارة قبل ادعاء ابن عليه والأصم عدم جوازها، وقولهما خرق للإجماع. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ٣، ص ٤١٩، تحقيق وتعليق وتخرير محمد صبحي حلاق، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، توزيع مكتبة العلم بجدة، جاء فيه "الإجارة جائزة عند فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحكي عن ابن عليه والأصم منها").

الحكمة من مشروعية الإجارة:

الناس ليسوا في درجة واحدة من المعيشة، ومن امتلاك بعض الأدوات واكتسابهم للمهارات، فيحتاجون إلى خدمة بعضهم البعض فأجيز عقد الإجارة والكراء؛ لما في ذلك من رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم في حياتهم.

والناس محتاجون إلى بعضهم فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود على وجه ترتفع به الحاجة ويون موافقا لأصل الشرع. (القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، د/ صالح بن غانم السدلان ص ٢٩٢، ٢٩٣، الناشر دار بلنسية، المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيه "حيث جاء هناك زمرة من العقود وورد بجوازها نص شرعي استثناء من القواعد العامة على خلاف القياس لحاجة الناس إليها كالسلم والإجارة.... وعقد الإجارة يرد على منافع معدومة تستوفى مع مرور الزمن في المستقبل؛ لكنه أجيز لحاجة الناس إليها لاسيما في عصرنا الحاضر - إلى السكنى).

الفرق بين الإجارة والكراء:

الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى. إلا أنهم أطلقوا على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل كالثياب والأواني والأمتعة، إلا السفن والحيوان إجارة؛ وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء، وهذا على سبيل الغالب في إطلاق لفظي الإجارة والكراء. وقد يتسمحن بإطلاق الإجارة على الكراء والكراء على الإجارة، فيطلقون على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء، ويطلقون على العقد على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل إجارة.

والفرقة التي ذكرها المالكية مبنية على العرف، وهي تفرقة اصطلاحية لا يترتب عليها أثر وإلا فالكل يسمى إجارة. (حاشية الدسوقي يهامش الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي ج ٤، ص ٢).

أركان الإجارة

قال المصنف:

"وأركانها أربعة: العاقد، والأجر، والمنفعة، والصيغة، والمراد ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، ويشمل ذلك المعاطاة، وأشار إلى الأولين بقوله: (وصحة الإجارة بعاقد) مؤجر ومستأجر كالبيع؛ فشرطهما التمييز، وشرط اللزوم التكليف؛ فالصبي المميز إذا أجر نفسه أو سلعته صح وتتوقف على رضا وليه ومثله العبد، وأما السفية إن عقد على نفسه فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الأجر محاباة فلوليه النظر وإن عقد على سلعة فلوليه النظر مطلقا كالبيع فالشرط لزوم أيضا في الجملة" (١).

(١) الشرح: قول المصنف وأركانها أربعة، يقصد أن للإجارة أربعة أركان وهي:

الركن الأول: العاقدان: وهما المؤجر، والمستأجر.

المؤجر: هو الذي يدفع الأجر مقابل المنفعة.

المستأجر: هو الذي يأخذ المنفعة مقابل الأجر.

يشترط في المؤجر، والمستأجر ما يشترط في البائع والمشتري في عقد البيع؛ لأن الإجارة بيع في المعنى إلا أنه بيع يرد على المنفعة دون الذات.

شروط صحة عقدهم: العقل فلا يصح من مجنون ومعتوه.

شروط لزوم عقدهم:

٣-الرشد

٢ -التكليف

١- الطوع

إجارة ناقص الأهلية

أولاً: إجارة الصبي المميز: تصح إجارة الصبي المميز سواء أجر نفسه، أو أجر سلعته، ويتوقف لزوم إجارته على رضا وليه، ومثله العبد.

ثانياً: إجارة السفية: إن عقد على نفسه، فلا كلام لوليه؛ إلا إذا كان في الأجرة محاباة، كما لو كان مثله يأخذ مقابل عمل مائة جنيه في اليوم وأجر نفسه بعشرين جنيهاً في اليوم، فإن الإجارة في هذه الحالة تكون متوقفة على إذن الولي.

أما إذا أجر السفية نفسه شيئاً مملوكاً له فإن عقده يتوقف على رضا الولي في جميع الأحوال كان الأجر فيه محاباة أم لا، ذلك كالبيع؛ لأن التكليف شرط للتصرف المالي، والتكليف شرط لزوم في الجملة وليس في جميع الأحوال.

الركن الثاني الأجر:

ويقصد به ما يبذله مالك المنفعة مقابل بذله منفعته، ويشترط فيه ما يشترط في البيع في الثمن من كونه طاهراً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه.

الركن الثالث الصيغة:

وهي كل ما يدل على تمليك المنفعة العوض، ويشمل ذلك الأقوال، والأفعال، والمعاطاة وهي تمليك المنفعة وبذل الأجر دون تلفظ، فمن ذهب إلى الشاطئ وجلس تحت مظلة - مملوكة لغيرة- مدة من الزمن وقام وترك لصاحبها أجرتها صحت الإجارة، وتصح الإجارة بالمعاطاة إذا كانت الأجرة معلومة لدى الطرفين قبل الشروع في العقد.

قول المصنف (وصحت الإجارة بعاقده وأجره) في كلام المصنف حذف الواو وما عطف عليه أي صحة الإجارة ولزومها بعاقده وأجره كالبيع، وإنما قدرنا ذلك؛ لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم.

قول المصنف "بعاقده" أي من يلي العقد بنفسه أو نيابة عن غيره، ومن يلي العقد في الإجارة المؤجر أو المستأجر.

قوله "وشروطهما" أي شروط صحة عقدهما أي المؤجر والمستأجر.

قوله في "الجملة" يعني في أغلب الأحوال وليس في كل الأحوال، وقوله "وأجره كالبيع" أي يشترط فيه ما يشترط في الثمن الذي هو ركن في البيع.

حالات وجوب تعجيل الأجرة

قال المصنف:

ولما كانت قاعدة الإمام ابن القاسم أن الثمن في المبيع الأصل فيه الحلول، وأن الأجرة في الإجارة على التأجيل إلا في مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة ذكرها المصنف بقوله (وعجل) الأجر وجوباً فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام وإلا فسد العقد (إن عين) أي إن كان معيناً كثوب بعينه أي شرط تعجيله أو كانت العادة تعجيله وإلا فسد العقد ولو عجل بالفعل كما يأتي في قوله وفست الخ (أو) كان غير معين ووقع التعجيل (بشرط) أي بسببه وهو عطف على معنى إن عين أي وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط (أعادة) بأن كان الغرف والعادة التعجيل وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فهي صحيحة في هذه الأربع^(١).

(١) الشرح: القاعدة عند ابن القاسم الأصل في الثمن في البيع هو الحلول، وأن الأصل في الأجرة في الإجارة هو التأجيل، إلا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة وهي:

- ١- إذا اشترط التعجيل وكان الأجر غير معين.
- ٢- إذا اعتيد التعجيل، بأن كان العرف والعادة التعجيل، وكان الأجر غير معين؛ لأن العادة تقوم مقام الشرط.
- فهذا إذا كان الأجر في الحالتين غير معين، كأن يقول المستأجر أكرني دارك سنة مثلاً لأسكنها بكذا، أو أرضك لأزرعها بكذا، وكانت الأجرة دنانير أو دراهم، لأن الدنانير والدرهم لا تتعين، ووجوب تعجيل الأجر في شرط التعجيل واعتياد التعجيل يقضى به عند التنازع، فإن تراضيا على التأخير جاز ذلك.
- ٣- إذا عين الأجر كهذا الثوب -أي في العروض- فإنه يجب تعجيله، إن شرط التعجيل أو كان العرف تعجيله ويغتنر التأخير ثلاثة أيام.
- ٤- إذا لم يتعين الأجر، أي كان في الذمة، والحال أنه لم يجز عرف ولا يوجد شرط بالتعجيل؛ فإنه يجب تعجيل الأجر إن كان في منافع مضمونة في ذمة المؤجر ولم يشرع

فيها مثل أن يقول استأجرتك على فعل كذا مثلا، فإنه يجب تعجيل الأجر، فإن شرع فلا ضرر، وإن لم يشرع فيها وتأخر في الشروع أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، إلا إذا عجل جميع الأجرة، وإلا لأدي إلى ابتداء الدين بالدين وهو منهي عنه.

ويستثنى من ذلك حالة: يتعاقد فيها السفر مع غيره إلى الحج قبل أوانه كما يحدث في أعرافنا فإنه يجوز له أن يكتفي بدفع بعض الأجرة عربونا في حالة خوف التلاعب، أو عدم الوفاء.

ويشترط لصحة هذا الاستثناء: أن يكون التعاقد في غير أوان الحج، أما إذا كان التعاقد في أوان الحج فلا بد من دفع كامل الأجرة أو الشروع في السفر. فإذا لم توجد حالة من حالات وجوب التعجيل للأجر فيجوز تعجيله وتأجيله حسبما يرضيه الطرفان، فإن اختلفا في الدفع يكون مياومة كلما استوفى منفعة يوم أو تمكن من استيفائها دفع الأجرة.

ويستثنى من ذلك: الأجراء والصناع فإنهم لا يعطون الأجر إلا بتمام العمل كله وذلك عند المشاحة أما عند التراضي فيجوز كل حال، وإلى هذا أشار المصنف بقوله وأما الصانع والأجير فليس أجرة إلا بعد التمام، ففي المدونة وإذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب الشيء حملوا على المتعارف بين الناس، فإن لم يكن لهم سنة لم يقض لهم بشيء إلا بعد الفراغ.

الأحوال التي تفسد فيها الإجارة

قال المصنف:

(وفسدت) إجارة عينت فيها الأجرة فهو راجع كقوله وعجل إن عين (إن انتفى) فيها (عرف تعجيل المعين) بأن كان العرف التأخير أولا عرف، وعلل الفساد بأنه كشرط التأجيل فيلزم الدين بالدين ، وعمارة الذمتين، ومحل الفساد فيهما إن لم يشترط التعجيل كما مر (كمع جعل) أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة ؛ لتنافرهما؛ لما في الجعل من عدم لزومه بالعقد، وجواز الغرر ، وعدم الأجل بخلاف الإجارة، (لا) مع (بيع) صفقة واحدة فلا تفسد لعدم منافاتها سواء كانت الإجارة في نفس البيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن يخطه البائع أو جلدا على أن يخرزه الخرازة، أ و في غيره كشرائه ثوبا بدرهم معلومة على أن ينسج له آخر، ويشترط في الصورة الأولى شروعه، أو ضرب أجل الإجارة ، ومعرفة خروجه عين علة أم لا، أو إمكان إعادته كالتحاس على أن يصنعه قدحا كما قدمه في السلم، فإن انتفى الأمران كالزيتون على أن يعصره فلا، وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع فتجوز من غير شرط، ثم عطف على قوله كمع جعل مسائل تفسد فيها الإجارة للجهالة فقال (ومجلد) جعل أجرا (لسلاخ) وأدخلت الكاف اللحم كلا و بعضا وسواء كانت الشاة حية أو مذبوحا، لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ ، وقد يخرج صحيحا أو مقطوعا.. (أو نخالة لطحان)؛ لأنها مجهولة القدر كالجزاف غير المرئي، وأما لو استأجره بكيل معلوم منها على أن يطحن له قدرا من الحب فيجوز (وجزء ثوب) جعل أجرة (لنساج) ينسج ذلك الثوب ، ومثل ذلك الجلود دبغها [جزء منها ؛ لجهل صفة خروجه، فإن وقع فالثوب لربه ، وله أجر مثله (أو رضيع) آدمي أو غيره جعل جزؤه كربيعة أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع بل (وإن) كان يملكه

(من الآن) ، لأن الصبي قد يتغير ، وقد يتعذر رضاعه لموت أو غيره ، ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما كم هنا (و) فسدت إذا استأجر هـ (بما سقط) أي بجزء منه كثلث (أو) بجزء منها (خرج من عصر زيتون) راجع للثاني للجهل بالكم ، والصفة ؛ لأن من الشجر ما هو قاصر يقل ما يسقط منه ، ومنه ما هو بخلافه (وكاحصد وادرس) هذا الزرع (ولك نصفه) وكذا ادرسه ولك نصفه ففاسد ، وله أجر مثله ، وأما احصده فقط ولك نصفه فسيأتي أنه جائز (وكراء أرض) صالحة للزراعة (بطعام) سواء انبت كالقمح ، أو لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام ، لأجل مع التفاضل والغرر ، والمزابنة ، وأما بيعها به فيجوز (أو بما تنبته) غير طعام كقطن وكتان ، وعصفر ، وزعفران ، وتين ، وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز إجماعا (كخشب) وحطب وقصب فارسي ، وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز (و) فسدت إجارة على (حمل طعام) مثلا (البلد) بعيد لا يجوز تأخير قبض المعين اليه (بنصفه) مثلا لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه ، فإن وقع فأجر مثله ، والطعام كله لربه (إلا أن يقبضه) أي الجزء المستأجر به (الآن) أي حين العقد بالفعل لعرف ، أو يشترط قبضه الآن ولولم يقبض بالفعل لعدم العلة المتقدمة فهذه المسألة من أفراد الإجارة بمعين فيجري فيها تفصيله ، وهو أنه إن وقعت والعرف التعجيل فلا بد منه وإلا فسدت ، وإن كان العرف التأخير أولا عرف فلا بد من اشتراط التعجيل وإلا فسدت ، ويغتفر التأخير اليسير كالثلاثة الأيام (وكان) أي كقوله إن (خطته اليوم) مثلا فهو بكذا من الأجر عشرة (وإلا) تخطه اليوم بل أزيد (فبكذا) أي بأجر أقل كثمانية ففاسدة للجهل بقدر الأجرة ، فإن وقع فله أجرة مثله ، ولو زاد على المسمى خاطه في

اليوم أوفي أكثر (واعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب ولا غيره (فما حصل) من ثمن أو أجرة (فلك نصفه) مثلا ففاسدة للجهل بقدر الأجرة، وكذا في داري ،أوفي حمامي أو سفينتي ونحوها فيتعين الفسخ إن لم يعمل فإن عمل فأشار له بقوله (وهو) أي ما حصل من عمله (للعامل) وحده (وعليه أجرتها) أي أجرة مثلها لربها بالغ ما بلغ ، ومثل ذلك إذا قال له أعمل عليها فأكرها على الأرجح أوقال له أكرها وما حصل من ذلك فلك نصفه فعمل عليها (عكس)خذها (لكريها) وما حصل فلك نصفه فأكرها فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثله ؛ لأنه أجر نفسه إجارة فاسده ،فالصور أربع ثلاثة منها الأجر فيها للعامل ، وعليه أجرتها ، والرابعة بالعكس إلا أن الثانية فيها قولان مرجحان وما قدمناه قول ابن القاسم فيها (وكبيعه) عطف على قوله كمع جعل (نصفا) لكثوب بدينار يدفعه الأجير لربه (بأن) أي على أن (يبيع)له (نصفا)ثانيا أي باعه نصف السلعة بدينار مثلا على أن يبيع له النصف الثاني فصار ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار والسمسرة علي بيع النصف الثاني إن أبهم في محل البيع ، أو عين غير بلد العقد ؛لأنه بيع معين يتأخر قبضه (إلا بالبلد) أي إلا أن يكون محل البيع البلد الذي هما به فيجوز ؛لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن ، ويلحق به بلد قريب يجوز تأخير قبض المعين له ، وللجواز شرطان زيادة على اشتراط تعيين البلد أشار لهما بقوله(إن أجلا) أي ضربا لبيع النصف الثاني أجلا ليكون إجارة محضة وهي تجامع البيع فيخرجان عن بيع وجعل (ولم يكن الثمن) أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر، وهو النصف المدفوع للسمسار (مثليا) وحينئذ فهو مساو للتعبير بالثمن ،او المبيع نعم التعبير بما ذكر أوضح ، فلو كان المبيع مثليا منع ؛لأنه قد يصير تارة إجارة وسلفا ؛لأنه قبض إجارته وهي مما لا يعرف بعينه فيصير

سلفا إن باع في نصف الأجل؛ لأنه يرد حصة ذلك ، وتارة يكون ثمنا إن باع في آخر الأجل ، أو مضى الأجل ولم يبيع العقد بين الممنوع وهو إجارة وسلف و الجائز وهو الثمن ، ويفهم من هذا أنه إذا شرط عليه أنه باع في أثناء الأجل لا يرد له باقي الثمن بتركه أو يأتيه بطعام آخر يبيعه أنه يجوز وهو كذلك^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف عدة صور تفسد فيها الإجارة وهي:

١- تفسد الإجارة بوقوعها بأجر معين وانتفى عرف تعجيل الأجر المعين؛ لأن انتفاء العرف بمثابة اشتراط التأجيل في حالة يجب فيها التعجيل فيكون ابتداء الدين بالدين وهو مما لا يجوز في الشرع.

ومحل الفساد حيث لا يوجد شرط يوجب تعجيل الأجر ، فإن وجد شرط تعجيل الأجر كانت الإجارة جائزة وصحيحة حتى لو انتفى عرف التعجيل.

٢- وقوع الإجارة مع الجعالة والجعالة هي: التزام أهل الإجارة عوضا علم، لتحصيل أمر يستحقه السامع بالتمام، إلا أن يتم غيره فبنسبة الثاني. (الشرح الكبير شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير ، ج٤، ص ٦٠ بهامش حاشية الدسوقي للعلامة محمد عرفة الدسوقي، وبهامشه تعليقات للشيخ محمد عليش) في صفقة واحدة مثل أجرني دابتك وائتني ببعيري الشارد بكذا؛ فتفسد الإجارة والجعل معا؛ وذلك لتنافر أحكامهما؛ إذ الجعالة غير لازمة بالعقد وإنما تلزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، فالمقصود بالجعالة التعاقد على إتمام عمل بأجر، وهي التزام من طرف واحد وهو الجاعل ابتداء، بخلاف الإجارة فهي تلزم بمجرد العقد، وعقد الإجارة ملزم للطرفين.

الجعالة يجوز فيها الغرر بجهل مقدار العمل، بخلاف الإجارة فلا يجوز فيها الغرر.

الجعالة لا يجوز فيها الأجل، بخلاف الإجارة فيجوز فيها الأجل.

ويجوز أن تجتمع الإجارة مع البيع في عقد واحد، فلا تفسد لعدم منافاتهما سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة عل أن يخطه البائع، أو جلد على أن يخزّه، أو في غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر ويشترط لصحة هذه الصورة عدة شروط:

- شروع الأجير في العمل بحيث لا يتأخر العمل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاتفاق على العمل.
- أن يضرب له أجلا للإجارة.
- أن يعرف في العادة الحالة التي يكون عليها المعمول بعد تمامه من الجودة والرداءة حتى تخرج الجهالة، فإذا لم يمكن ذلك فلا تجوز الإجارة إلا إذا كان الشئ الذي أضيفت إليه الصنعة مما يمكن إعادته إلى الحالة الأولى التي كان عليها عند التعاقد كما هو الحال في التعاقد على شراء سبيكة من الذهب على أن يصنعها البائع مشغولات ذهبية.
- أما إذا ورد عقد الإجارة على غير المبيع كما لو اشترى ثوبا على أن يصنع له آخر فهذه الصورة تجوز بدون شروط.
- ٣- تفسد الإجارة إذا كان الاستئجار على أن تكون الأجرة بعض ما استؤجر عليه الأجير، ومن أمثلة ذلك:
- لا يجوز الاستئجار على ذبح شاة على أن يأخذ السلاخ أجرة على السلخ في حيوان مباح الأكل، فالإجارة فاسدة، وقعت قبل الذبح أو بعده؛ لأنه لا يستحق الجلد إلا بعد السلخ، وهو لا يدري هل يخرج الجلد سليما أو مقطوعا، وفي أي جهة يكون القطع، وهل يكون رقيقا أم لا، فعلة المنع هنا الجهل بصفة الجلد بعد السلخ، وهو غرر ممنوع في الإجارة كالبيع، ومثل الجلد اللحم كلا أو بعضا؛ لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد ولا بد في عوض الإجارة أن يكون معلوما، وكذلك لا تجوز الإجارة على ذبحها بقطعة من لحمها.
- أن يعطى الطحان النخالة أجرة، كأن تستأجر شخصا يطحن لك حبا بنخالة. ومن أمثلة هذا القبيل ما يقع في بلاد الأرياف من دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنة في مقابلة درسه فهي إجارة فاسدة، وأما لو قال له أدرسه ولك حملان تبنا من تبنة، أو من غير تبنة جاز ذلك.
- أن يعطى النساج جزء من الثوب المنسوج أجرة على النسج، والدباغ جزء من الجلد المدبوغ أجرة على الدبغ، فنفس الإجارة لجهل صفة خروجه.

ما يجوز في الإجارة

قال المصنف: (وجاز) أي عقد الإجارة على دابة (بنصف) جر نصف بالباء، وهي ظاهرة ، وفي نسخة ، فنصف مرفوع بدل من ضمير جاز العائد

- أن يعطى جزء الحيوان الرضيع أجرا لمن يرضعه، وعلل الفساد أن الرضيع قد يتغير، وقد يتعذر رضاعة لموت أو غيره، ولا يلزمه خلفه، فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة، بين السلامة وعدمها وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما.
- ٤- الإجارة على عمل تكون الأجرة للأجير فيها مما يحصله من ثمن أو أجرة ممن يعاملهم بالنصف مثلا. ومثال ذلك: قول الرجل للأجير اعمل على دابتي، أو أعمل على سيارتي، أو في حانوتي ونحو ذلك، وما حصل من ثمن وأجرة فلك نصفه مثلا فهذه الإجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة فتفسخ.
- فإن عمل فجميع ما تحصل يكون للعامل، وعليه لرب الدابة، أو السيارة، أو الحانوت ونحو لك أجرة مثلها، أي الدابة وما معها؛ وذلك لأنه يكون كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا.
- ٥- أن يعطى الأجير على الحصاد زرع ودرسه نصف ما يخرج أو ثلثه، وكذا درسه فقط فذلك فاسد، ولالأجير أجرة عمله؛ وذلك للجهل بما يخرج من الحب وهو غرر؛ لأن نصف الحب أو ثلثه مغيب لا يدري كم يخرج وكيف يخرج.
- ٦- كراء الأرض للزراعة بطعام على اختلاف أصنافه، على النحو التالي:
 - كان مما تنبته الأرض كالقمح.
 - أولم تنبته كاللبن والسمن، والعسل، والشاة المذبوحة، والحيوان الذي لا يراد إلا للذبح كخصي المعز، والسماك، وطير الماء، وكذلك الحيوان الذي يراد للبنز
 - أو مما تنبته من غير الطعام، كقطن وكتان، أي شعرهما لا ثيابها وكزعفران وعصفر وتبن وحطب الذرة.
 - اما كراء أرض الزراعة لغير الزراعة بطعام وبما يخرج منها فيجوز.
- كما يجوز بيعها بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاما 'فالنهى قاصر على الكراء، لا على البيع.
- وكذلك فإن كراء الدور، والحوانيت بالطعام جائز، والدليل هو الأجماع.

على الكراء أو الإجارة أي وجاز كراء هو نصف (ما يحتطب عليها) أي الدابة المتقدم ذكرها بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها بعرف ، أو غيره سواء قيد بزمان كيوم لي ويوم لك أم لا كنقله لي ونقله لك فالأجرة هنا معلومة بخلاف ما تقدم من قوله واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه واحترز بقوله بنصف ما يحتطب عليها فلا يجوز لقوة الغرر ، ومثل السفينة الدابة والشبكة ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمل عليها إذا كان معينا من مكان معين فلا مفهوم لدابة ولا النصف ، (و) جاز (صاع دقيق) يدفعه رب القمح ونحوه لمن يطحنه له (منه) أو من غيره في نظير طحنه (أو) صاع (من زيت) يدفعه رب الزيتون لمن يعصره له أجرة لعصره (لم يتخلف) أي إذا لم يختلف كل من الحب أو الزيتون في الخروج ، فإن اختلف بأن كان تارة يخرج منه الدقيق ، أو الزيت ، وترة لا تمنع ؛ للجهالة ، فإن شك في الخروج حمل في الزيتون ونحوه كبزر السمس على عدم الخروج فيمنع ، وفي الحنطة ونحوها على الخروج فيجوز^(١).

(١) الشرح: بعد أن ذكر المصنف صور من الإجازات الفاسدة تبعه بذكر صورتين من الإجازات الجائزة وهي كما يلي:

١ - إجارة السيارة بجزء من مما ينقل عليها:

يجوز إجارة السيارة التي تنقل أشياء كسيارات النقل المعروفة عندنا على أن تكون معلومة معينة فلا مجال لعدم الجواز ثم إن هذه الصورة تختلف عن الصور التي ذكرها المصنف في الإجازات الفاسدة، وهي إجارة الدابة بنصف ما يحتطب عليها أي بنصف ثمن ما يحتطب عليها لأن الثمن المنقول يتطرق إليه الجهالة بخلاف ما نحن عليه حيث إن المنقول شيء معين ينقل إلى مكان معين فلا جهالة هنا. لكن يشترط للجواز أن يعلم قدر ما يحمل على السيارة ونحوها بعرف أو نحو ذلك للخروج من الجهالة.

٢ - الإجارة على الطحن، أو العصر بجزء معين من المطحون والمعصور:

يجوز الإجارة على طحن حب من القمح وغيره على ان يكون أجرة الطحان جزء معين من الدقيق، وكذلك تجوز الإجارة على عصر حب الزيتون، أو السمس على أن تكون أجرة العاصر جزء مهين من الزيتون المعصور.

ويشترط لجواز ذلك: عدم اختلاف أحوال المعمول - القمح، والزيتون ونحوهما - بعد الخروج على حالة معينة، أما إذا اختلفت بأن كان تارة يخرج منه دقيق، أو الزيت، وتارة لا، مَنع؛ للجهالة، فإن شك في الخروج حمل في الزيتون ونحوه كبزر السمس على عدم الخروج لكون الشأن فيه ذلك لربما كان الزيتون رديئاً لا يخرج منه زيت، فيمَنع، وفي الحنطة ونحوه على الخروج فيجوز؛ لأن العادة في القمح يخرج منه الدقيق، وإن اختلفت درجة الجودة فيه.

إجارة الشيء المؤجر

قال المصنف: (و) جاز استئجار المالك المؤجر لداره، أو دابته مثلاً (منه) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف جر منفعة كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقداً^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف هنا صورة من صور الإجارة الجائزة وهي إيجار الشيء المؤجر - بفتح الجيم - للمالك كأن يستأجر إنسان داراً، أو دابة من شخص ثم يقوم المستأجر بتأجيرها للمالك بمثل الأجرة، أو أقل، أو أكثر، سواء كانت بجنس الأول أولاً، بشرط أن تكون مدة الإجارة الثانية أقل من المدة الأولى، أو مساوية لها؛ لأن الإجارة إذا انتهت مدتها عاد الملك لصاحبه ولا يتصور أن يستأجر الإنسان ملكه. أما إذا وجد تهمة فلا يجوز كاستئجارها بعشرة حالاً، وبثمانية حالاً، فتمنع هنا لتهمة سلف جر نفعا.

جعل الخدمة أجرا على تعليم الصنعة

قال المصنف: (وجاز) لمن له رقيق، أو ولد (تعليمه) أيدفعه لمن يعلمه صنعة معينة (يعمله سنة) مثلاً للمعلم فسنة ظرف لعمله، وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة من يوم العقد عند الإطلاق فإن هينا زمنا عمل به فيما يظهر^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف صورة من صور الإجازات الجائزة، وهي جعل الخدمة أجرا على تعليم صنعة معينة على أن يكون الأجر مقابل التعليم، جرت العادة أن يذهب الصبيان إلى أصحاب الحرف - نجار، أو ميكانيكا، أو سباكة... - فترة معينة من الزمن ليتعلم هؤلاء الصبيان الصنعة ولا يتقاضى هؤلاء الصبيان أجرة في تلك الفترة؛ لأن أجرته كانت مقابل تعليمه الحرفة، ويبدأ حساب الفترة التي يعمل فيها الصبي في محل العمل من يوم أخذه لا من يوم العقد فإن حدد زمنا معيناً يبدأ فيه عمل الصبي عند صاحب الحرفة عمل.

الإجارة على حصاد الزرع بجزء معين من المحصول

قال المصنف: (و) جاز (أحصد) زرعي (هذا ولك نصفه)، وجذ نخلي هذا ولك نصفه وأشار إلى أنه لابد من تعيينه وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك، وبقيّة العمل من الدرس والتذرية عليهما، ويمنع قسمة قتا؛ لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن يونس، وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الأمر والمضارع وتتكسر، (و) جاز أحصد زرعي و(ما حصدت فلك نصفه) مثلا وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء، وما قبله من الإجارة كما تقدم^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف صورة من صور الإجازات الجائزة وهي الإجارة على حصاد الزرع بجزء معين من المحصول مثل: أن يستأجر شخصا ويقول له المالك: أحصد زرعي، أو جذ نخلي هذا ولك نصفه، وهي من باب الإجارة اللازمة ليس لأحد أن يرجع فيها، فيملك الأجير حصته بالعقد لا بالحصاد خلافا للشيخ عبد الباقي الزرقاني، وحينئذ فهو يحصد النصف له، والنصف الآخر لربه كما صرح به ابن رشد، وعياض، وما هلك قبل الحصاد فضمامنه منهما، وبقيّة الأعمال من التذرية والدرس عليهما، ولا يجوز قسمته قتا حتى لا يدخله التفاضل.

والفرق بين هذه الصورة، والصورة والتي تقدم ذكرها في قوله " كاحصد وادرس هذا الزرع ولك نصفه" وهي صورة من صور الإجارة الفاسدة، أما الصورة التي نحن بصدد استأجره بجزء من المحصول وهو مشاهد فكان بمثابة الأجر الجزافي وهو جائز عندنا، أما الصورة التي في الإجارة الفاسدة فإنه استأجره على جزء من الحب وهو مغيب لا يرى فتطرقت إليه الجهالة المقضية إلى المنازعة.

ويجوز أن يقول المالك للمستأجر وما حصدت فلك نصفه ويكون هذا من باب الجعالة؛ لعدم تعيين ما يحصد، ويحتمل أن يحصده كله، أو نصفه، أو ثلثه، أو غير ذلك، وهي غير لازمة للمستأجر، ولذلك يجوز له أن يترك العمل في أي وقت شاء، ولذا قيد بعض علمائنا الجواز بعدم تعيين زمن معين للحصد كما هو الحال في الجعالة.

إجارة دابة، أو سفينة لمسافة محددة أو مدة محددة

على أنه إن استغنى في المدة أو المسافة حاسب ربحها

قال المصنف: (و) جاز (كراء دابة) أو سفينة (لكذا) أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة (على) أنه (إن استغنى فيها) أي في المدة أو المسافة المعينة (حاسب) ربحها أي كان له بحساب ما سار أو ما سكن بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه؛ لأنه أمين، وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف هنا إلى مسألة أخرى من الصور الجائزة للإجارة من استأجر دابة ونحوها كسفينة لمسافة محددة، أو مدة محددة على أنه إن استغنى عنها في المدة، أو المسافة المعينة لظفرة حاجته في أثناء الطريق حاسب ربحها، أي: أنه كان لربحها بحساب ما سار المستأجر أو سكن صعوبة وسهولة.

ووجه الجواز هنا: أنه كأنه قال له أكرىك من هذا الطريق كل بريد بكذا، وأجرتك الدار بحساب كل شهر بكذا، فيكون ذكر المسافة لتتقدر الأجرة. ومحل الجواز إن لم ينقد الأجرة فإن نقدها لم يجز.

حكم إيجار شيء مؤجر - بفتح الجيم - وإيجار الشيء المنشئ منفعة

قال المصنف: (و) جاز (استئجار شيء (مؤجر) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى للمستأجر الأول أو لغيره (أو) استئجار شيء مستثنى أي استثناء البائع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع يعني أن من اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة جاز له أن يؤجرها لأنسان مدة بعد مدة الانتفاع على أن يقبضها المستأجر بعد مضي مدة الانتفاع وسيأتي المصنف أنه يجوز استثناء العام في الدار وسنين في الأرض ، وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكره المتوسط (و) جاز (النقد فيه) أي في الشيء المؤجر والمبيع المستثنى منفعته (إن لم يتغير غالبا) أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ، ومدة الاستثناء بأن ظن بقاؤه بحالة ، أو احتمال بأن شك في البقاء وعدمه وهو مسلم في الصورة الأولى دون الثانية ، ويجوز أن يكون قوله إن لم يتغير شرطا في أصل الجواز لا جواز النقد أي محل جواز استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا ، وإن احتمل فعلى أحد القولين ، وإن ظن التغير فالمنع قطعا ، وإذا منع العقد منع النقد ضرورة ، (و) جاز لمن استأجر دارا سنين ، أو شهور ، أو أياما بأجر معلوم (عدم التسمية لكل سنة) أو شهر ، أو يوم فإن كانت السنين ، أو الشهور تختلف في القيمة كدور مكة ، ودور النيل بمصر ، وحصل مانع رجوع للقيمة لا التسمية ، فإن شرط في العقد الرجوع للتسمية فسد^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف إيجار شيء مؤجر - بفتح الجيم - أي: إن من أجر حيوانا أو دارا مدة معينة معلومة كشهر أو سنة، يجوز له أن يؤجره قبل انقضائها مدة تلي مدة الإجارة

الأولى للمستأجر، أو لغيره، وذلك ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول، كالأحكار الموقوفة بمصر، وإلا عمل به؛ لأن العرف كالشرط.

وكذلك يجوز استئجار شيء مستثنى منفعته عند البيع بأن استثنى البائع منفعة ما باع، دار أو غير ذلك مدة معلومة، فللمشتري منه أن يؤجر ما اشتراه مدة تلي مدة الانتفاع، على أن استثناء السنة في الدار والسنتين في الأرض، وثلاثة أيام في الدابة.

النقد في إيجار المؤجر والمبيع المستثنى منفعته، ومحل جواز الإيجار والنقد إن لم يتغير غالبا، بأن كان الشأن عدم تغيره وهو صادق في صورتين ما إذا كان الغالب سلامته أو احتمل السلامة وعدمها، لكن الصورة الأولى متفقع عليها، والثانية فيها خلاف، هذا بالنسبة للإيجار فيهما، وأما النقد يجوز إن غلبت السلامة فيهما، لا إن لم تغلب بأن كان الشأن عدمها لطول المدة أو ضعف البناء أو نحو ذلك من كل ما شأنه التغير لكثرة العلاج فيه كالطاحونة والمعصرة، واحتمل الأمر فعلم أن الصور في عدم التغير غالبا ثلاث:

الأولى: الشأن السلامة فيجوز العقد والنقد قطعا.

الثانية: عدمها، فلا يجوز عقد على نقد.

الثالثة: احتمال الأمرين، فيجوز العقد لا النقد، وقيل لا يجوز عقد ولا نقد.

حكم كراء الأرض لتتخذ مسجدا

قال المصنف: (و) جاز (كراء أرض لتتخذ مسجدا مدة) معينة (والنقض) يكون (لربه) الباني (إذا انقضت) المدة يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بتلك المدة، وهو لا يشترط فيه التأييد كما يأتي، وترجع الأرض لمالكها^(١).

حكم الاستئجار على طرح النجاسات

قال المصنف: (و) جاز استئجار (على طرح ميتة) ونحوها من النجاسات وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة^(٢).

(١) الشرح: يجوز استئجار أرض ليني عليها المستأجر مسجدا مدة معينة، وعند انتهاء المدة تعود الأرض لمالكها، ويهدم المسجد.

(٢) الشرح: ذكر المصنف صورة من صور الإجارة الجائزة وهي جواز الاستئجار على طرح النجاسات عذرة، وميتة بأجر معلوم، وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة الداعية إلى إبعادها عن مجتمعات الناس، فتدخل تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، والضرورة هنا حفظ النفس من أضرار النجاسات وعفونتها.

وكذلك يجوز الإيجار على ما يلي:

- حمل النجاسة للانتفاع بها على الوجه الجائز، كحملها لأكل الكلاب، أو تزييل أرض أو لأكل مضطر سواء كان هو الحامل أو غيره، وحمل جلد مدبوغ لاستعماله في اليايسات والماء، فهو جائز، والإجارة عليه جائزة.

الإجارة على القصاص، وتأديب الابن

قال المصنف: (و) استتجار على (القصاص) من قتل حكم به الحاكم، وسلمه للمجني عليه أو لأوليائه، (و) على (الأدب) لوالده أو عبده إذا ثبت موجب، فلأب أو السيد الاستتجار عليه^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف جواز الاستتجار على القصاص، من قتل أو قطع، حكم به الحاكم العدل، وسلمه للمجني عليه أو وليه، وأما الإجارة على القتل ظلماً فلا تجوز، وعلة عدم الجواز أن المباشر مقدم على المتسبب، فإن نزل اقتص من الأجير، ولا أجر له، ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على المتسبب.

ويجوز الإيجار على الأدب لابن، ولا يطلب ثبوت موجب الأدب عند الأب إذ يصدق في ابنه الصغير، وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الأب بل يؤدبه الحاكم بالثبوت بشهادة بيعة عادلة.

حكم إجارة العبد خمسة عشر عاما، والأرض مأمونة الري

قال المصنف: (و) جاز استئجار (عبد خمسة عشرة عاما) بالنقد، ولو بشرط، وأما الدابة فحد إجارته سنة إلا لسفر فالشهور، وأجاز إجارة دار جديدة، وأرض مأمونة الري ثلاثين سنة بالنقد وبالمؤجل، وأما الدار القديمة فدون ذلك، بقدر ما يظن سلامتها اليه، أما الأرض الغير مأمونة الري فيجوز العقد بلا نقد، ومحل ايجار العبد المدة المذكورة ما لم يتغير غالبا فيها، وإلا منع إلا بقدر ما يظن السلامة وسيأتي في الوقف، وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين، ولمن مرجعها له كالعشر، (و) جاز التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كاستئجار على عمل (يوم) أو ساعة، أو جمعة، أو شهر يخطط له فيه، أو يبني، أو يدرس، أو يحصد له فيه بكذا، والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم، أو بناء حائط، أو قنطرة، حفر بئر وصف، (أو خياطة ثوب) أو سراويل بكذا فقله (مثلا) راجع لليوم، وللخياطة، للثوب (وهل تفسد) الإجارة (إن جمعهما) أي الزمن و العمل (وتساويا) كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ولا أكثر قال ابن رشد اتفاقا، وقال ابن عبد السلام على أحد المشهورين، والمشهور الثاني عدم الفساد (أو) تفسد (مطلقا) ولو زاد الزمن على العمل عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره ابن رشد في زائد الزمن، وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقله (خلاف) الأولى بدله تردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر، وعلى القول بالفساد فاللزام أجرة المثل زادت على المسمى أوقلت، (و) جاز (بيع دار) استثنى البائع منفعتها عاما (لتقيض) للمشتري (بعد عام و) بيع (أرض) استثنى البائع

منفعتها (عشر) من الأعوام لقوة الأمن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه، وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء الشهر وإنما يمنع بشرط النقد فقط^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى جواز إجارة العبد مدة خمسة عشرة عاما بالنقد ولو بشرط، وكذلك يجوز إجارة الدابة مدة سنة إلا أن يكون في سفر فغاية ذلك بالشهور، والحكمة في التفريق بين إجارة العبد، وإجارة الدابة أن العبد إذا حصل له مشقة يستطيع أن يخبر بحال نفسه، بخلاف الدابة لا يتأتى منها ذلك فيؤدي إلى إتلافها.

وأشار المصنف إلى جواز إيجار دار نحو ثلاثين عاما ولو بشرط النقد، ووجه جواز اشتراط النقد هو كونها مأمونة التغير غالبا، فإن كانت قديمة يحتمل بقاؤها ثلاثين وعدمه جاز العقد دون النقد، وإن كانت قديمة جدا لا تبقى ثلاثين عادة لم يجز كراؤها الثلاثين، والعلة في اختلاف الحكم بين الجواز وعدمه هو الوثوق في بقاء الدار على حالها وعدم بقائها وتغييرها.

جواز إجارة الأرض الزراعية المأمونة الري خمسين عاما، لا أكثر، فإن لم يؤمن من ريعها جاز العقد عليها هذه المدة دون النقد.

بيع دار ليقبضها مشتريها بعد عام من يوم بيعها، فيجوز استثناء منفعتها سنة؛ وبيع أرض لتقبض بعد عشر سنين، فيجوز استثناء منفعتها عشرا، وجه جواز ذلك ما في الدور والأرض من قوة الأمن من تغييرهما فاغتفر فيهما بيع يتأخر قبضه. (شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ١١، حاشية الزرقاني على مختصر خليل ج ٤، ص ١٤).

تجوز الإجارة على صنعة محددة بعمل، نحو خط لي الثوب، أو أحصد هذا الفدان، أو احفر هذا البئر بكذا، أو الإجارة على صنعة محددة بزمان كخط عندي يوما، أو شهرا، أو ابن لي بيتا، ونحو ذلك كل يوم، أو كل جمعة، أو شهرا أو جميع الشهر أو السنة.

وتفسد الإجارة إن جمع العمل والزمن وتساويا، بأن كانت العادة أن الزمن لا يزيد على الفعل ولا ينقص.

وأما إن كان الزمن ينقص عن العمل فإنه يفسد بالأولى، وأما لو كان الزمن أكثر ففيه خلاف في المذهب، قيل يجوز اتفاقا، وقيل تفسد على المشهور، لاحتمال طارئ على الأجير يمنعه من العمل، أي يدخله الغرر. (لمعرفة المزيد يراجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر ج ٤، ص ١٣، ١٢، الذخيرة ج ٥، ص ٤٢٠).

حكم الإجارة على الاسترضاع

قال المصنف:

(و) جاز استئجار على (استرضاع) لرضيع آدمي، أو غيره (والعرف) معتبر (في كغسل خرقة) فإن لم يكن فعلى أبيه على الراجح، فلو قال وغسل كخرقة على أبيه إلا لعرف لشمل المسألتين (ولزوجها) أي الموضع دون غيره (فسخه إن لم يأذن) لها فيه فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له (كأهل الطفل) ولو أما، وحاضنة لهم الفسخ (إذا حملت) الظئر؛ لأنه مظنة الضرر والخوف (و) لها الفسخ في (موت إحدى الظئرين) إذا استؤجر بعقد، أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين العقد، وماتت الأولى فللثانية الفسخ، وأما إن ماتت الثانية، أولم تعلم الأولى فلا فسخ، (و) لها الفسخ في (موت أبيه و) الحال أنها (لم تقبض أجرة) قبل موته كلا أو بعضا ولم يترك مالا (إلا أن يتطوع بها متطوع) من وارث، أو غيره فلا فسخ كما لو قبضتها من أبيه قبل موته، أو ترك مالا للولد^(١).

(١) الشرح: يجوز استئجار امرأة لترضع طفلا لغيرها - وذلك بالنسبة للأطفال التي تموت أمهاتهم، أو بالنسبة للتوائم الذين لا يكفيهم أمهاتهم، أو تكون الأم قليلة اللبن ولا يكفي لبنها الولد، وإن كان فيه استيفاء عين قصدا - "وأن تلك العين مغيبة، وهذا في بني الإنسان والحيوان.

الدليل على ذلك:

قوله تعالى: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى" سورة الطلاق آية ٦.

قوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ" سورة البقرة من الآية ٢٣٣.

أمر الله تعالى المطلقين أن يعطوا مطلقاتهم البائنات أجورهن على الرضاع، إذا رغبن في إرضاع أولادهن منهم حيث كان الرضاع واجبا عليهن ، والأمر بإعطاء الأجرة على الرضاع فرع من جواز الإجارة . (تفسير القرطبي ج ١٨، ص ١٦٨).

الضرورة الداعية على ذلك: ووجهها أن حياة المولود متوقفة عادة على الرضاع ، وهذا من باب حفظ النفس وهو من الكليات الخمس التي أمرت الشريعة بحفظها . (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي ج ١٣، ٤، شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ١٣).

ويجوز استئجار المرضعة بالنقد، وبالطعام، أو بالنقد والطعام معا كأن يشترط إطعامها بالإضافة إلى الأجر، ولا يكون هذا من باب بيع الطعام لأجل الضرورة؛ لأن النهي ورد في الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها. ويكون غسل بدن الطفل وغسل خرقه على أبيه لا على المرضع، إلا لعرف أو شرط فيعمل به.

الأحوال التي يجوز فيها فسخ عقد الإرضاع

ولزوج المرضع فسخ عقد الإجارة إن لم يأذن لها في الإرضاع . أي إذا أقدمت على عقد الإرضاع بدون علمه -، والتعليل في أحقية الزوج في فسخ عقد الإرضاع هو الضرر الذي يلحق الزوج بتشاغلها عنه وتغير حالها، وإن له الحق في الوطء لا يسقط عنه إلا برضاه وإذنه، أما إذا أقدمت على الإرضاع بإذنه فليس له فسخ العقد.

- يجوز لأهل الطفل فسخ العقد إن حملت المرضع من زوجها أو غيره زمن الرضاع. وإنما كان لخم الفسخ؛ لأن الحمل مظنة تضرر الولد بلبنها.

- يجوز للمرضع فسخ العقد إن مات أبو الطفل ولم تقبض الأجرة منه قبل موته ولم يترك له مالا، ولا مال للولد تأخذ منه أجرتها، ولم يتطوع أحد بالأجرة من قريب ولا بعيد، أما إذا ترك له مالا فلا يجوز لها فسخ العقد، وتقبض أجرتها من ميراث الولد من تركه أبيه.

وإن قبضت من الأب أجرتها قبل موته لم يكن لها الفسخ وعندئذ يتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التي عجلها؛ لأن الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الرضيع

فيرجعون به على مال الرضيع لا على المرضعة، وليس إعطاء الأب أجرة رضاعة هبة منه للرضيع، وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموته، ومحل رجوع الورثة بالأجرة على الرضيع بما زاد على يوم الموت مالم يعجل الأب الأجرة خوفا من موته الآن، وإلا كانت هبة ليس للورثة منها شيء.

- يجوز للمرضع فسخ العقد إذا كانت هي شريكة لأخرى في إرضاع صبي معين بعقد واحد، أو بعقدين متتاليين، وكانت تعلم الثانية بالأولى وماتت الأولى، أو فسخ عقدها فللثانية الفسخ؛ لأنها إنما قبلت القدوم على العقد لعلمها بأن هناك مرضعة أخرى تشاركها في إرضاع الصبي فإذا ماتت هذه المرضعة، أو فسخ عقد إرضاعها فإن الصبي سيكون معتمدا اعتمادا كلياً على لبنها بعد أن كانت الأولى تكفيه نصف الرضعات، وهذا بخلاف مالماتت الثانية وكان الاستئجار بعقدين فإن الأولى لا يجوز لها أن تفسخ العقد؛ لأنها قبلت العقد وكانت منفردة بالإرضاع وإدخال الثانية عليها من باب زيادة الاهتمام بالصغير، أو قد يكون من باب التسامح والرفقة بها، وكذلك ليس للثانية الفسخ إذا كانت لا تعلم أن هناك مرضعة أولى تقوم بالإرضاع.

حكم من استأجر عبداً ووجده أكلًا

قال المصنف: (وكظهور مستأجرٍ بفتح الجيم) (أوجر بأكله أكلًا) معمول لظهور أي ظهر حال كونه أكلًا خارجًا عن المعتاد للمستأجر الفسخ؛ لأنه كعيب ظهر به، إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره، والفرق بينه وبين الزوجة أكلة فلا خيار لزوجها، وهي مصيبة نزلت به فعليه اشباعها أن النكاح مبني على المكارمة بخلاف الإجارة أنها من البيع وهو مبني على المشاحة ويؤخذ منه أن من اشترى عبداً فوجده أكلًا فله رده^(١).

(١) الشرح: من استأجر عبداً فوجده أكلًا أي خارجًا عن الأكل المعتاد فلمستأجره الرد؛ لأنه عيب ظهر به إلا أن يرضى الأجير بطعام الوسط المعتاد فلا كلام لمؤجره، أما الزوجة تظهر أكلة فليس للزوج الفسخ.

والفرق بينها وبين الصورة السابقة: أن النكاح مبني على المكارمة بخلاف الإجارة فإنها من البيع وهو مبني على المشاحة، ويؤخذ من ذلك أن من اشترى عبداً فوجده أكلًا له رده. (الشرح الكبير على مختصر خليل ج ٤، ص ١٤، وأما فتوى الناصر اللقاني 'أن كثرة الأكل ليس بعيب يوجب الرد في المبيع؛ لأن كثرة الأكل الزائد على العادة من جملة ما العادة السلامة منه، والأطباء يجعلون ذلك داءً احترق في المعدة فهو من الأمراض، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤، ص ١٤).

حكم وطئ المرضع إذا استؤجرت للإرضاع، والسفر بها

قال المصنف: (ومنع زوج رضى) بإجارة زوجته ظئرا (من وطئ) لها؛ لأنه مظنة ضرر الطفل بالفعل ، ومثل الزوج السيد كما هو ظاهر (و) منع الزوج من (سفر) بها فيما إذا استؤجرت برضاه (كأن ترضع) غيره (معه) فتمنع ولو كان فيها كفاية لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال العقد فلا تمنع من إرضاعه، لأنه حينئذ بمنزلة الشرط وهي إذا اشترطت غيره لا تمنع ، (و) الاسترضاع (لا يستتبع) أي لا يستلزم حضانة لزيادتها على المعقود عليه (كعكسه) أي من استأجر امرأة لحضانة طفل لا يستلزم رضاعة فلا يلزمها إلا الشرط ، أو عرف في المسألتين^(١).

(١) الشرح: الزوج إذا رضى لزوجته أن تؤجر نفسها للإرضاع وفعلت فإن الإجارة تلزمها، ويمنع الزوج من وطئ الزوجة حال الإرضاع. وعلّة ذلك: أنه مظنة الإضرار بالطفل ولو لم يحصل إضرار بالطفل. وكذلك يمنع الزوج السفر بزوجته المرضع إن أذن لها في الإرضاع، فإن لم يأذن لها، له وطئها وله فسخ العقد.

ولو أراد أهل الطفل السفر بالطفل فلا يمكنون من اخ الولد، إلا إذا دفعوا كامل الأجرة للمرضع حيث كانت وجيبه.

وكذلك لا يجوز المرأة المرضع أن ترضع مع الطفل طفلا آخر ولو كان فيها كفايته؛ لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال العقد فلا تمنع من رضاعه معه، لأنه حينئذ بمنزلة الشرط، وكذلك لا تمنع المرضعة من اشتراط غير الولد للإرضاع مع الطفل.

ومن استرضع امرأة لترضع ولده لا يلزمها حضانتها؛ لأنها زيادة على المطلوب، وكذلك من استأجرها لترضعه ليس عليها أن تحضنه، إلا لم يكن هناك شرط أو عرف، وإلا عمل به.

حكم من باع سلعة وشرط على المشتري أن يعمل فيها سنة
قال المصنف: وعطف على الجائز مسألة مشتملة على بيع وإجارة بقوله
(و) جاز (بيعه) لآخر (سلعة).

بثمن معلوم أي تساوي أكثر منه (على أن يتجر) المشتري للبائع بثمنها
المذكور (سنة) مثلا فالمراد مدة معلومة، ولا بد من إحضار الثمن ، والإشهاد
عليه لينتقل من ذمة وإلا أدى إلى سلف جر نفعا ؛ لأنه يتهم ليزيده على
تأخيرته ولا بد أيضا من تعيين النوع الذي يتجر فيه ، وأن يوجد في جميع الأجل
، وأن يكون مديرا لا محتكرا ؛ لأن المحتكر يرصد الأسواق فيؤدي إلى أجل
مجهول فيدخل الجهل في الثمن ؛ لأن الثمن مجموع النقد والعمل ، وأن لا يتجر
له في الربح ؛ لأن الربح مجهول فهذه سبعة شروط علم الثمن المتجر فيه
ووجوده في الأجل والإدارة ، وعدم التجر في الربح تؤخذ من المصنف بالقوة ،
ولما كان هناك شرط ثامن لا يؤخذ منه صرح به بأداة الشرط بقوله (إن شرط
الخلف) لما يتلف من الثمن ليتم العمل الذي هو جزء من الثمن ، وإلا أدى إلى
الغرر ومثله في الجواز مع شرط الخلف قوله^(١) ...

(١) الشرح: أشار المصنف في النص السابق إلى مسألة مشتملة على بيع وإجارة، فيجوز
للبيع أن يبيع السلعة لآخر بثمن معلوم كمائة أي وهي تساوي أكثر منه على أن يتجر
المشتري للبائع في ثمنها مدة سنة - أي مدة معلومة - .

وصورتها: شخص باع سلعة لآخر تساوي مائة وخمسين مثلا بمائة على أن يتجر له سنة
فقال الأمر أن ثمن السلعة مائة دينار وعمل سنة فيها، لجواز هذه المسألة ثمانية شروط هي:

- ١- أن يكون الثمن معلوما.
- ٢- أن يكون العمل إلى أجل معلوم.
- ٣- أن يعين النوع الذي يتجر فيه.
- ٤- أن يكون موجودا في السنة.

-
- ٥- أن يحضر الثمن ليخرج من ذمته.
- ٦- أن يكون مديراً؛ لأن المحتكر يبيع إذا غلت السلع، وذلك يؤدي إلى الأجل المجهول.
- ٧- أن يشترط الخلف، وإلا أدى إلى الغرر.
- ٨- ألا يشترط ألا يتجر له في الربح لأن الربح مجهول.

حكم الاستئجار على رعي غنم بشرط الخلف

قال المصنف: (كغنم) أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم (عينت) إن شرط الخلف لما يتلف منها لا إن لم يشترطه فلا تصح وله أجر مثله (وإلا) تكن معينة فلا يشترط للجواز شرط الخلف بل يصح العقد بدونه وحينئذ (فله) أي للراعي (الخلف على أجره) أي يقضى له بالخلف على رب الغنم، أو دفع جميع الأجرة (كراكب) تشبيهه في قوله فله الخلف أي أن الراكب إذا تعذر ركوبه لموت، أو مرض، أو حبس لم تنفسخ الإجارة ويلزمه، أو وارثه الاتيان بالخلف، أو دفع جميع الأجرة^(١).

(١) الشرح: يجوز للشخص أن يستأجر شخصا يرعى له غنما بعينها سنة بأجرة معلومة بشرط أن يشترط الراعي في العقد على ربه، أن ما مات من الغنم، أو ما تلف منها أخلفه، أو جرى العرف بالخلف، فإن لم يشترط الخلف في العقد لم يجز، فإن امتنع رب الماشية من الخلف أخذ الراعي جميع الأجرة.

وكذلك راكب السفينة إذا تعذر ركوبه فإن الإجارة لا تنفسخ ويلزمه، أو ورثته إن مات أن يأتوا بخلفه، أو يدفعوا جميع الأجرة فهو تشبيهه في الخلف أي كما يجب خلف الراكب إذا تعذر ركوبه، ولا يفسخ الكراء؛ لأنه مما يستوفي به، أما إذا كانت الدابة غير معينة كأن استأجر دابة غير معينة ليركبها لموضع كذا فهلكت فعلى المكري خلفها.

تابع صور من الإجارة الجائزة

قال المصنف: (و) جاز استئجار (حافتي نهر ك ليبي) عليها المستأجر (بيتا) ويصير النهر تحت سقف ذلك البناء ، (و) جاز استئجار (طريق في دار) للمرور فيها لحاجة ، (و) جاز استئجار (مسيل) أي موضع سيلان، (ومصب مرحاض) أي مصبوب أي ما يصب من الفضلات فالمسيل اسم مكان، وهو المجرة ، والصب بمعنى اسم مفعول ، والمرحاض محل الرحض أي الطرح كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة ، أو ما يجتمع في ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها (لا ميزاب يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب ؛ لأنه يقل ويكثر ويكون مملوكا لك ومستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزلت منه (في أرضه) ليخرج إلى الخارج فيجوز ويكون كمسيل مصب مرحاض ، أو ميزاب لا شراء مائه ، (و) جاز (كراء رحي ماء) أي تدور بالماء (بطعام أو غيره) للطحن عليها^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف صوراً من الإجارة الجائزة، فقال : يجوز للإنسان أن يؤجر حافتي نهر لشخص ليبنى عليه بيتاً ، أو لنصب رحي عليها ويصير النهر تحت البناء، ولا يشترط هنا وصف البناء، مما يبنى به من حجر، أو آجر مثلاً مما يثقل أو يخف، أما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر، وكذلك يجوز لك أن تستأجر طريقاً في دار رجل لتتوصل بها إلى منافعك أو ما تريد ، وإلا لم يجز ؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل ؛ لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة باطلاً ؛ لعدم انتفاعه بالطريق.

وقول المصنف: دار لا مفهوم له ؛ لأن المراد الطريق في أرض غيرك سواء كانت داراً، أو أرضاً ، أو بستاناً أو نحو ذلك.

وقول المصنف: ومسيل مصب مرحاض الثلاثة المذكورة اسم مكان، فمسيل اسم للمكان الذي يسيل فيه الماء كالمجرة، ومصب اسم للمكان الذي يصب فيه الماء، أي يجوز استئجار مكان لصب الماء فيه، ومصب مصدر ميمي بمعنى انصباب، ومرحاض من الرحض وهو الطرح كالكنيف، أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة ونحوها . فيجوز استئجار محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة، كما هو موجود في مصر من استئجار مجراه يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل بالمجاري، وكذلك يجوز استئجار أرض لوضع الفضلات فيها.

ثم ذكر المصنف أنه لا يجوز شراء ماء ميزاب؛ لأنه يقل ويكثر، ويكون أولاً يكون، إلا أن يكون الميزاب لمنزلك بأن يكون مملوكاً لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه في أرضه ليخرج إلى الخارج دار الجار ويستقر في أرضك فيجوز، وتكون هذه المسألة كمسألة مصب المرحاض لا فرق بينهما، والاستثناء منقطع لأن هذا استئجار، والمستثنى منه بيع...

ذكر المصنف أن من كانت له رحي تدور بالماء يجوز له أن يكرها بالطعام أو غيره للطحن عليها.

حكم الإجارة على تعليم القرآن الكريم

قال المصنف: (و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلا ككل شهر بدرهم ، أو كل سنة بدينار ، (أو على الحِذاق) بكسر الحاء ، والذال والمعجمة أي الحفظ لجميعه ، أو جزء معين بأجر معلوم . وأشار بأو إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما وهو المشهور إذ قد يمضي الشهر ولا يحفظ ما عينه، أو يحفظه في أثنائه، (وأخذها) المعلم أي يأخذ الحذقة بمعنى الاصرافه ففيه استخدام كذا قيل أي يقضى بها للمعلم على ولي الطفل ،أو على القارئ الرشيد (وإن لم تشترط) ، ومحلها ما تفررت فيه عرفا من السور كسبح ، وعم ، وتبارك، وغيرها ، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وقد تختلف باختلاف الزمان ، والمكان وقد تختلف باختلاف الأشخاص فقرا، وغنى^(١).

(١) الشرح: تجوز الإجارة على تعليم القرآن الكريم، وتعليم علومه من تجويد، وقراءات، والإجارة على تحفيظ القرآن الكريم على نوعين:

١- مشاهرة أب كلما مر شهر على التحفيظ استحق الشيخ أجرته حتى ولو لم يستوعب الطالب شيئا.

٢- على الحذق أي على الحفظ لكل، أو لبعض أجزاء المصحف حسبما يقضى به العرف، أو الشرط فكلما حفظ الجزء المتفق عليه أخذ الشيخ أجرته المتفق عليها.

لا يجوز الجمع بين الطريقتين السابقتين؛ لأن الطلاب يتفاوتون في الحفظ فقد يمضي الشهر ولا يحفظ الطالب شيئا فيكون في ذلك إححاف بالشيخ، وقد يكون الطالب ذكيا سريع الحفظ يحفظ الجزء المطلوب منه في مدة وجيزة فيكون في ذلك إححاف بوليّه.

وإذا اتفق على أجر وجب دفعه إلى الشيخ بل ويقضى بها على الطالب، أو وليّه، وإن لم ينص عليها في العقد.

إجارة ما يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية

قال المصنف: (و) جاز (إجارة ماعون) أي ما يستعان به (كصفحة وقدر) وفأس، ودلو كان مما يعرف بعينه أو لا^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى جواز إجارة الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية، ويقاس عليها جواز الإجارة لكتب العلم، أو أسطوانات علمية للطلاع عليها، وسائر الأشياء النافعة التي يحتاج إليها الإنسان في حياته.

الإجارة على حفر بئر

قال المصنف: (و) جاز العقد (على حفر بئر إجارة ، وجعالة فالإجارة فيما يملك من الأرض ، وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول ، وعرض كخمسة أذرع في خمسة ، والعمل عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل ، والجعالة فيما لا يملك فقط ، ولا بد من الوصف كالإجارة ، وإنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها ، أو بقول ولك بتمام العمل كذا ، والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا سيحصل للجاعل فيه نفع حين الترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ، ولا تصح الجعالة فيه ، فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد^(١).

(١) الشرح: تجوز الإجارة على حفر بئر، وإقامة المباني التي توصف وصفا دقيقا ببيانها بالرسم الموضح للمشروع، بيانها كافيا طولا، وعرضا وعمقا وغير ذلك، سواء كانت الأرض مملوكة للمؤجر، أو لم تكن مملوكة له، فالعقد في الصورة الأولى إجارة جائزة إذا دخلا على تعيين العمل، ويستحق الما قول، أو العامل الأجر بمجرد الفراغ من المشروع، أو مضي مدة من تمكين نفسه أن يحفر فيها البئر، أو يقام فيها البناء؛ لأن التمكين من الانتفاع كالانتفاع بالفعل، وإذا انهدم البناء أثناء العمل ، فإذا كان الانهدام بتقصير من المستأجر كما لو خالف ما هو مشروط أو ما هو متعارف عليه بين أهل الصنعة ، فإنه يضمن هذا الانهدام. أما إذا انهدم البناء ولم يكن هناك تقصير أخذ من الأجرة مقدار ما يستحقه عن المرحلة التي عمل فيها أو أقامها.

أما الصورة الثانية: وهي كون الأرض ليست مملوكة للمؤجر فإن العقد تارة يكون إجارة، وتارة يكون جعالة فيكون إجارة إذا دخلا على بيان المشروع المراد عمله ببيان كافيا مع وجود شرط يلزم المؤجر بالأجر، وقد يكون جعالة إذا صرح بها في العقد، أو قامت قرينة على إرادتها بأن يقول له لك بتمام عملك كذا، ففي هذه الصورة فإن العامل يكون له الحق في ترك العمل في أي وقت ولا يستحق شيئا، وكذا لو انهدم المشروع لا يستحق شيئا على ما مضى من عمل وكان التلف بلا تعد أو تقريط فلا ضمان عليه. (تعريف الجعالة هي: التزام

أهل الإجارة جعلاً يستحقه السامع بالتمام. الشرح الكبير شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردى ج ٤، ص ٦٠، ٦١). (موات الأرض هي: ما سلم عن الاختصاص، الشرح الكبير شرح مختصر خليل ج ٤، ص ٦٦، شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ٦٦).

الفرق بين الإجارة والجعالة هنا: أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل فيه نفع للجاعل حين الترك لو ترك، بخلاف الإجارة، ولهذا لا يجوز أن يجاعله إلا على حفر بئر في الموات.

مكروهات الإجارة

قال المصنف: ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله: (ويكره حلي) أي إجارته بذهب، أو فضة أو غيرهما نقداً أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع (كإيجار مستأجر دابة) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها لمثله خفة وأمانة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط، أو مات، وأما لو استأجرها للحمل عليها فيجوز كراؤها لحمل مثله كما يفيد مما يأتي قوله وفعل المأذون فيه لا أضرب (أو ثوب) أي يكره لمن استأجر ثوباً للبس أن يكره (لمثله) ولكونه مما يغاب عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني؛ لأن ضمان التهمة يزول بالبينة، ومحل الكراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكري، وأما إن علم رضاه فجائز وإن علم عدم رضاه لم يجز، (و) كره (تعليم فقه، وفرائض) بأجرة مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو، وبيان كذلك، وأما تعليم علم الفرائض بالرسم فلا يكره (كبيع كتبه) أي ما ذكر، وكذا كتب الحديث، والمصاحف، والتفسير، (و) كره (قراءة بلحن) أي تطريب بأنغام حيث لا يخرج عما عليه القراء، وإلا حرمت كقراءة بالشاذ وقد تقدمت المسألة في سجود التلاوة، والمناسب هنا كراهة الإجارة على القراءة، (و) كره (كراء دَف) بضم الدال، وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغريال، (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهيته (لعرس) أي نكاح، وقيل هي جائزة في النكاح، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها، والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع الكراهة، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فبحرم كراؤها، (و) كره (كراء كعبد كافر) المتبادر منه أن كافر نعت لعبد، وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر أو تقديم كافر

على كعبد ، وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد وهو جائز على قلة ، والأصل كراء كافر عبدا ونحوه ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي يكره للمسلم أن يكره عبده أو نفسه ، أو ولده لكافر حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يده ن ولم يكرهه في فعل محرم فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز ، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر حرم وفسخت وله اجرة ما عمل وكذا إن استأجره على محرم كخمر ، ورعي خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له ، (و) كره (بناء مسجد للكرء) أي لأخذ اجرة ممن يصلي فيه ؛لأنه ليس من مكارم الأخلاق، والمشهور عدم الجواز ، (و) كره (سكنى) بأهله (فوقه) أي المسجد إن بني للسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم كم يأتي في الموات في قوله وكمنع عكسه فلا معارضة، وأشار للركن الثالث...^(١)

(١) الشرح: صور من الإيجارات المكروهة:

إجارة الحلي، قال المصنف: ولما تكلم على الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله: (ويكره حلي) أي إجارته بذهب، أو فضة أو غيرهما نقداً أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع.

الشرح: لما فرغ المصنف من صور الإيجارات الممنوعة، والجائزة شرع في سرد بعض صور من الإيجارات المكروهة وبيانها كالآتي:

الحلي هو الذهب، أو الفضة تتحلى بهما المرأة، يكره إجارة الحلي.

وجه الكراهة؛ لأنه ليس من شأن الناس، والأولى إعارته؛ لأنها من المعروف، وأن السلف كانوا يرون إعارته من غير أجر، وعلل بعض فقهاء المذهب أن علة الكراهة أن الحلي قد تنقص قيمته باستعمال المستأجر فتقل قيمته فيكون ما نقص من القيمة مقابل الأجرة النقدية يبيع نقد بنقد ، ولما كان النقصان غير محقق كانت الإجارة مكروهة مقيدة بألا يكون المستأجر يحرم عليه لبس الحلي المستأجر فإن كان المستأجر يحرم عليه لبس الحلي المستأجر تمتع إجارته ؛لأنه سيكون من يباب الإعانة على الإثم وهو منهى عنه بمقتضى قوله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"

إيجار الدابة المستأجرة والثياب المستأجرة

قال المصنف: (كإيجار مستأجر دابة) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها لمثله خفة وأمانة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط، أو مات، وأما لو استأجرها للحمل عليها فيجوز كراؤها لحمل مثله كما يفيد مما يأتي قوله وفعل المأذون فيه لا أضر (أو ثوب) أي يكره لمن استأجر ثوبا للبسه أن يكرهه (لمثله) ولكونه مما يغاب عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني؛ لأن ضمان التهمة يزول بالبينة، ومحل الكراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكري، وأما إن علم رضاه فجائز وإن علم عدم رضاه لم يجز^(١).

(١) الشرح: يكره لمن استأجر سيارة للركوب، أن يكرهها لمثله سواء في الأمانة، أو الخفة، أو النقل أو، الحفاظة والغلظة، ولا ضمان عليه إن تلفت للدابة، أو ماتت بلا تفريط. فإن كان الأول هو اللفظ فلا ضمان بالأولى، وإن كان الثاني هو اللفظ ضمن، ومحل الكراهة إذا لم يعلم حال رضى ربها وعدمه.

ومثل الدابة: الثوب فيكره لمن استأجر ثوبا للبسه أن يكرهه لمثله، ويقال فيه: ما قيل في الدابة إلا أنهما يفترقان في الضمان، فإن الدابة لا ضمان فيها إن ضاعت بلا تفريط، أو ماتت، وأما الثوب فيضمنه -أي: الأول- إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني؛ لأن ضمان الأول ضمان تهمة لا ضمان عداء، وضمان التهمة يزول بالبينة.

الإجارة على تعليم الفقه والفرائض

قال المصنف: (و) كره (تعليم فقه، وفرائض) بأجرة مخافة ان يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو، وبيان كذلك، وأما تعليم علم الفرائض بالرسم فلا يكره (كبيع كتبه) أي ما ذكر، وكذا كتب الحديث، والمصاحف، والتفسير^(١).

(١) الشرح: ذكر المصنف أن من صور الإجارة المكروهة الإجارة على تعليم الفقه والفرائض، كما يكره بيع كتب الفقه، والفرائض، وعلة الكراهة أن أخذ الأجر يؤدي إلى قلة الإقبال عليها وأما تعليم علم الفرائض بالرسم فلا يكره أخذ الأجرة عليه؛ لأنه صنعة من الصنائع.

يكره الإجارة على تعلم الشعر. وخالف في ذلك ابن حبيب فقال: بجواز تعلم الشعر، وأيام العرب والرسائل ونحوها، مما يليق بذوي المروءات، ويمنع شعر الهجاء، والخمر والخنا.

قراءة القرآن بلحن وتطريب

قال المصنف: (و) كره (قراءة بلحن) أي تطريب بأنغام حيث لا يخرجها عما عليه القراء، وإلا حرمت كقراءة بالشاذ وقد تقدمت المسألة في سجود التلاوة، والمناسب هنا كراهة الإجارة على القراءة^(١).

(١) الشرح: تكرر الإجارة على قراءة القرآن الكريم بلحن تطريب وأنغام؛ لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن حده، وإلا حرمت، كالقراءة بالشاذ، والقراءة الشاذة ما زاد على العشرة، وهو الراجح، والمراد بالتطريب تقطيع الصوت بالأنغام والأهوية، وتقدمت مسألة كراهة قراءة القرآن الكريم بتطريب وأنغام وأدلتها في سجود التلاوة، وذكرت هنا لبيان كراهة الإجارة على ذلك.

ووجه كراهة قراءة القرآن الكريم بالتطريب: أن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينافي ذلك.

إجارة المعازف والدقوف في العرس

قال المصنف: (و) كره (كراء دُف) بضم الدال، وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغريال، (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهيته (العرس) أي نكاح، وقيل هي جائزة في النكاح، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها، والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع الكراهة، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فيحرم كراؤها^(١).

(١) الشرح: تكره إجارة الدف ومعزف في النكاح، والدف طبل مغشي من جهة يسمى في العرف بالطار، والمعزف آلة اللهو فيشمل المزمار، ولا يلزم من جوازها في النكاح جواز أخذ الأجرة عليها. والراجح أن الدف والكبر جائزان في العرس مع الكراهة، وأن المعازف حرام في غير النكاح فيحرم كراؤها.

وهذا القول مبني على الكراهة سماع المعازف في العرس، وقيل سماعها في العرس جائز، أما في غير العرس فالمذهب على حرمتها.

إيجار مسلم نفسه أو ولده لكافر

قال المصنف:

(و) كره (كراءُ كعبد كافرٍ) المتبادر منه أنَّ كافر نعت لعبد وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر، أو تقديم كافر على كعبد، وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد وهو جائز على قلة، والأصل كراء حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يده، ولم يكثره في فعل محرم، لا إن لم يستبد بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم، والكافر فيحوز، وإن كان تحت يده كأجير لخدمة بيته، وظئر حرم، وفسخت وله أجرة ما عمل، وكذا إن استأجره في فعل محرم كعصر خمر، ورعي خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له^(١)

بناء مسجد للكراء، والسكنى فوقه

(١) الشرح: يكره للمسلم أن يؤاجر نفسه، أو ولده، أو عبده المسلم، أو دابته لكافر فيما يحل، كخياطة ثوب، وبناء، وحرث، وما أشبه ذلك إذا كان الكافر يستبد بالمسلم. أما إذا أجر المسلم نفسه لكافر فيما لا يحل كعصر خمر، ورعاية خنزير فيحرم، وترد الإجارة قبل العمل، أما بعد العمل فتفسخ الإجارة، ويتصدق بالأجرة أدبا للمسلم، إلا أن يعذر لأجل جهل فلا تؤخذ منه.

وكذلك إذا كان العمل فيه إهانة للمسلم، بحيث يكون تحت يده خادما له في بيته، ويقدم له الطعام، ويغسل يديه، ويجرى خلفه، ومرضعة لولده، يحرم ويفسخ العقد، وله أجر ما عمل.

وأما إذا لم يكن الكافر مستبدا بعمل المسلم، بحيث يكون المسلم في حانوته كخياط، ويأتيه الكافر والمسلم فيجوز.

قال المصنف: (و) كره ممن يصلي فيه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، والمشهور عدم الجوار، (بناء مسجد للكراء) أي لأخذه (سكنى) بأهله (فوقه) أي المسجد إن بنى المسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم كما يأتي له في الموات في قوله ومنع عكسه فلا معارضة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى أنه يكره بناء مسجد ليكره لمن يصلي فيه، ويأخذ الأجرة ممن يصلي فيه، فالمشهور في المذهب أنه غير جائز؛ لأنه حبس لله لا يباع ولا يكرى، وعن القاضي عياض أنه مكروه، وعلل الكراهة بأنه ليس من مكارم الأخلاق. وكذلك لا يجوز لو بناه الله تعالى ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلي فيه؛ لأنه خرج عنه الله تعالى أي كان حبسا لا حكم له، ولا لأحد فيه؛ والحبس لا يباع ولا يكرى. (شرح الخرشي على مختصر خليل، ج ٧، ص ٢٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي بهامش الشرح الكبير، ج ٤، ص ١٩).

أما السكنى فوق المسجد المعد للكراء بالأهل -أي الزوجة- مكروه؛ لما فيه من إذلال المسجد بوطء أهله فوقه.

أما إذا كان المسجد غير معد للكراء وتم وقفه يحرم السكنى فوقه بأهله.

أما لو كانت السكنى للعبادة بمفرده فجائز كما ذكر المصنف في باب إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه.

أما السكنى تحت المسجد فجائز مطلقا سواء كانت السكنى بمفرده أو بأهله، بني المسجد للعبادة، أو لغيره.

الركن الثالث (المنفعة)

قال المصنف: وأشار للركن الثالث بقوله (بمنفعة) متعلق بأجر، والباء بمعنى في، أي وصحت الإجارة بعاقده، وأجرني مقابل منفعة لها شروط أشار لها بقوله (تتقوم) لأي لها قيمة شرعا لو تلفت احترازا عن رائحة الرياحين ونحوها فلا يجوز استئجارها للشم، وكذا البساتين ونحوها للفرجة، والدنانير ونحوها لتزيين الحوانيت، والجدران للاستغلال، والسراج للاستصباح، وكذا آلات اللهو، وتعليم الأنعام إذ لا قيمة لها شرعا، فلا تصح إجارة ما ذكر وتفسخ إن وقعت ولا أجرة، (قدر على تسليمها) فلا يجوز استئجار آبق، أو بغير شارد أو أي شيء غير مملوك للمؤجر، أو بعيد غيبة ونحو ذلك (بلا استيفاء عين) احترز من نحو استئجار شجر لأكل ثمره، واستثنى من ذلك مسألة الظئر للرضاع (ولا حظر) احترز عن استئجار شخص لعصر خمر أو رقص ونحو ذلك من كل منفعة محرمة (و) بلا تعين يأتي بيانه ومحترزه (ولو مصحفا) للقراءة فيه فيصح إجارته له، ويجوز ابتداء خلافا لابن حبيب، (و) لو (أرضا غمر) أي كثر (ماؤها ونذر انكشافه) هو محل المبالغة إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف، (و) لو (شجراً لتجفيف) نحو ثياب (عليها)؛ لأن الانتفاع بها على هذا الوجه لا تتأثر به، وينقص قوتها فهي منفعة تتقوم، وقوله (على الأحسن) بغني عنه المبالغة، ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من القيود فذكر محترز بلا استثناء عين قصدا بقوله (لا) استئجار شجر (لأخذ ثمرته أو) استئجار (شاة للبنها) أي لأخذه فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن شاة، أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة في إبان الحلاب مع معرفة وجه حلابها لأجل لا ينقص اللبن فيه، والشروع في الأخذ يوم العقد أو قبله

فيجوز وكذا إن وقع على الكيل ككل يوم رطلين من لبن شياهاك بكذا (واغتفر) اشتراط إدخال (ما في الأرض) المكترة وجيبة من الشجر المثمر (مالم يزد) ما فيها أي قيمته (على الثلث) أي ثلث الجميع فإن زاد لم يغتفر ، وتفسخ الإجارة ويعتبر الثلث (بالتقويم) ولا يعتبر ما أكرت به لأنه قد يزيد وينقص فيقال ما قيمة الأرض ، أو الدار إذا أكرت بلا شجر مثمر فيقال عشرة ، فيقال وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد اسقاط كلفتها فيقال خمسة ، أو أقل فقد علم أنه الثلث ، أو أقل ، ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء ، وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر ، وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكرت مشاهرة لم يجز إدخال شيء ، وذكر مفهوم لا حظر بقوله (و) لا (تعليم غناء) بكسر الغين والمد (أو دخول حائض لمسجد) أي لخدمته (أو دار لتتخذ كنيسة) أو مجمعا لفساق ، أو خمارة (كبيعها لذلك) ويفسخ متى اطلع عليه (وتصدق بالكراء) جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء (وبفضلة الثمن) في بيعها لذلك (على الأرجح) أي بزائد على الثمن لو بيعت لمباح وكذا بزائد الكراء للأرض إذا أكرت لو أكرت لجائز ، وذكر محترز تعين بقوله (ولا) تجوز الإجارة على (مُتَعِينٍ) أي مطلوب من كل شخص بعينه ، ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرض (كركعتي الفجر بخلاف الكفاية) كغسل ميت أو حمله فيصح الاستئجار عليه مالم يتعين بخلاف صلاة الجنازة عليها مطلقا (وَعَيْنٌ) في عقد الإجارة وجوبا (متعلم) لقراءة ، صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة (ورضيع) ؛ لاختلاف

حاله بكثرة الرضاع وقتله (و) عين (دار حانوت) ، و حمام ، وخان ونحوهما إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى ركن المنفعة: وهي المعقود عليها في عقد الإجارة وهي المقصود الأول منها.

ويشترط فيها:

١- أن تكون لها قيمة شرعا لو تلفت، ومعنى ذلك أن تكون مملوكة ملكية خاصة، فلا تستأجر الروائح لمجرد الشم، وكذلك شم الرياحين؛ فإن صاحب الرياحين والروائح لا يمكنه منع رائحتها، أما الجلوس داخل البستان الذي فيه الرياحين فله استئجاره، وكذلك الاستدفاء بنار إذا كان إدفائها خارج ملكه، وكون شيء له قيمة أو ليس له قيمة مرجعه إلى العرف، فقد يكون الشيء له قيمة في بلد، وقد لا يكون له قيمة في بلد آخر.

٢- ويشترط فيها أن تكون مقدورا على تسليمها للمستأجر حسا، وشرعا، فلا يجوز استئجار حيوان شارد أو شيء مغصوب، أو غير مملوك للمؤجر، وكذلك لا يجوز استئجار شخص لقتل غيره بغير حق.

٣- ألا يترتب على استيفاء المنفعة استيفاء العين قصدا، فلا يجوز استئجار الشجر لأكل ثمرة.

٤- أن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز استئجار شخص على الرقص، أو عصر الخمر ونحو ذلك من كل منفعة محرمة، وكذلك لا تجوز إجارة الحائض، والجنب، والكافر لخدمة المسجد؛ لأنه يترتب على استيفاء المنفعة المعقود عليها الحظر، وكما يمنع تقرير النساء في الوظائف التي لا تتأتى شرعا إلا من الرجال كالإمامة، والخطابة، والأذان فتقريهن فيه باطل؛ لأن شرط التقرير أن يكون المقرر أهلا لما قرر فيه.

وكذلك لا يجوز كراء دار لتتخذ كنيسة، أو مجمعا لفساق، أو خمارة، ويفسخ العقد متى اطلع عليه، ويتصدق بالكراء جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجار للدار، وبما ينوب من الزمن الذي اطلع عليه في الأثناء.

٥- ألا تكون من القربات المعينة على المكلف، فلا يجوز استئجار شخص ليصوم عن غيره، أو يؤدي الصلاة المفروضة عنه حتى ولو كانت نفلا كركعتي الفجر؛ لأن هذه العبادات متعينة على الشخص ولا تقبل النيابة، ويشترط في الفرض المتعين الذي لا يصلح محلا للنياحة فيه لعقد الإجارة ألا تجوز النيابة فيه، فإذا كان مما تجوز فيه النيابة كما هو

الحال في الزكاة، والحج فتجوز الإجارة عليه، وعليه فتجوز الإجارة على الفروض غير المتعين.

٦- يشترط في المنفعة أن تكون معلومة علماً ينفي الجهل بها إذا كانت الجهالة تؤدي إلى المنازعة، فلا تجوز الإجارة على التدريس لأي طالب، أو العمل في أي عمل، وتعيين المنفعة تكون بتعيين محلها، والعلم بها.

ما يجب تعيينه في الإجارة

قال المصنف: (و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه فيذكر قدره طولاً، وعرضاً وكونه بطوب، أو حجر أو غيرهما بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبني فيها من كونه من حجر، أو طوب، (و) عين (محمل) بفتح أوله، وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشُقْدَفْ ، ومحفة لأنه يختلف باختلاف السعة والضيق ، والطول ، والقصر ، وأما بكسر أوله وفتح ثالثه فعلاقة السيف (أن لم توصف) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد ، (و) عينت (دابة) اكرت (لركوب) عليها بالإشارة الحسية أو بأل العهدية ، ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة (فجنس) أي فاللزم تعيين جنسها كإبل ، أو بغال (ونوع) أي صنف كعراب وبخت (وذكورة) أو أنوثة فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد ، والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب ، أو غيره لا بد في صحة الإجارة عليها من التعيين بالذات ، الوصف إلا أنها إذا عينت بالإشارة انفسخت الإجارة بتلفها وإلا فلا وعلى ربها بدلها ولو قال دابتك البيضاء ، أو الحمراء وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم يقل عليه ، أو التي رأيته معك بالأمس عينها ، وكلام المصنف لا يفيد ذلك فكان عليه أن يقول بعد قوله ومحل ودابة وسفينة ونحوها إن لم توصف بالإشارة وإلا فمضمونة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى ما يجب تعيينه في الإجارة، يجب تعيين ما يلي:

البناء على جدار استؤجر للبناء عليه بأن يذكر طول مت بنى عليه وعرضه، وكونه من حجر أو لبن أو غير ذلك، بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط وصف ما يبني عليها؛ لأنه لا يتعلق به غرض، بل يكفي علم المساحة.

ووجه الفرق بين الجدار يجب تعيين ما يبنى عليه، والأرض لا يجب ذلك فيها؛ أن الجدار يلحقه الضرر بكثرة البناء، بينما الأرض لا ضرر يلحقها بذلك وهذا الفرع مبني على جواز استئجار الحائط للبناء عليه.

- يجب تعيين المحمل المكترى للركوب فيه، وشقذف، ومحفة، وحجفة لأنه يختلف بحسب السعة والضيق، والطول، والقصر، والمتانة وغيرها.

- يجب تعيين المسكن، من دار أو غيرها، لاختلاف أحواله. وهذه المذكورات وحوها لا بد فيها من التعيين إن لم توصف وصفا شافيا، فالواجب إما التعيين، أو الوصف الشافي المفيد للمراد، وإلا كانت إجارة فاسدة.

- يجب تعيين الدابة المكترة للركوب أو الحمل، فيجب فيها التعيين ولا يكفي فيها الوصف، إلا الدابة المضمونة في الذمة ليتوصل بها إلى محل معين، وذلك إن لم تقصد عينها، فالواجب تعيين نوعها كإبل وبغال، وصنفها كعراب أو بخت، وذكرورة أو أنوثة لأن الوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين.

والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره: لا بد في صحة العقد عليها من التعيين بالذات أو بالوصف إلا أنها إذا عينت بالإشارة كدابتك هذه أو التي كانت معك بالأمس انفسخت الإجارة بتلفها، وإلا فلا تفسخ الأجرة وعلى ربه بدلها، فغير المعينة بالإشارة مضمونة، وعلى ربه بدلها إن تلفت، وإلا انفسخت بتلفها.

إجارة الأجير نفسه في عملين في وقت واحد

قال المصنف: (وليس لراع) استؤجر على غنم (رعي) غنم (أخرى) معها (إن لم يقو) على رعي الأخرى معها لغير ربها لكثرتها (إلا بمشارك) يعاونه فله رعي أخرى مع الأولى، (أو تقل) الأولى بحيث يقوى على رعي الأخرى معها (ولم يشترط) عليه ربُّ الأولى (خلافه) أي عدم رعي غيره فله رعي أخرى ومفهومه أنها إن قلت واشترط ربها عليه عدم رعي غيرها لم يجز له رعي الأخرى ، وإليه أشار بقوله (والا) بأن شرط خلافه أي عدم رعي غيرها معها (فأجرة) لما رعى من غيرها (لمستأجره) أي رب الغنم الأولى (كأجير لخدمة أجر نفسه) حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه ، أو بعضه فأجرته تكون لمستأجره الأول إن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته ، فإن لم يفوت عليه شيئا بأن وفى له بجميع ما استأجره عليه فلا كلام له ، وفهم من قوله فأجره لمستأجره ، وقوله أجر نفسه أنه لو عمل مجانا فإنه يسقط من كرائه بقدر قيمة ما عمل^(١).

(١) الشرح:

أجير الغنم، إذا استؤجر أجير لرعي بقر، أو بقر، أو إبل أو غيرها عينت له كهذه، أم لم تعين كعشرة من الغنم مثلا، فله أن يرعى غنما أخرى معها إن قوي على رعي الأخرى، ولو بمشارك يعينه على رعي الأخرى، وذلك إن لم يشترط رب الغنم الأولى عدم رعي غنم أخرى مع غنمه، فإن اشترط عليه ألا يرعى معها أخرى لم يجز له، فإن خالف الراعي ورعى معها غيرها فأجرة الذي أخذه في نظير الرعي الأخرى لمستأجرة الأول ولو قوي الأجير على رعي الجميع ولم يفوت شيئا.

فإن فوت عليه شيئا فالمستأجر مخير بين أن يعطيه الأجرة التي عينها له ويأخذ الأجرة التي في نظير رعي الأخرى، وبين أن يسقط أجرة ما فوته الأجير عليه بأن ينقصه من الأجرة التي سماها له، وهذا في أجير الغنم.

على من تكون رعاية ما تلده الغنم

قال المصنف: (ولا يلزمه) أي الراعي (رعي الولد) الذي تلده الغنم فعلى ربها أن يأتي لها براع آخر لرعيها ويجعل للأول أجرة في نظير رعي الأولاد (إلا لعرف) فإنه يعمل به^(١).

وأما أجير الخدمة إذا استؤجر في خدمة نفسه في خدمة أخرى معها حتى فوت على المستأجر الأول ما استأجره عليه، أو بعضه فإنه مخير كما في أجير الغنم، فإن لم يفوت عليه شيئاً بأن وفي بعمل كل ما طلب منه فلا كلام لمستأجره بخلاف أجير الغنم.

ومما تقدم يتعلق بإجارة الأجير نفسه في خدمة أخرى فلو عمل عملاً مجاناً بدون أجر فإن المستأجر يسقط من أجره بقدر ما فوته. أي فليس هناك تخيير، فإن لم يفوت شيئاً فلا يسقط من أجره شيء.

(١) الشرح: لا يلزم الراعي رعي ما تلده الغنم بعد الإجارة فعلى ربها أن يأتي لها براع آخر يقوم برعي الأولاد، أو يجعل للأجير الأول أجرة في نظير رعيه، إلا إذا وجد شرط أو عرف فيعمل به، والشرط مقدم على العرف إن وجد. ووجه عدم لزوم رعي الراعي لما تلده الأمهات من الغنم عند عدم العرف والشرط، أن العقد لم يتناول ذلك، إذ الولد لم يكن موجوداً حين العقد، وفي ذلك مشقة على الراعي طرأت بعد ولادة الأمهات.

ويلزم الراعي الذي يأتي به أن يراعاها مع الأمهات؛ لئلا يتعب راعي الأمهات إذا فارقت أولادها، لا لمنع التفرقة لأنها خاصة بمن يعقل. والفرق بين راعي الغنم لا يلزمه رعيه وولد المرأة الذي وضعته في السفر يلزم الجمال حمله، أن الحاصل من أولاد الغنم، وحين العقد لا يوجد أولاد حتى يتناولها العقد، والضرر الحاصل للجمال مشقة الحمل، والولد كان محمولاً قبل وضعه فيستصحب.

ما يُعمل فيه بالعُرف

قال المصنف: (وَعَمَلٌ بِهِ) أي بالعُرف أيضا (في الخيط) في كونه على الخياط، أو على رب الثوب، (و) في (نقش الرحي) المستأجرة للطحن في كونه على الملك أو المستأجر، (و) في (آلة بناء) فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه، (وإلا) يكن عُرف فيما ذكر (فعلى ربه) أي رب المصنوع من ثوب، ودقيق، وجدار وذلك (عكس إكاف) بكسر الهمزة ككتاب، وتضم كغراب، والمراد به ما يركب عليه من برذعة، أو شيء أصغر منها (وشبهه) كسرج وحويه ولجام ومقود فيعمل فيها بالعرف، وإلا فعلى رب الدابة على المذهب، وحينئذ فحكم الإكاف وشبهه حكم الخيط وما معه إذ هو على ربه في الموضعين لا عكسه، وأجيب بأن مرادة العكس في التصوير لا الحكم وهو أنه في الأول مكتر وهذا مكر، (و) عمل بالعرف (في) أحوال (السير والمنازل)، وقدّر الإقامة بها (والمعاليق) جمع معلوق بصم الميم كعصفور، وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن، وزيت، وعسل (والزاملة) ما يحمل فيه المسافر حاجته من خُرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمنازل، وإلا فسخ الكراء، وأما المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم المكري حملها (و) في (وطائه) أي فراشه وأولى غطائه (بمحمل) حملا أو اتيانا فإن لم يكن عُرف لم يلزم المكري (وبدل) نقص (الطعام المحمول) بأكل أو بيع فإن لم يكن عُرف فعليه وزن الحمل الأول، وأما عكسه كما إذا استأجره على قنطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول (وتوفيره) أي الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع وأراد المكري تخفيفه عُمَل بالعرف (كنزع الطيلسان) بفتح اللام، وقد تكسر، وتضم (قائلة) أو ليلا أي أن من استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه

أن ينزعه في أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه (وهو) أي من تولى المعقود عليه، أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر بالفتح كراع ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى عدة مواضع يعمل فيها بالعرف منها:

يعمل بالعرف في كون الخيط على الخياط أو على رب الثوب، وفي كون نقش الرحي المستأجرة للطحن عليها على المالك أو المستأجر، وفي كون آلة البناء على البناء أو على رب الحائط. فإن لم يوجد عرف فعلى رب الشيء المصنوع وهو الثوب والجدار. ووجه كونه على رب الشيء المصنوع إذا لم يوجد عرف، أن لفظ الخياطة والبناء لا يقتضي إلا العمل. وأما نقش الرحا فإنه عند عدم العرف لازم لرب الرحي سواء كان هو صاحب الدقيق أو كان الدقيق لغيره. (العرف الصحيح): هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعي ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس عقد الاستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءاً من مهرها، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر. - كتاب علم أصول الفقه ص ٨٩، ط مكتبة الدعوة - الدليل السابع العرف - المكتبة الشاملة. (الذخرة للقرافي ج ٥، ص ٤٢٥، وجاء فيها "فإن فقدت العادة فعلى رب المال؛ لأن اللفظ لا يقتضي إلا العمل").

يعمل بالعرف في كراء الدابة في كون البرذعة والقنب والسرّج واللجام والمقود على رب الدابة أو المكتري. فإن لم يوجد عرف فعلى رب الدابة.

يعمل بالعرف في السير على الدابة المكترة ليلاً أو نهاراً، وفي باقي أحوال السير من كونه بالهويّنة أو حدر، أو متوسطاً، وفي المنازل التي ينزل بها في سير المسافة وقدر الإقامة بها ولا كلام لرب الدابة ولا المستأجر مع العرف.

فإن لم يكن عرف فلا بد في السير والمنازل من البيان وإلا فسد الكراء لعدم صحتها وفسخ لزيادة الغرر.

ويعمل بالعرف فيما يعلق بجانب الرجل مما يحتاج إليه المسافر في سفره من نحو سمن، وزيت، وعسل، وفي الزاملة. التي يضع المسافر فيها حاجته كخروج وكيس ونحوهما. الزاملة:

هي ما يحمل فيه، كالخرج ونحوه، الذخيرة ح ٥، ص ٤٢٧، وجاء فيها "قال صاحب التنبیهات: الزاملة ما يحمل فيها كالخرج ونحوه".

فإن لم يكن عرف فيما يعلق والزاملة فلا يلزم المكري حملها.
وقول المصنف وفي السير عطف على قوله وفي الخيط وكأنه أعاد الجار لبعده.

ويعمل بالعرف في فراش المحمل هل هو على رب الدابة أو على المكثري. فإن لم يكن عُرف لم يلزم المكري أي: رب الدابة الإتيان به.

ويعمل بالعرف في بدل الطعام نقص الطعام المحمول على الإبل إذا نقص بأكل أو بيع.
فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الأول.

ويعمل بالعرف في توفير الطعام المحمول بالكراء إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع ونازعه رب الدابة . فإن لم يكن عُرف فلا كلام لرب الدابة وعليه حمله إلى غاية المسافة ولو زاد الطعام ثقلاً كنزول مطر عليه، فقال سحنون لم يلزم المكري إلا زنة الحمل المشترك.
شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ٢٥.

ويعمل بالعرف في نزع ثوب مكثري للبس مثل القميص والعمامة والشال الذي يغطي به الرأس فيجب عليه نزعه في الأوقات التي جرى لعرف بنزعه فيها، كالليل والقائلة، فإن لم يكن عرف على عوام اللبس وإن اختلف العرف وجب البيان فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة.

الضمان في الإجارة

قال المصنف: (أمن فلا ضمان) عليه إن ادعى الضياع ، أو التلف كان مما يغاب عليه أولا ، ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت ولا يحلف غيره ، وقيل يحلف ما فرطت ، وبالع على عدم الضمان بقوله (ولو شرط) عليه (إثباته) أي الضمان (إن لم يأت بسمة الميت) فلا ضمان وإن لم يأت بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجره المثل سواء زادت على التسمية ، أو نقصت عند ابن القاسم إلا أن يسقط قبل الفوات ، وإلا صحت الإجارة ، والفوات هنا بانقضاء العمل فإسقاطه في أثناءه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة (أو عشر) أجبر حمل أو عثرت دابته (بدهن وطعام) أو غيرهما ، (أو) عشر (بأنية فانكسرت و) الحال أنه (لم يتعد) في فعله ولا سوق دابته فلا ضمان إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه ولم يصاحبه ولم تقم له بينة فيضمن ، (أو انقطع الحبل) فتلف المتاع المشدود به ، (ولم يغر بفعل) بأن لم يغر أصلا ، أو غر بقول فلا ضمان له إذ لا أثر للغر القولي كأن يأتي بشقة لخياط يقول له هل تكفي ثوبا فيقول نعم فيفصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط ، وإن علم عدم كفايتها ، نعم إن شرط عليه بأن قال له إن علمت أنها تكفي ففصلها ، وإلا فلا فقال تكفي فيضمن ومثال القولي أيضا أن يقول الصيرفي في دينار ، أو درهم أنه جيد وهو يعلم أنه ردي فلا ضمان ولو بأجرة ، وقيل بضمانه مطلقا ، أو قيل إن كان بأجرة واستظهر فإن غر بفعل ضمن كربطه بحبل رث أو مشيه بموضع زلق ، أو تعثر الدابة فيه وله الأجرة بحساب ما سار ككل متعد في المحمولات فإن لم يضمن فلا كراء له (كحارس) لدار أو بستان أو طعام ، أو ثياب أو غيرها لا ضمان عليه ؛ لأنه أمين ، إلا أن يتعدى أو يفرط ولا عبرة بما

شرط ،أو كتب على الخفراء في الحارث ، والأسواق من الضمان (ولو حماميا) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب مالم يفرط ، ومن التفريط مالم قال رأيت رجلا يلبسها فطننت أنه صاحبها ، (وأجير) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعة أم لا (كسمسار) يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه (إن ظهر خيرُهُ) أي أمانته (على الأظهر) وإلا ضمن (ونوتي) وهو عامل السفينة (عُرقت سفينتهُ بعمل صانع) في سيرها وحملها وإلا ضمن المال أو الدابة مالم يعتمد القتل وإلا قُتل (لا إن خالف) راع (مرعى شُرط) عليه فهلك أو ضاعت فيضمن أو (أنزى) الراعي أي أطلق الفحل على الإناث (بلا إذن) من ربها فيضمن إن عطبت تحت الفحل أو من الولادة إلا لعرف بأن الرعاة تنزى (أو غر) المكثري (بفعل) كقول انضم له شرط كما تقدم (فقيمته) أي يضمن قيمته (يَوْمَ التلف) في موضع التلف وله من الكراء بحسابه طعاما كان أو غيره قامت بينة بتلفه بالعثار ونحوه أم لا (أو صانع) يضمن (في مصنوعة) فقط أي فيما له فيه صنعة كحلي يصوغه وكتاب بنسخه، وثوب يخيطة ، وخشبه يصنعها كذا ثم يدعي تلفه أو ضياعه (لا) في (غيره) أي لا ضمان عليه فيه (ولو محتاجا له عمل) أي ولو كان الغير يحتاج عمل المصنوع له فيضمن مصنوعه فقط ؛لأنه أمين في ذلك الغير لا صانع فمن دفع لطحان قمحا في قفة ليطحنه له ، أو دفع لناسخ كتابا لينسخ له منه آخر فادعى ضياع الكل ضمن القمح دون القفة ، والكتاب المسوخ دون المنسوخ منه فأحرى في عدم الضمان مالا يحتاج له العمل، وبالف في ضمان على الصانع مصنوعه بقوله على ضمان الصانع مصنوعه بقوله (وإن) عمله الصانع (ببيته أو) عمله (بلا أجر) وسواء تلف بصنعه أو بغيرها إلا أن يكون في صنعه تغيير^(١)..

(١) الشرح: أشار المصنف إلى الضمان في عقد الإجارة، ويكون المستأجر والأجير لا

ضمان عليهما على النحو التالي:

- إذا ادعى الضياع أو التلف وكان مما يغاب عليه أم لا. ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما فرطت، ولا يحلف غير المتهم، وقيل: يحلف غير المتهم فيقتصر في يمينه على قوله ما فرطت، ولا يحلف على الضياع.

والفرق: أن غير المتهم إذا وقع منه ضياع إنما يكون من تفريطه فيكفي حلفه ما فرطت، وهناك قول ثالث: إنه كالمتهم يحلف لقد ضاع وما فرطت.

ولا ضمان على المستأجر ولا الأجير المذكورين ولو شرط عليه إثبات الضمان في العقد، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله (ولو شرط) عليه (إثباته)، ويفسد عقد الإجارة بهذا الشرط.

ووجه الفساد أنه شرط يناقض مقتضى العقد. فإذا وقع فله أجره المثل زادت على المسمى أو نقصت قاله ابن القاسم.

ومحل الفساد: إن لم يسقط الشرط قبل الفوات، وإلا صحت، والفوات هنا يكون بانقضاء العمل. فإسقاطه في اثنا عشر كإسقاطه قبله في إفادة الصحة. والحاصل أنه شرط مفسد للعقد ما لم يسقط لكن لو عثر عليه بعد العمل فله أجر مثله ولا يعمل بالشرط.

ومثل التلف والضياع في عدم الضمان للأجير إذا عثرت دابته بدهن أو غيره استؤجر لحمله، أو عثر بآنية فانكسرت، أو انقطع الحبل الذي ربط به الأمتعة فتلفت، فلا ضمان عليه. ووجه عدم الضمان أن الأجير معه الإذن ويده يد أمانة، وعدم الضمان مقيد بأمرين هما:

الأول: ما لم يتعد في فعله أو سوق الدابة، فإنه يضمن لتعديده، فإن كذبه ربه - بعد م تعديده - فلا يصدق في الطعام والإدام إلا ببينة ويصدق في غيره.
وعلة التضمن في الطعام والإدام ما فيهما من قوة التهمة، لكون الطبع يحث على أخذ الطعام ويميل إليه.

وأشار المصنف إلى تلك العلة بقوله إلا أن يتهم فلا يصدق ربه. وعلق على ذلك الشيخ محمد عرفة الدسوقي بقوله يؤخذ من هذا أن المستأجر بالفتح ليس بأمين في الطعام. والسفينة كالدابة في التفصيل بين حمل الطعام وعيره.

الثاني: مالم يغر بفعله. فإن غر بفعله ضمن، كريطه الأمتعة بحبل رديء رث أو مشيه بالدابة بمكان زلق، فإنه يضمن؛ لأنه مفرط. فإن لم يفرغ بفعله وغر بقوله فلا ضمان عليه؛ لأنه لا أثر للغرور القولي، كأن يأتي أحد بشقة لخياط ويقول له كأن كانت تكفي ثوبا ففصلها، فقال له تكفي ففصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط وإن علم عدم كفايتها، إلا أن يشترط عليه بأن قال له: إن علمت أنها تكفي ثوبا ففصلها وإلا فلا، فقال تكفي مع علمه بأنها لا تكفي فيضمن.

وتعليل الضمان هنا أنه لم يؤذن له في قطعه إلا بشرط أن يكون فيه ثوب، فإذا قطعه وجب عليه الضمان؛ لأن ذلك خيانة. ومن الغرر القولي، قول الصيرفي في دنانير أو دراهم إنها جيدة مع عمله إنها رديئة فلا ضمان عليه ولو بأجرة. وقيل يضمن مطلقا، وقيل إن كان بأجرة، واستظهر هذا القول.

حارس الدار، أو البستان، أو الزرع، أو حارس طعام، أو عرض لا ضمان عليه؛ لأنه أمين. ولو كان حماميا إلا أن يتعدى أو يفرط. ومن التفريط ما لو قال الحمامي رأيت رجلا يلبس الثياب فظننت أنه صاحبها. ومن التفريط نوم الحارس في وقت لا ينام فيه. ووجه تضمين الحمامي عند التفريط بإعطاء الثياب لغير صاحبها، أنه أخطأ عليه متاعه فدفعه إلى غيره، وأموال الناس تضمن بالعمد والخطأ.

وأما الغفراء في الحارات والأسواق فلا ضمان عليهم، ولا عبرة بما يكتب عليهم من أنه إذا ضاع شيء في دار يضمنونه؛ لأن ذلك التزام ما لا يلزم، ولا ضمان حيث ما لم يفرطوا كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، ونقله عنه الشيخ كريم الدين.

وأعلم ان أصل المذهب عدم تضمين الخفاء، والحراس، والرعاة، واستحسن بعض المتأخرين تضمينهم نظرا لكونه من المصالح العامة.

أجبر الصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه، وإلا ضمن؛ لأنه صار له حكم الصانع المشترك المنتصب للناس.

السمسار الذي يطوف بالسلع في الأسواق لبيعها، إذا كان خيرا ذا أمانه، لا ضمان عليه إذا ادعى ضياع شيء مما بيده بغير تعديه وبلا تفريط، وهذا في السلع قبل بيعها أوفي ثمنها إذا ضاع بعد البيع وفيما يحصل في السلع كالثوب من تمزيق، أو خرق بسبب نشر أو طي إذا لم يخرج عما أذن له فيه ويضمن كما إذا ادعى أنه باع سلعة لرجل وأنكر ذلك الرجل الشراء ولم يكن له برينة عليه لتفريطه بترك الإشهاد. وقيد بعضهم عدم الضمان من ظهر خيره بما إذا لم ينصب نفسه للسمسرة وإلا ضمن كالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد. وأمل من لم يظهر خيره فيضمن ن كذا افتى ابن رشد، وقيل: لا يضمن السمسار مطلقا قال عياض: وهو المعروف من قول مالك وأصحابه، قال: لأنهم وكلاء وليسوا صناع.

- النوتي إذا غرقت السفينة بفعل سائغ في تسييرها، وفي المشي بها في ربح أو موج بحسب المعتاد، وفي وسقها الوسق المعتاد فلا ضمان عليه في نفس ولا مال، وأولى إذا غرقت بغير فعل كهيجان البحر واختلاف الريح مع عجزه عن صرفها. وأن النوتي لا أجر له إذا غرقت أثناء المسافة، وكذا بعد تمامها، وقبل التمكن من إخراج الحمل، أما إذا غرقت بعد تمام المسافة، وبعد مضي مدة يمكن إخراج الأحمال منها فإنه لا ضمان على النوتي، وله الأجرة كاملة، ويجوز الطرح من السفينة عند خوف غرقها ويوزع ما طرح على مال التجارة فقط، ولا سبيل لطرح الأدمي ذكرنا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا خلافا للخي القائل بجواز طرح الأدميين بالقرعة؛ لأن هذا كالخرق للإجماع على أنه لا يجوز إماته أحد من الأدميين لنجاة غيره.

- وإن غرقت بفعل لا يسوغ في سيرها أو حملها ضمن، وإن تعدد الفعل فالقصاص، والعلة في تضمين النوتي التعدي، فحيثما غابت العلة فلا ضمان.

- المستأجر لدابة إذا ضربها أو ساقها بالعصا على الناس بغير خرق فعطبت لم يضمن لأن العرف جارٍ بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب على قدر الحاجة مأذونا فيه، فلم يضمن ما حدث عنه.

وفيما عدا ذلك يكون المستأجر والأجير ضامنا وذلك كما يلي:

- الراعي إذا خالف المرعى الذي شُـرط عليه، كأن يقال له لا ترعى إلا في المكان الفلاني فخالف ورعى في غيره أولا ترع في محل الجاموس فخالف ورعى فيه فتلفت فإنه يضمن.

ومحل الضمان إذا خالف مرعى شُـرط إذا كان بالغاً وإلا فلا ضمان لقول المصنف وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه.

- الراعي إذا أنزى الفحل على الإناث بلا إذن من ربها فعطبت، أو ماتت تحت الفحل أو عند الولادة فيضمن، إلا لعرف بأن الرعاة تنزي ولا تستأذن فلا ضمان اتفاقاً، أما إذا لم يجر عُرِف بشيء فقولان بالضمان وعدمه، والمعتمد الأول وعليه مشى المصنف، ومحل الخلاف إذا كان الفحل لرب الأنثى وإلا ضمن اتفاقاً.

- إذا غر بفعل فإنه يضمن كما تقدم، وكذلك إذا غر بقول انضم له شرط كما تقدم. وكل من الراعي وما بعده فالضمان يكون بالقيمة يوم التلف لا يوم التعدي ولا يوم الحكم.

- ويضمن الصانع في مصنوعة فقط لا غير، كثوب يخيطة، أو حلي يصوغه، أو خشبة ينشرها، أو حب يطحنه.

والفرق بين إيجاب الضمان على الصانع دون غيرهم من المستأجرين والأجراء لا يضمنون إلا بالتعدي؛ أن الأصل في قبض الصانع لأمتعة الناس هو على الضمان؛ لأنهم متهمون، بينما غيرهم الأصل فيهم ظانهم أمانة على ما يستأجرونه.

ولا ضمان على الصانع في غير مصنوعة، كما لو جعل الشيء المصنوع في ظرف فادعى الصانع ضياعها فإنه يضمن الصانع ما فيه الصنعة لا الظرف، ولو كان الصانع محتاجاً له في العمل فلا يضمنه، كقفة الطحين، والكتاب الذي يُنسخ منه، وهذا قول سحنون، وعمله بأنه لا عمل له فيه، وقال ابن حبيب: يضمن الصانع ما لا يستغني عنه سواء احتاج له الصانع أو المصنوع، وقال ابن المواز: يضمن الصانع ما يحتاج في عمله كالكتاب الذي

ينسخ منه دون ما يحتاج إليه المصنوع كظرف القمح والعجين، ووجه عدم تضمينه الظرف أنه باق عنده على حكم الوديعة.

ويضمن الصانع مصنوعه على ما تقدم ولو كان يصنعه في بيته دفعا لما يتوهم من عدم ضمانه في هذه الحالة ؛ لأنه لما عمل في بيته صار كأنه لم ينصب نفسه للعمل للناس. ودليل هذا القول المتوهم، هو ظان الأصل في الصانع عدم تضمينهم وأنهم مؤتمنون؛ لأنهم أجراء، وقد أسقط الشرع عن الأجير الضمان فأخرج أهل العلم الصانع من ذلك لنصيبهم أنفسهم لأعمال الناس وأخذ أمتعتهم، وإذا لم ينصب نفسه على الأصل، يسقط عنه الضمان. ويضمن الصانع أيضا ولو كان يصنعه بلا أجر، فأولى لو صنعه بأجر في حانوته.

شروط تضمين الصناع

قال المصنف: ... إلا أن يكون في صنعته تغير كثقب اللؤلؤ ، وتقش الفصوص وتقويم السيوف وكذا الختان والطب فلا ضمان إلا بالتفريط ، وأشار لشروط ضمان الصانع بقوله (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو جماعة مخصوصة ، (وغياب عليها) أي على السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ربها ، وبغير بيته ، فإن صنعها ببيته ولو بغير حضوره ، أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقة أو تلف بنار مثلاً بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغير كما مر ، ويشترط أيضاً أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله صيده للمعلم فيدعي هروبه فلا ضمان عليه ، وهذا غير قول المصنف وغياب عليها ، وإذا ضمن الصانع (فبقيته يوم دفعه) إلا أن يرى عنده بعده فلاخر رؤية إلا أن يقر الصانع أنه تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذ ذاك من قيمته يوم الدفع ، أو الرؤية فيغرمها ؛ لأنه أقر على نفسه وبإلغ على الضمان بقوله (ولو شرط) الصانع (نفية) أي نفي الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور ، وله أجر مثله (أودعا) الصانع ربه (لأخذه) بعد فراغه من صنعه فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال ابن عرفه إن لم يقبض الصانع أجرته فإن قبضها وصار بعد الفراغ وطلبه لأخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط (إلا أن تقوم بينة) بتلفه أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لأخذه أم لا ، وإذا لم يضمن (فتسقط الأجرة) من ربه ؛ لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه (وإلا أن يحضره) الصانع لربه (بشرطه) أي على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لأنه خرج من حكم الإجارة إلى الإيداع وهذا إذا كان قد دفع الأجرة وإلا كان رهناً فيها فحكمه حكم الرهن ، (وصدق) راع نحر بغيره ، أو ذبح

شاة (إن ادعى خوف موت) لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه المالك وقال بل تعديت ، وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفه (أو) ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال ذبحتها خوف موتها ثم سرفت ، ومثلاً الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع الضرس) أذن له فيه ونازعه ربه وقال قلعت غير المأذون فيه، (أو) ادعى الصباغ (صبغاً) بأن قال أمرتني به ، وقال ربه بل بغيره ، أو قال أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم من الزعفران مثلاً ، وقال ربه بل بخمسه (فتوزع) أي نازعه ربه فيصدق الأجير في المسائل الأربعة^(١).

(١) الشرح: أشار المصنف إلى أن شروط تضمين الصانع خمسة وهي:

- ١- أن ينصب نفسه للصنة لعامة الناس، ويسمى الأجير المشترك. واحترزا عن الأجير لشخص خاص، أو جماعة مخصوصين فلا ضمان عليه.
- ٢- أن يغيب الصانع عن الشيء المصنوع بأن لا يعمل في بيت ربه وإن لم يكن حاضراً أو بحضوره ولو في غير بيته، وإلا فلا ضمان عليه.
- ٣- أن يكون المصنوع مما يغاب عليه أي: بأن يمكن إخفاؤه.
- ٤- ألا يكون في صنعه تغيير، أي: تعريض للإتلاف، كتقب اللؤلؤ، ونقش الفصوص، وتقويم السيوف، والختان، وقلع الضرس، وخبز العيش في الفرن، والطب، فلا ضمان إلا بالتفريط.

فإذا ختن الخاتن، أو سقى الطبيب المريض دواءً، أو قلع له شيئاً، أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا في ماله ولا على عاقلته؛ لأنه مما فيه تغيير فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه، وهذا إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعله فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته، وإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب، وكون الدية على عاقلته أو في ماله قولان الأول لابن القاسم، والثاني لمالك وهو الراجح؛ لأن فعله عمد والعاقل لا تحمل عمداً.

- ٥- ألا تكون له بينة بتلفه بلا تفريط.

وإذا ضمن الصانع يضمن قيمته يوم دفعه المصنوع للصانع، لا يوم تلفه ولا يوم الحكم إلا أن يرى المصنوع عنده بعد يوم الدفع فإن رئي بعده فبأخر رؤية.

وإذا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع فلا أجره للصانع. وكذا إذا اعتبرت بآخر رؤية لم يكن مصنوعا، وعلى ربه الأجرة.

وإذا شرط الصانع نفي الضمان عن نفسه، فإنه يضمن ولا يفيد شرطه؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كذا علله الشيخ محمد عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير بهامش الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ أحمد الدريد، وأشار إلى تلك العلة الشيخ الخرشي في شرحه على مختصر خليل.

فإذا وقع العقد وعثر عليه ففيه أجره المثل قلت أة كثرت دون المسمى. وينتفي الضمان عن الصانع إذا كانت بينة تشهد بضياعة بلا تفريط فلا ضمان عليه. وهذا لأن ضمان الصانع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة.

فإن أحضره الصانع لربه مصنوعا على الصفة المشترطة فتركه صاحبه عنده، فادعي ضياعه فلا ضمان عليه؛ لأنه خرج مخرج الإيداع، ولا تسقط الأجرة؛ لأنها تستحق بالتسليم وقد حصل. وهذا ما لم يتركه عنده رهنا في نظير الأجرة، وإلا كان حكمه حكم الرهن يضمنه ضمان الرهان، ولا تسقط الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا.

ويصدق الراعي إن ادعى ضياح بعض الماشية بلا تفريط أو ادعى الخوف من موت بعضها فنحر أو ذبح وجاء بها مدكاه وخالفه ربه وقال له: بل تعديت كما يصدق إن ادعى سرقة ما نحر، وقال نحرتهما لخوف موتها فسرقت، وخالفه ربهما وقال: بل أكلتها، وفي كلا المسألتين يحلف الراعي إذا اتهم فقط، فإن خاف الراعي موتها وترك ذكاتها حتى ماتت ضمنها.

وإن قال: ذبحتها خوف الموت وأكلتها لم يصدق، إذا كان المحل قريبا، وذلك لقوة التهمة، وإلا صدق، ومحل عدم تصديقه مالم يجعل له ربهما أكلها وإلا صدق.

وأما المستأجر، والمستعير، والمرتهن، والمودع، والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعوى التذكية لخوف الموت إلا بطلخ، أو بينة، وإن كانوا يصدقون في التلف والضياح، وذكر الشيخ محمد عرفة الدسوقي أن الفرق بين هؤلاء والراعي مع كون الجميع أمناء لتعذر الإشهاد من الراعي غالبا بخلاف هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم في الإشهاد غالبا. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي بهامش الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٩).

وأحرى من هذا في الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وأدعى أنه فعل ذلك لخوف موتها، أو سلخ دابة غيره، وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ.

ويصدق الحجام إن ادعى قلع ضرس أذن له فيه، ونوزع في ذلك بأن المقلوع غير المأذون له فيه فالقول قول الحجام وله من الأجرة ما سماه إلا ان يصدقه الحجام على ما قاله فلا أجرة له، وعليه القصاص في العمد والعقل في الخطأ، وقول المصنف ضرر لا مفهوم له بل يشمل الضرر والسن والناوب، وإنما عبر به، وإنما خص الضرر بالذكر لأن الغالب أن الوجع يقع فيه.

ويصدق الصباغ أنه صبغ الثوب عصفرا بعشرة وادعى ربه أمره بخمسة منه، مع يمين الصانع إن أشبه أن يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشبهه صدق رب الثوب، فإن أتى بما لا يشبهه فله أجرة المثل.

فسخ الإجارة

قال المصنف: ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: (وَفُسِخَتْ) الإجارة (بِتَلْفٍ مَا يَسْتَوْفَى مِنْهُ لَا) بِتَلْفٍ مَا يَسْتَوْفَى (بِهِ) الْمُنْفَعَةُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى قَوْلِهِمْ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا فَيُهْلِكُهَا تَنْفُسُخُ الْإِجَارَةِ كَمَوْتِ الدَّابَّةِ الْمَعِينَةِ، وَكُلِّ عَيْنٍ تَسْتَوْفَى بِهَا الْمُنْفَعَةُ فَيُهْلِكُهَا لَا تَنْفُسُخُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَوْتِ الشَّخْصِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْعَيْنِ الْمَعِينَةِ وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ وَأَرَادَ بِالتَّلْفِ التَّعْذُرَ أَيْ تَعْذُرَ اسْتِيفَاءِ مَا اسْتَوْجَرَ عَلَيْهِ كَأَسْرِ وَصْبِي، وَسُكُونِ وَجَعِ ضَرْسٍ، وَعَفْوِ قِصَاصٍ، وَاسْتِثْنَى مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِهِ صَبِيَّيْنِ وَفَرَسَيْنِ بِقَوْلِهِ (إِلَّا صَبِيٍّ تَعْلَمُ) بِالإِضَافَةِ وَجَرَّ صَبِيٍّ لِأَنَّهُ مَسْتِثْنَى مِنْ ضَمِيرِ بِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَ نَفْيِ بِهِ فَهُوَ بَدَلُ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ لَا مَتَعْلَمَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْبَالِغَ مِنَ الْإِخْتِصَارِ (وَرَضِعَ) مَاتَ كُلُّ قَبْلَ تَمَامِ مَدَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ الشَّرُوعِ فِيهَا (وَفَرَسَ نَزْوٍ) مَاتَتْ مِثْلًا قَبْلَ النَّزْوِ عَلَيْهَا وَأَمَّا مَوْتُ الذَّكَرِ الْمَعِينِ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَفُسِخَتْ بِتَلْفٍ مَا يَسْتَوْفَى مِنْهُ (وُ) فَرَسَ (رَوْضٍ) أَيْ رِيَاضَةً أَيْ تَعْلِيمَهَا حَسَنَ الْجَرِيِّ فَمَاتَتْ، أَوْ عَطِبَتْ فَتَنْفُسُخُ وَلَهُ بِحِسَابِ مَا عَمِلَ وَالْحَقُّ بِهَذِهِ الصُّورِ الْأَرْبَعَةِ حَصْدُ زَرْعٍ مَعِينٍ، وَحَرْثِ الْأَرْضِ بِعَيْنِهَا وَبِنَاءِ حَائِطٍ بِدَارٍ فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّهِ غَيْرُهُ فَتَنْفُسُخُ لَتَعْذُرَ الْخَلْفَ، وَقِيلَ لَا بَلْ يُقَالُ لِرَبِّهَا ادْفَعْ جَمِيعَ الْأَجَرَةِ، أَوْ أَنْتَ بِغَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَصْنَفِ لِإِقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا (وُ) فَسِخَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى (سَنِ) لِقَلْعٍ) أَيْ لِأَجْلِ قَلْعِهَا فَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ وَلَوْ قَالَ وَقَلْعَ سَنِ (فَسَكَنْتَ) أَيْ أَلَمَهَا كَانَ أَوْضَحَ (كَعَفْوٍ) ذِي (الْقِصَاصِ) عَنِ الْمَقْتَصِ مِنْهُ فَتَنْفُسُخُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْقِصَاصِ لَتَعْذُرَ الْخَلْفَ وَهَذَا إِنْ عَفَا غَيْرَ الْمُسْتَأْجَرِ، وَأَمَّا إِنْ هَذَا الْمُسْتَأْجَرُ فَتَلَزَمَ حِينَئِذٍ الْأَجَرَةُ (وُ) فَسِخَتْ (بِغَضَبِ الدَّارِ) الْمُسْتَأْجَرَةُ (وِغَضَبِ مَنْفَعَتِهَا) إِذَا كَانَ الْغَاصِبُ لَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ، (وُ) فَسِخَتْ بِ (أَمْرِ السُّلْطَانِ) أَيْ

من له سلطنة وقهر (بإغلاق الحوانيت) بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها ، ويلزم السلطان أجرتها لربها إذا كان قصده غصب المنفعة فقط دون الذات ، (و) بظهور (حمل ظئر) أي مرضع (أو) حصول (مرض) لها (تقدر معه على رضاع) إن تحقق ضرر الرضيع وإلا كان أهله بالخيار كما تقدم، (و) بسبب (مرض عبد) لا قدرة له على فعل ما استؤجر عليه (وهربه لاعدو) بأرض حرب ، أو ما نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض الإسلام لم تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هروبه (إلا أن يرجع) العبد أي يعود من مرضه أو هربه (في بقيته) أي العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل ، كذا الظئر تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الكراء مقدار ما عطل من زمن المرض أو الهرب ويحتمل رجوع الاستثناء لقوله الدار وما بعده كأنه قال إلا أن يرجع الشيء المستأجر على حالته التي كان عليها قبل المانع فلا فسخ أن له جميع المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم (بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح) فلا ترجع الإجارة بعد الفسخ لما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر ، ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه فحكمهما سواء ، وإنما اختلف جواب الإمام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو العكس السؤال لكان الجواب ما ذكر (وخيّر) المستأجر في الفسخ وعدمه (إن تبين أنه) أي العبد مثلاً المستأجر ليعلمه في داره ، أو حانوته أو غيرها مما لا يمكن التحفظ منه فيه (سارق) أي شأنه السرقة ؛ لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة كالبيع ، وأما لو أكريته على شيء يمكن التحفظ منه فلا تنفسخ منه كما تقدم في المساقاة.

(و) فسخت الإجارة (برشد صغير عقد عليه) نفسه ، (أو على سلعة) كدأبته وداره (ولي) أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيداً فقلوه وبرشد معطوف على تلف بدليل الباء أي وفسخت بتلف ما ، وفسخت برشد ومعنى الفسخ إن شاء الصغير فهو مخير في الحقيقة ، وعطفه على إن تبين يبعده إعادة الباء ، وفي نسخة كرشد صغير بالكاف وهو تشبيه في التخيير وهي ظاهره ، والرشد يعتبر في العقد على نفسه ، أو على سلعة كما هو ظاهر وقد صرح به في التوضيح وقوله (إلا تظن عدم بلوغه) قبل انقضاء المدة (و) الحال أنه قد (بقى) منها اليسير (كالشهر) فيلزمه المدة ولا خيار له بأنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشهب وهو ضعيف ، والمذهب أنه خاص بالأولى ، والحاصل أن محل خياره في العقد على نفسه أن يظن الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئاً مطلقاً ، أو ظن عدم بلوغه فيها فبلغ رشيداً وقد بقي منها كثير بأن زاد على كالشهر فإن ظن عدمه فيها فبلغ فيها وقد بقي اليسير كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ويلزمه البقاء لتمامها.

وأما في إجارة سلعة فإن بلغ سفيها فلا خيار له ولا يعتبر العقد على سلعة ظن رشد ولا عدمه، وكذا إن بلغ رشيداً، وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الإجارة مطلقاً بقي اليسير أو الكثير فإن ظن البلوغ أولم يظن شيئاً فله الخيار فعلم أن الذي يخص المسألة الأولى هو قوله بقي كالشهر، وشبهه في الحكم المستثنى وهو اللزوم قوله (كسفيه) عقد وليه على سلعة، أو على نفسه لعيشه (ثلاث سنين) أو أكثر فرشد في أثناءها فتلزم الإجارة ولا خيار له حيث بقي من المدة الثلاث سنين فدون لأن الولي فعل ما يجوز له فإن عقد عليه لا لعيشه فله الفسخ لأن الولي لا تسلط له على نفسه بل على ماله وحينئذ فلو

اجر نفسه فلا كلام لوليه مالم يحاب وكذا لا كلام له إن رشد لأنه في نفسه كالرشيد.

(و) فسخت الإجارة (بموت مستحق وقف وآخر) ذلك الوقف في حياته مدة ، (ومات قبل نقضها) وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته ، أو لمن يليه ولو ولده ولو بقى منها يسير (على الأصح) ولو كان المستحق المؤجر ناظرا بخلاف ناظر غير مستحق فلا تنفسخ بموته (لا) تنفسخ (بإقرار المالك) للذات المؤجرة بأنه باعها ، أو وهبها ، أو أجزها لآخر قبل الإجارة ونازعه المكتري ولا بينة لاتهامه على نقضها ويلزمه الإقرار فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة وله الأكثر من المسمى الذي أكرت به وكراء المثل على المقر، (أو خلف) بضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف أي لا تنفسخ الإجارة بتخلف (رب دابة) معينة أم لا (في) العقد على زمن (غير معين) كأن يكتريها ليلاتي بها رجلا ، أو وفدا ، أو ليشيع بها رجلا يوم كذا ، أو شهر كذا فتخلف ريثا عن الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر بخلاف إذا عين الزمن كأكثرها يوم كذا ، أو على أن تخدمني ، أو تخيط لي في يوم كذا فتخلف فتفسخ ؛ لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن (أو) في غير (حج) فلا تنفسخ بخلاف الحج إذا أخلف ربها حتى فات فيفسخ الكراء وإن قبض الكراء رده لزوال أيامه (وإن فات مقصده) من تشييع مسافر أو ملاقا ته (أو) بظهور فسق مستأجر) لكدار لا تنفسخ ، وأمر (وآجر الحاكم) عليه (إن لم يكف) وهذا إن حصل بفسقه ضرر الدار أو الجار وهذا إن تيسر إيجارها عليه فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه ولزمه الكراء ومن أكرى أو اشترى داراً لها جار سوء فعيب ترد به ، ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أجرت، (أو بعث عبد) مؤجر لا تصح إجارته (وحكمه على الرق) أي يستمر رقيقاً إلى تما

المدة في شهادته وقصاصه له وعليه وارثه لا فب وطاء السيد لها إن كانت أمة لتعلق حق المستأجر بالعين المؤجرة فإن أسقط حقه فما بقي من المدة مجاناً أو بشيء أخذ م العبد نجر عتقه (وأجرته) في باقي المدة بعد العتق (لسيده إن أراد أنه حر بعدها) لأنه بمنزلة من أعتقه، واستثنى منفعة مدة معينة فإن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته للعبد مع بقاءه إلى تمامها فالشرط راجع لقوله وأجرته لسيده فقط لا لما قبله^(١).

(١) الشرح : ذكر المصنف قاعدة المذهب في فسخ الإجارة أن كل عين يستوفى منها المنفعة فيهلكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة، وانهدام الدار المعينة.

ونوع ما في قول المصنف "بتلف ما يستوفى منه" ما موصولة، أي: الذي يستوفى منه، والموصول عند أهل اللغة من صيغ العموم، فكأنه قال بتلف كل ما يستوفى منه، لا نكرة بمعنى شيء، لأن النكرة في سياق الإثبات لا عموم لها، وقوله بتلف ما يستوفى منه إذا كان معيناً وأما إذا كان مضموناً في الذمة فلا تنفسخ بتلفه. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤، ص ٢٩، شرح الخرشي على مختصر خليل ج ٧، ص ٣٠).

وقوله: "وانهدام الدار المعينة" لم يقيد ابن الحاجب الدار لكونها معينة قال في التوضيح: ولم يذكر المصنف التعيين لأن الدار لا تكرر إلا معينة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٤، ص ٢٩).

تنبيه: وسوف اذكر الأمور التي تنفسخ بها الإجارة أولاً، ثم اذكر بعد الأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة فلتنبيه إلى ذلك أيها القارئ الكريم، فالمصنف في الكتاب ذكر القاعدة التي تنفسخ بها الإجارة وذكر لها أمثلة، ثم بعد ذلك ذكر الأمور التي تستثنى من القاعدة، وساق بعد هذا الاستثناء أموراً تنفسخ بها الإجارة فلاحظ ذلك وفقك الله. ينبى على القاعدة التي ذكرها المصنف وهي كل عين يستوفى منها المنفعة فيهلكها تنفسخ الإجارة ما يلي:

- تنفسخ الإجارة إذا تعذر ما يستوفى منه المنفعة مثل الدار، والحانوت، والحمام السفينة ونحوها، وإن لم تعين حال العقد، ودابة عينت، والتفصيل بين المعينة وغيرها إنما في الدابة فقط، أما السفينة، والحمام ونحوهما متى تعذر ما يستوفى منه فسخت الإجارة. وأراد المصنف بقوله تلف التعذر-أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه-؛ لأن التعذر أعم من التلف، ويشمل الضياع والمرض، والغصب وغلق الحوانيت قهوا كما ذكره المصنف بعد ذلك.

وإذا فسخت الإجارة رجع إلى المحاسبة باعتبار ما حصل من المنفعة وما لم يحصل، وباعتبار المسافة طولا وقصرا، صعوبة وسهولة.

- وتنفسخ الإجارة ولو كان التعذر بغصب لما يستوفى منه دارا كانت، أو غيرها أو غصب منفعة لما يستوفى منه ولو لم يغصب الذات إذا كان الغاصب لا تتاله الأحكام.

كما تنفسخ الإجارة ولو بأمر ظالم لا تتاله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكثرة بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها، ويلزم الظالم أجرتها لربها إذا كان قصده غصب المنفعة فقط دون الذات.

ومحل فسخ الإجارة: بغصب العين المستأجرة، أو غصب منفعتها إن شاء المستأجر؛ وإن شاء بقي على اجارته، فإن فسخها كان لمالك الذات المغصوبة الأجرة على الغاصب، وإن أبقاها من غير فسخ صار ذلك المستأجر مع الغاصب بمنزلة المالك فتكون الأجرة له، ومعنى الفسخ في هذه المسائل أنها معرضة للفسخ، لا إنها تنفسخ بالفعل.

- وتنفسخ الإجارة بحمل الظئر-أي المرضع-سواء كان الحمل قبل عقد الإجارة وظهر بعده أو طرأ بعد عقد الإجارة إذا لم تقدر على الرضاع، فإن قدرت على الرضاع فلا تنفسخ الإجارة ما لم يضر بالرضيع.

- تنفسخ الإجارة إذا حدث مرض للأجير لا يقدر معه على عمل ما استؤجر عليه أو مرض الظئر-المرضع-لا تقدر معه على الرضاع فإن قدرت معه على الرضاع لم تنفسخ الإجارة إلا أن يضر.

- تتفسخ الإجارة بمرض الدابة لا تقدر معه على الفعل ما استؤجرت عليه وذلك لنفي الضرر الذي يدخل على المكري لو ألزمه ربه أن يقيم معه وينتظر شفاءها؛ لأن ذلك قد يؤخره عن الوصول إلى مقصده ويفوت عليه المصلحة، ونفي الضرر عن رب الدابة لو ألزمه المكري ورغب في الإقامة حتى تشفى؛ لأن السفر قد يجحف به ويقطعه عن عياله ويكلفه من النفقة الزائدة على نفسه وعلى الدابة.
 - وإذا صح الأجير، أو صحت المرضع، أو الدابة في مدة الإجارة قبل الفسخ بالفعل فيلزم ببقية العمل ولا تفسخ الإجارة، وسقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام المرض.
 - وإذا حصل الفسخ قبل الصحة لم يلزم الأجير والظئر وصاحب الدابة عمل فيما بقي.
-
- وتتفسخ الإجارة إذا تبين للمستأجر أن الأجير شأنه السرقة؛ لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة والبيع، وبذلك علل الشيخ الدردير، فيخير المستأجر في الفسخ وعدمه، وهذا حيث كان استأجره للخدمة في بيته أو حانوته مما لا يمكن التحفظ فيه منه وأما لو إذا أجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تفسخ الإجارة بتبين سرقة لإمكان التحفظ منه.
-
- وتتفسخ الإجارة إذا تبين للمستأجر أن الأجير قد بلغ رشيدا، أي: حيث كان صغيرا وعقد عليه أو على سلعة وليه من أب أو وصي، أو حاكم كما إذا استأجره لخدمة مثلا ثلاث سنوات فبلغ رشيدا قبل انقضاء المدة، فإنه مخير بين الإبقاء لتمام المدة والفسخ.
 - لكن يلزم في العقد عليه بقاء المدة بقيدين:
 - الأول: أن يظن اليسير من المدة قبل تمام المدة وقت العقد فبلغ.
 - الثاني: أن يبقى اليسير من المدة كالشهر.
 - فبهذين القيدين لا خيار له. وإنما الخيار فيما إذا ظن وليه بلوغه فيهما أو لا ظن عنده مطلقا أي: بقي اليسير أو الكثير كان العقد عليه أو على السلعة أو ظن عدمه وبقي في العقد عليه الكثير.
 - كما يلزم العقد إذا عقد ولي الصغير على سلع الصغير، كدابته وداره وغيرهما فيلزم فيما إذا ظن عدم بلوغه مطلقا، ولو بقي في المدة سنين بعد رشده على الأرجح.
 - ومقابلة قول أشهب إن العقد على السلعة كالعقد عليه لا يلزمه إلا إذا ظن الولي عدم بلوغه وبقي مثل الشهر.

وأما سلع السفية إذا عقد وليه عليها فإنه لازم له إلا إذا رشد في أثناء مدة الإجارة بقي اليسير أو، ظن وليه رشده أم لا. إذ الرشد لا تعلم له غاية، وهو غير منضبط بالنسبة للسفيه.

وللسفيه أن يؤجر نفسه لعيشه، سواء ظن رشده أو ظن عدمه أو لم يظن شيء بقي اليسير أو بقي الكثير وهذا دون سلعة؛ لأنه محجور عليه بالنسبة لسلعة دون نفسه، ولا كلام لوليه في ذلك إلا أن يحابي، فلوليه الكلام من حيث المحابة. وكذلك لا كلام للولي إن رشد السفية؛ لأنه في نفسه كالرشيد، ولو آجره وليه لغير عيشه فله هو الفسخ لأن الولي لا تسلط له على نفسه. وإن آجر نفسه لعيشه فلا كلام له.

- وتتفسخ الإجارة بموت مستحق وقف أجر ذلك الوقف مدة معينة، ومات قبل تقضيها. وانتقل الاستحقاق فيه لمن في طبقته ولو ولده، وبقي يسير من المدة. فتتفسخ الإجارة ولو كان ذلك المستحق الذي آجر ناظرا-على الأصح-بخلاف نظرا غير المستحق أجر مدة معلومة بأجر المثل ثم مات فلا تتفسخ، ومقابل القول الأصح قول ابن شاش لا تتفسخ وهو قول ضعيف لأنه لا يعرف لغيره.

مالا تنفسخ به الإجارة

قال المصنف: ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: (وَفُسخت) الإجارة (بتلف ما يستوفى منه لا) بتلف ما يستوفى (به) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم أن كل عين يستوفى منها فيهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة ، وكل عين تستوفى بها المنفعة فيهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم ورثته مقامه وأراد بالتلف التعذر أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه كأسر وصبي، وسكون وجع ضرر ، وعفو قصاص ، واستثنى من قوله لابه صبيين وفرسين بقوله (إلا صبي تعلم) بالإضافة وجر صبي لأنه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي به فهو بدل منه ولو قال لا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار (ورضع) مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو الشروع فيها (وفرس نزو) ماتت مثلاً قبل النزو عليها وأما موت الذكر المعين فداخل في قوله وفسخت بتلف ما يستوفى منه (و) فرس (روض) أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت ، أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما عمل وألحق بهذه الصور الأربعة حصد زرع معين ، وحرث الأرض بعينها وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف ، وقيل لا بل يقال لربها ادفع جميع الأجرة ، أو انت بغيرها وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على الأربعة التي ذكرها (و) فسخت الإجارة على (سنٍ لقلع) أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ولو قال وقلع سن (فسكنت) أي ألمها كان أوضح (كعفو) ذي (القصاص) عن المقتص منه

فتفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف وهذا إن عفا غير المستأجر، وأما إن هذا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة^(١).

(١) الشرح: بعد أن أشار المصنف إلى الأمور التي تنفسخ بها الإجارة وذكر قاعدة المذهب أن كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة. وذكر عدة مسائل تتبني على هذه القاعدة - سبق ذكر هذه المسائل تحت عنوان فسخ الإجارة- و ذكر هنا أمور لا تنفسخ بها الإجارة. (أخرت الحديث عن الأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة إلى هذا الموضع حتى تكون جميع مسائل فسخ الإجارة في موضع واحد ويستطيع القارئ الإلمام بها ، وقد نبهت إلى ذلك الأمور في بداية الكلام عن فسخ الإجارة).

وذكر المصنف قاعدة للأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة وهي:

أن كل عين يستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة وقوم ورثته مقامه إلا في أربع مسائل: صبيان، وفرسان؛ وصبيا التعليم والرضاعة ، وفرسا النزو والرياضة. فحيث مات صبي التعليم والرضاعة انفسخت الإجارة ، ورجعا للمحاسبة ، وكذلك فرس النزو إذا استأجر الفحل على مدة معينة ثلا، أو أربع سنوات مثلا فحملت من مرتين ،او ماتت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسبة وكذلك إذا استؤجر لفرس يروضها ويعلمها كيفية الجري فماتت ، ويرجعان للمحاسبة وعلى القاعدة المذكور فإن الإجارة لا تنفسخ بموت الشخص المستأجر للعين المستأجرة، و يستثنى مما لا تنفسخ به الإجارة أربع مسائل تنفسخ الإجارة فيها بهلاك العين التي تستوفى بها المنفعة ، وهي: صبيان ، وفرسان ، صبيا للتعليم، والرضاعة، وفرسا فرس للنزو، والرياضة، فإذا استأجر شخصا معلما لتعليم صبي ويشمل البالغ، وقول المصنف "إلا صبي تعلم" أي لأن الصبي لا مفهوم له، وإنما خصه بالذكر؛ لأنه هو الذي شأنه التعليم. أو امرأة لترضع صبيا ، أو فحلا للنزو على فرس أي استأجر صاحبها ذكرا ينزو عليها جمعة مثلا، أو عشر مرات بدينار وحملت من مرة فتفسخ الإجارة ولرب الذكر من الأجر بحساب ما عمل ويشمل كل دابة نزو، أو مروضاً لترويض فرس، فإذا استأجر رب الفرس شخصا يعلمها حسن السير فماتت قبل تعليمها فإن الإجارة تنفسخ وله بحساب ما عمل ؛ فإذا مات صبي التعليم أو الرضاعة انفسخت الإجارة ورجعا للمحاسبة.

هذه المسائل الأربع المستثناة عند سحنون ، وابن أبي زيد القيرواني ، وقال ابن عرفة له الأجرة لا تنفسخ في المسائل الأربع ، وله جميع الأجرة ؛ لأن المانع ليس من جهته .
وألحق بهذه الأربعة حصد من استأجر شخصا لحصد زرع معين ، أو وحرث أرض بعينها ليس لربها غيرهما ، أو بناء حائط بدار ، فيحصل مانع من جهة رب الأرض ، أو الزرع ، أو الحائط ، كأن تلف الزرع ، أو يبست الأرض ، أو تفقد مواد البناء ، وليس لرب الأرض غيرها فتتفسخ الإجارة لتعذر الخلف ، أما إن كان له خلف استأجره فيها ، أو يدفع له الأجرة بتمامها ولا تنفسخ الإجارة .

وقيل : لا تلحق هذه المسائل بالمسائل الأربعة المستثناة ، وقيل لا تنفسخ الإجارة ، ويقال لربها : ادفع الأجرة كاملة ، أو انت بغيرها إن كان له غيرها .
وعلى كل فالمسائل المستثناة والمسائل المختلف في إلحاقها بها ن مقيدة بكونها من جهة المستأجر ، فهي من قبيل ما يستوفى به . أما إذا كان المانع من جهة المؤجر على الحصد ، أو الحرث ، أو البناء ، كان ذلك من قبيل تعذر ما يستوفى منه ، وليس الكلام هنا فيه .

- لا تنفسخ الإجارة بإقرار المالك للذات المؤجرة بأن باعها أو وهبها أو أجرها لأخر ر قبل الإجارة المذكورة ، ونازعه المكثري ولا توجد معه بينة لاتهامه بنقضها ، ويلزمه الإقرار فيأخذها المقر بعد انتهاء المدة وله الاكثر من المسمى الذي أكرت به ، وكراء المثل على المقر .

- وقول المصنف "أو خلف" بضم الخاء ، وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف أي : لا ينفسخ الكراء بتخلف رب دابة معينة ، أو غير معينة عقد عليها شخص لملاقاة رجل أو ليشيع بها رجلا فتخلف ربا عن الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر ، وإن فات ما يقصده ويروم إليه ، ما لم يكن الزمن معيناً ولم يكن حجا . ووجه عدم الفسخ عند عدم تعيين الزمن وعدم الحج أن المكثري يمكن أن يصل إلى غرضه في أي وقت في السنة .

- أما إذا كان الوقت معيناً أو حجا فلم يأت المكثري بالشيء المكثري إلى أن أنقضى الزمن المعين ، أو فات الحجب إن الكراء ينفسخ .